

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG
BỘ MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁP LUẬT

Tài liệu học tập
MÔN: PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG

Hà Nội, tháng 8 năm 2021

A. Mục đích yêu cầu :

- **Mục đích:** Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật nói chung và pháp luật Việt Nam nói riêng. Trên cơ sở đó, sinh viên sau khi ra trường có thể vận dụng các kiến thức pháp luật đã học để giải quyết các tình huống xảy ra trên thực tế; đồng thời giúp hình thành ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi xử sự phù hợp với pháp luật của sinh viên; cũng như là cơ sở để sinh viên có thể tự tìm hiểu các quy định của pháp luật có liên quan đến công việc và cuộc sống sau này.

- **Yêu cầu:** Sinh viên cần dự lớp tối thiểu 80% số giờ học và kết hợp với nghiên cứu tài liệu, từ đó hình thành các kỹ năng thực hành cần thiết theo yêu cầu của môn học.

B. Nội dung chi tiết

C . Tài liệu tham khảo

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
- Bộ luật dân sự năm 2015;
- Bộ luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật thương mại năm 2005;
- Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 và năm 2019;
- Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;
- Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;
- Bộ luật tố tụng hình sự 2015;
- Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Chương 1:

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC

1.1.1. Nguồn gốc của nhà nước

1.1.1.1. Một số học thuyết về nguồn gốc của Nhà nước

Nhà nước là một hiện tượng xã hội đa dạng và phức tạp. Để có nhận thức đúng về bản chất Nhà nước, cũng như những biến động trong đời sống Nhà nước cần lý giải nhiều vấn đề trong đó nhất thiết phải làm sáng tỏ nguồn gốc hình thành Nhà nước, chỉ ra những nguyên nhân đích thực làm xuất hiện Nhà nước.

Trong lịch sử chính trị - pháp lý, ngay từ thời kỳ cổ đại, trung đại và cận đại đã có nhiều nhà tư tưởng đề cập tới vấn đề nguồn gốc của nhà nước. Xuất phát từ các góc độ khác nhau, các nhà tư tưởng trong lịch sử đã có những lý giải khác nhau về vấn đề nguồn gốc của nhà nước. Các học thuyết này có thể chia làm hai nhóm. Nhóm học thuyết phi mác-xít và học thuyết Mác-Lênin.

a. Theo các học thuyết phi mác-xít:

a1) Thuyết thần học:

Những nhà tư tưởng theo thuyết thần học cho rằng: Thượng đế là người sắp đặt mọi trật tự trong xã hội, nhà nước là do thượng đế sáng tạo ra để bảo vệ trật tự chung xã hội. Nhà nước là do đấng tối cao sinh ra, là sự thể hiện ý chí của chúa trời. Do vậy, quyền lực của nhà nước là hiện thân quyền lực của chúa, vì thế nó vĩnh cửu. Sự phục tùng quyền lực này là cần thiết và tất yếu.

a2) Thuyết gia trưởng:

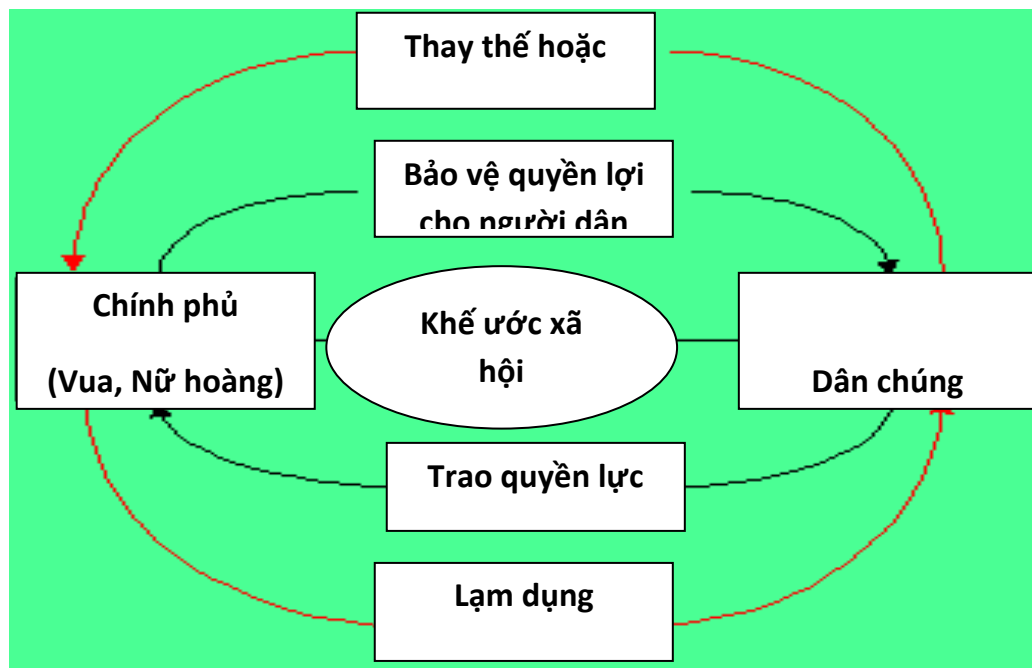
Những người theo thuyết gia trưởng cho rằng: Nhà nước ra đời là kết quả của sự phát triển gia đình, là hình thức tổ chức tự nhiên của cuộc sống con người, vì vậy, cũng như gia đình, nhà nước tồn tại trong mọi xã hội, quyền lực nhà nước về thực chất cũng giống như quyền lực của người đứng đầu trong gia đình, nó chỉ là sự tiếp tục của quyền lực của người gia trưởng trong gia đình.

Thực chất của thuyết này nhằm bảo vệ chế độ quân chủ chuyên chế thời phong kiến, nó gắn liền với tôn giáo, thần thánh hoá quyền lực quân chủ.

a3) Thuyết khế ước xã hội:

Thuyết khế ước xã hội cho rằng: nhà nước ra đời là kết quả của một bản hợp đồng (khế ước) được ký kết giữa các thành viên sống trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước. Về bản chất, nhà nước phản ánh lợi ích của các thành viên sống trong xã hội, lợi ích của mỗi thành viên đều được nhà nước ghi nhận và bảo vệ.

Sự ra đời của thuyết khế ước xã hội đánh dấu một bước tiến trong nhận thức của con người về nguồn gốc nhà nước, chống lại sự chuyên quyền, độc đoán của chế độ phong kiến. Theo học thuyết, chủ quyền trong nhà nước thuộc về nhân dân, và nếu nhà nước không làm tròn vai trò của mình, các quyền tự nhiên bị vi phạm thì khế ước sẽ bị mất hiệu lực, nhân dân có quyền lật đổ nhà nước và ký kết khế ước mới.



Về mặt lịch sử, thuyết khế ước xã hội có tính cách mạng và giá trị lịch sử to lớn, nó chứa đựng những yếu tố tiên bộ xã hội. Tuy nhiên, thuyết khế ước xã hội vẫn có những hạn chế nhất định, các nhà tư tưởng vẫn đứng trên lập trường quan điểm của chủ nghĩa duy tâm để giải thích sự xuất hiện của nhà nước và sự thay thế nhà nước. Nó chưa lý giải được nguồn gốc vật chất và bản chất giai cấp của nhà nước. Thực tế cho thấy hoàn toàn không có một bản khế ước như vậy và đây là điều phi hiện thực. Thuyết này là cơ sở cho cách mạng tư sản lật đổ ách thống trị phong kiến.

a4) Thuyết bạo lực

Những người theo thuyết bạo lực cho rằng: Nhà nước xuất hiện trực tiếp từ việc sử dụng bạo lực giữa thị tộc này với thị tộc khác mà kết quả là thị tộc chiến thắng thiết lập nên bộ máy cai trị, áp đặt các quy tắc cai quản đối với thị tộc chiến bại.

Tóm lại: Tất cả các học thuyết trên đều cố gắng lý giải, chỉ ra các nguyên nhân ra đời Nhà nước nhưng do còn hạn chế về mặt lịch sử, nhận thức hoặc bị chi phối bởi lợi ích giai cấp mà cố tình giải thích sai lệch những nguyên nhân đích thực làm phát sinh Nhà nước nhằm che đậy bản chất Nhà nước. Đa số họ xem xét sự ra đời của Nhà nước tách rời những điều kiện vật chất xã hội, tách rời những

nguyên nhân kinh tế mà đi chứng minh rằng Nhà nước luôn luôn tồn tại trong mọi xã hội, Nhà nước là một lực lượng đứng trên xã hội.

b. Quan điểm của chủ nghĩa Mac – Lênin

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac - Lênin, Nhà nước là một hiện tượng xã hội nảy sinh bởi nguyên nhân từ xã hội. Nó có quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong trong lịch sử. Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội phát triển đến một trình độ nhất định và tiêu vong khi các điều kiện khách quan cho sự tồn tại của nó mất đi.

b1) Chế độ công sản nguyên thủy, tổ chức thị tộc - bộ lạc và quyền lực xã hội

Chế độ công sản nguyên thủy là hình thái kinh tế xã hội đầu tiên trong lịch sử loài người, ở đó không tồn tại giai cấp, Nhà nước và pháp luật nhưng đã chứa đựng những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Nhà nước.

- Cơ sở kinh tế: Do trình độ phát triển của lực lượng sản xuất còn thấp kém, công cụ lao động còn thô sơ, sự hiểu biết về thế giới tự nhiên của người lao động còn lạc hậu nên con người phải dựa vào nhau cùng chung sống, cùng lao động, cùng hưởng thành quả của lao động chung. Mọi tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động đều thuộc sở hữu chung của mọi thành viên trong cộng đồng. Trong điều kiện đó không ai có tài sản riêng, không có người giàu, người nghèo, xã hội chưa phân chia thành giai cấp và không có đấu tranh giai cấp.

- Tổ chức xã hội: Được tổ chức rất đơn giản. Tế bào của xã hội là thị tộc. Thị tộc được tổ chức theo nguyên tắc huyết thống, lúc đầu huyết thống được xác lập theo dòng mẹ gọi là thị tộc mẫu hệ và về sau được xác lập theo dòng cha gọi là thị tộc phụ hệ. Mỗi thành viên của thị tộc đều tự do, bình đẳng về quyền lợi và địa vị xã hội, trong xã hội không tồn tại đặc quyền, đặc lợi không có sự phân hóa giàu nghèo. Quá trình phát triển xã hội công sản nguyên thủy đã xuất hiện hình thức tổ chức cao hơn, nhiều thị tộc hợp thành bộ lạc, nhiều bộ lạc hợp thành bộ lạc.

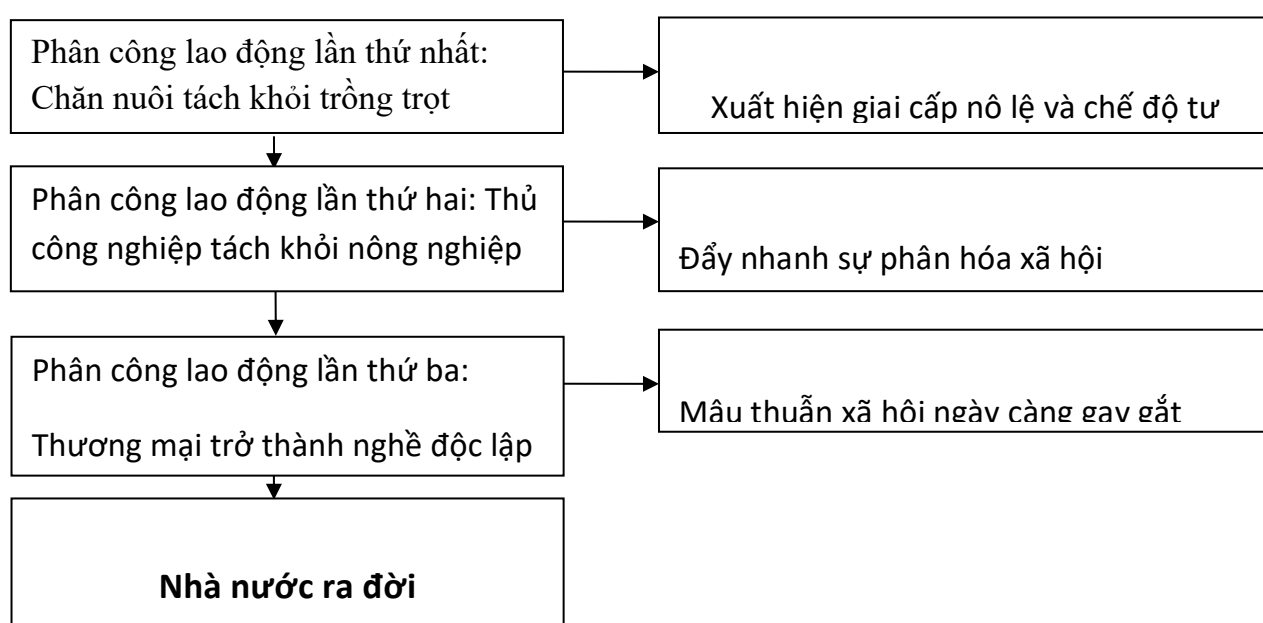
- Quyền lực xã hội: Hệ thống quản lý của thị tộc là Hội đồng thị tộc và tù trưởng. Hội đồng thị tộc hợp thành bởi tất cả các thành viên đã trưởng thành của thị tộc là tổ chức quyền lực cao nhất của thị tộc. Hội đồng sẽ bầu ra thủ lĩnh hoặc tù trưởng (được lựa chọn từ những người nhiều tuổi, có kinh nghiệm và uy tín trong cộng đồng). Tù trưởng đứng đầu thị tộc song không có đặc quyền so với các thành viên khác của thị tộc, họ cũng phải lao động và được hưởng thụ như mọi người. Quyền lực của họ gắn liền với dân cư, dựa trên uy tín mà không dựa vào sự cưỡng chế.

Như vậy, trong xã hội công sản nguyên thủy chưa xuất hiện chế độ tư hữu và chưa có sự phân chia giai cấp, do đó quyền lực xã hội do dân cư tự tổ chức, không mang tính chính trị và giai cấp. Tuy nhiên, điều này sẽ dần dần bị phá vỡ

khi xã hội ngày càng phát triển với ba lần phân công lao động xã hội. Mỗi lần phân công lao động xã hội đã dẫn đến những hệ quả nhất định và các hệ quả này chính là nguyên nhân cho sự ra đời nhà nước.

b2) Sự tan rã của chế độ công sản nguyên thủy và sự xuất hiện Nhà nước

Trong quá trình sống và lao động sản xuất, con người ngày một phát triển hơn về thể chất, trí lực, cấu trúc các giác quan ngày một hoàn thiện, hiểu biết nhiều hơn các quy luật tự nhiên và xã hội, tích lũy được nhiều kinh nghiệm sản xuất, luôn tìm kiếm và cải tiến các công cụ lao động dẫn đến năng suất lao động xã hội tăng lên không ngừng, lực lượng sản xuất có những bước tiến rõ rệt đòi hỏi có sự phân công lao động theo hướng chuyên môn hóa. Vào thời kỳ cuối của chế độ cộng sản nguyên thủy đã diễn ra lần lượt 3 lần phân công lao động xã hội:



- Sự phát triển của công cụ sản xuất, sự phân công lao động xã hội làm cho kinh tế đạt những bước tiến dài, sản phẩm làm ra ngày một nhiều hơn so với yêu cầu của xã hội, xuất hiện của cải dư thừa, phát sinh khả năng chiếm đoạt sản phẩm thừa làm của riêng. Quá trình phân hóa tài sản bắt đầu nảy sinh, những người có địa vị và uy tín trong xã hội như tù trưởng, thủ lĩnh quân sự lợi dụng ưu thế sẵn có của mình chiếm đoạt tài sản của thị tộc - bộ lạc thành tài sản riêng. Chế độ tư hữu được hình thành.

- Trước đây do khả năng kinh tế không cho phép và nhu cầu về sức lao động không đặt ra nên tù binh bị bắt trong các cuộc giao tranh giữa các thị tộc - bộ lạc đều bị giết, về sau do sản xuất phát triển, nhu cầu sức lao động tăng, tù binh được giữ lại nuôi để bổ sung vào nguồn lao động và những người có địa vị trong thị tộc đã chiếm hữu và khai thác lao động cho cá nhân họ.

- Chế độ hôn nhân một vợ, một chồng xuất hiện, gia đình có cơ cấu nhỏ tách khỏi gia đình phụ hệ cơ cấu lớn và trở thành đơn vị kinh tế tự chủ trong sản xuất, độc lập tài sản, tự định đoạt sản phẩm lao động.

Trong quá trình sản xuất, những người có công cụ tốt, có sức khỏe và kinh nghiệm thu được hiệu quả cao, ngày càng giàu có. Một số người chiếm được tư liệu sản xuất, bóc lột lao động tù binh và bóc lột những người nghèo khác trở nên giàu có, giành được vị trí ưu thế trong xã hội và trở thành giai cấp bóc lột. Những người không có tư liệu sản xuất, bị bóc lột ngày càng nghèo khó trở thành giai cấp bị bóc lột. Hai bộ phận dân cư này do quyền lợi đối lập nhau nên mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt và quyết liệt.

Trước thực trạng trên, chế độ thị tộc tỏ ra bất lực, không đủ khả năng điều hành và quản lý xã hội. Nhu cầu khách quan đó cần một tổ chức đó chính là nhà nước và nhà nước đã xuất hiện.

Nhà nước do giai cấp chiếm được ưu thế về kinh tế tổ chức ra để thực hiện sự thống trị giai cấp, dập tắt xung đột công khai giữa các giai cấp, giữ các xung đột ấy trong một vòng trật tự, bảo vệ lợi ích và địa vị của giai cấp thống trị.

b3) Nguyên nhân ra đời Nhà nước

- Nguyên nhân kinh tế:

Với sự phát triển của lực lượng sản xuất cùng sự phân công lao động xã hội đã tạo ra được của cải vật chất ngày càng nhiều hơn so với nhu cầu thỏa mãn ở mức độ cần thiết tối thiểu của xã hội, xuất hiện của cải dư thừa, xuất hiện sự chiếm đoạt tài sản làm của riêng. Chế độ tư hữu xuất hiện.

- Nguyên nhân xã hội:

Xuất phát từ chế độ tư hữu, trong xã hội xuất hiện những bộ phận người mâu thuẫn nhau về lợi ích kinh tế. Những người giàu có đã giành được ưu thế trong xã hội và trở thành giai cấp bóc lột. Những người nghèo không có tư liệu sản xuất ngày càng trở nên nghèo hơn và trở thành giai cấp bị bóc lột, mà điển hình là những người nô lệ. Hai bộ phận này do lợi ích đối lập với nhau đến mức không thể điều hòa được.

Ngoài nguyên nhân kinh tế và nguyên nhân xã hội, sự xuất hiện nhà nước ở các vùng và của các dân tộc khác nhau cũng có những đặc điểm khác nhau do có các điều kiện kinh tế, xã hội, vị trí địa lý và ngoại cảnh khác nhau.

1.1.1.2. Các con đường hình thành Nhà nước

Theo Ăng- ghen, có 4 phương thức hình thành Nhà nước¹.

¹ Nguyễn Bằng Tường (2010). *Giới thiệu tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước”*. NXB Chính trị quốc gia-Sự thật.

a. Sự ra đời của Nhà nước Aten (Hy Lạp)

Từ thế kỉ 12 trước công nguyên (TCN), tộc người Đôriêng gồm 4 bộ lạc đến xâm chiếm vùng đồng bằng miền Trung lục địa Hi Lạp (nơi có nhiều khoáng sản, có đường bờ biển dài, nhiều vịnh, rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế công thương nghiệp, đặc biệt là thương mại đường biển).

Từ thế kỉ 8 TCN, 4 bộ lạc này liên minh với nhau hình thành nên Liên minh bộ lạc. Những người đứng đầu 4 bộ lạc là quý tộc chủ nô và nắm toàn bộ quyền lực.

Đến thế kỉ thứ 7 TCN, Hy Lạp đã xây dựng xong thành bang Aten (hai nhà nước thành bang nổi bật và đáng lưu ý là: Nhà nước Cộng hòa quý tộc chủ nô Xpác và Nhà nước Cộng hòa dân chủ chủ nô Aten). Trong xã hội Aten lúc này có 2 mâu thuẫn cơ bản đó là mâu thuẫn giữa quý tộc chủ nô cũ và quý tộc chủ nô mới; mâu thuẫn giữa giai cấp quý tộc chủ nô nói chung và tầng lớp bình dân, nô lệ.

Đến thế kỉ 6 TCN, cuộc cách mạng Xô-lông năm 594TCN và Klix-ten năm 509 TCN dẫn đến sự tan rã toàn bộ chế độ thị tộc và nhà nước thực sự được hình thành.

Nhà nước Aten ra đời là kết quả vận động của những nguyên nhân nội tại trong xã hội đó là sự chiếm hữu tài sản và sự phân hóa giai cấp trong xã hội. Nhà nước Aten là phương thức xuất hiện Nhà nước có tính thuần túy và cổ điển nhất (sự vận động, phát triển của lực lượng sản xuất dẫn đến xuất hiện giai cấp, xuất hiện Nhà nước).

b. Sự ra đời của Nhà nước Roma

Lịch sử La Mã từ năm 753 đến 510 TCN thường được gọi là “chế độ vương triều”. Trong thời gian này có 7 ông vua lần lượt thống trị La Mã. Công xã La Mã có 300 thị tộc, 10 thị tộc thành một bào tộc và 10 bào tộc tổ chức thành một bộ lạc. Do vậy, La Mã có 3 bộ lạc và thực hiện chế độ quân sự dân chủ. Vua vừa là thẩm phán, chánh án tối cao.

Vào giữa thế kỷ VI trước công nguyên vua Servius Tullius (vị hoàng đế thứ 6 của La Mã cổ đại) đã phá giới hạn của tổ chức thị tộc, thực hành cải cách xã hội. Ông căn cứ theo tài sản tư hữu nhiều, ít để chia toàn thể những người trai tráng có nghĩa vụ đi lính, không phân biệt quý tộc Patrici hay bình dân Po-lep làm sáu đẳng cấp: đẳng cấp thứ nhất là lớp quý tộc có nhiều của cải; càng xuống những đẳng cấp dưới thì của cải tư hữu càng ít dần; đẳng cấp thứ sáu thì chỉ gồm những người vô sản. Nguyên nhân căn bản của những biến động xã hội dẫn đến cải cách của Tullius là cuộc đấu tranh ngày càng quyết liệt giữa một bên là quần chúng bình dân Po-lep mà vai trò trong nền sản xuất xã hội ngày càng trở nên quan trọng và một bên là tầng lớp quý tộc Patrici mà thế lực đã bị giảm sút. Kết quả tất nhiên của cuộc đấu tranh đó là sự giải thể nhanh chóng của xã hội thị tộc La Mã, là sự

thủ tiêu bước đầu tình trạng cách biệt về nguồn gốc xã hội giữa Pơ-lep và Patrici, là sự thực hiện bước đầu quyền bình đẳng về nghĩa vụ quân sự giữa hai giai cấp đó. Bởi vậy cải cách của Tullius tuy chưa hoàn toàn xóa bỏ mọi sự cách biệt giữa quý tộc và bình dân, song vẫn được người bình dân xem như là một trong những thắng lợi đầu tiên của họ đối với giai cấp quý tộc thị tộc.

c. Sự ra đời của Nhà nước Giec mạnh (Đức)

Từ thời kỳ cổ đại, nước Đức đã có các bộ lạc người German cư ngụ. Quân German hết mực can trường, mãnh liệt và dưới sự lãnh đạo của tù trưởng Arminius, họ tiêu diệt hoàn toàn ba binh đoàn Lê dương La Mã, các bộ tộc German xâm nhập La Mã, dẫn đến sự sụp đổ của Đế quốc Tây La Mã vào năm 476. Nhà nước Giec mạnh hình thành khoảng giữa thế kỷ V trước công nguyên do nhu cầu phải thiết lập sự cai trị đối với vùng đất La Mã cổ sau chiến thắng của người Giéc mạnh chứ không phải do yêu cầu đấu tranh giai cấp trong xã hội Giéc mạnh. Do Nhà nước hình thành không phải từ sự đấu tranh giai cấp, xã hội Giéc - mạnh vẫn tồn tại chế độ thị tộc, sự phân hóa giai cấp chỉ mới bắt đầu và còn mờ nhạt.

Sau khi Nhà nước Giéc mạnh ra đời và bước vào củng cố, hoàn thiện thì bộ máy Nhà nước, sự phân hóa giai cấp trong xã hội Giéc mạnh mới rõ rệt.

d. Sự ra đời của các Nhà nước Phương Đông cổ đại

Nguyên nhân thúc đẩy sự ra đời của các nhà nước phương Đông là do nhu cầu trị thủy và chống giặc ngoại xâm.

Do nhu cầu tự vệ, chống thiên tai và yêu cầu sản xuất như khai khẩn đất đai, trị thủy... đòi hỏi con người phải tập hợp lại trong một cộng đồng có sự liên hệ cao hơn gia đình và thị tộc. Xã hội khi đó chưa diễn ra sự phân hoá giai cấp rõ rệt, mâu thuẫn giai cấp chưa thực sự gay gắt.

Nhà nước Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập cổ đại,... được hình thành từ rất sớm, hơn 3000 năm trước công nguyên.

Ở Việt Nam, nhà nước xuất hiện vào khoảng thiên niên kỷ 2 trước công nguyên. Cũng như các nhà nước phương Đông khác, sự phân chia giai cấp trong xã hội cổ Việt Nam chưa đến mức gay gắt. Trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ, nhu cầu xây dựng, quản lý những công trình trị thủy đảm bảo nền sản xuất nông nghiệp và tổ chức lực lượng chống giặc ngoại xâm đã thúc đẩy quá trình liên kết các tộc người và hoàn thiện bộ máy quản lý. Kết quả này đã cho ra đời nhà nước Việt Nam đầu tiên - Nhà nước Văn Lang của các Vua Hùng rồi đến Nhà nước sơ khai thời An Dương Vương –Âu Lạc năm 208 trước công nguyên.

Tóm lại: Nguyên nhân trực tiếp của sự xuất hiện nhà nước là *mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được*. V.I.Lênin nhận định: “Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những môi trường giai cấp không thể điều hoà được. Bất cứ ở

đâu, hễ lúc nào và chừng mực nào mà về mặt khách quan, những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được thì nhà nước xuất hiện”².

Định nghĩa: Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị.

1.1.2. Bản chất của Nhà nước

1.1.2.1. Các dấu hiệu đặc trưng (các thuộc tính) của Nhà nước

a. Nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị công đặc biệt, có bộ máy chuyên thực hiện cưỡng chế và quản lý những công việc chung của xã hội.

Nhà nước là tổ chức công quyền thiết lập một quyền lực đặc biệt không còn hòa nhập với dân cư như trong xã hội thị tộc mà “đường như” tách rời và đứng lên trên xã hội. Quyền lực trong xã hội không thuộc về xã hội mà thuộc về giai cấp thống trị. Và để thực hiện quyền lực công cộng cần có một lớp người đặc biệt chuyên làm nhiệm vụ quản lý và cưỡng chế.

Nhà nước tổ chức một bộ máy quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng chế đối với mọi thành viên trong xã hội. Khác với các cơ quan điều hành công việc chung trong thị tộc, bộ lạc, nhà nước của giai cấp thống trị nào cũng có một bộ máy quyền lực chuyên nghiệp. Bộ máy quyền lực đó bao gồm các lực lượng vũ trang đặc biệt (quân đội, cảnh sát, nhà tù, v.v.) và bộ máy quản lý hành chính (cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quan lại nhà sai....) mà xã hội thị tộc, bộ lạc không hề biết đến trước đó. Nhà nước thực hiện quyền lực của mình trên cơ sở sức mạnh cưỡng chế của pháp luật và dùng các thiết chế (tổ chức) bạo lực để pháp luật của mình được thực thi trong thực tế quản lý.

b. Nhà nước phân chia dân cư theo lãnh thổ

Nếu trong xã hội cộng sản nguyên thủy, tổ chức thị tộc tập hợp các thành viên của mình theo huyết thống thì nhà nước lại phân chia dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ không phụ thuộc vào huyết thống, nghề nghiệp hoặc giới tính. Việc phân chia này dẫn đến việc hình thành các cơ quan quản lý trên từng đơn vị hành chính lãnh thổ. Lãnh thổ là dấu hiệu đặc trưng riêng có của nhà nước, nhà nước thực thi quyền lực thống trị trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ. Nhà nước nào cũng có lãnh thổ riêng, trên lãnh thổ đó được phân thành các đơn vị hành chính như tỉnh, huyện, xã hoặc tỉnh, khu tự trị, đặc khu, quận, hạt,...

Do có dấu hiệu lãnh thổ mà xuất hiện chế độ quốc tịch. Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

² V.I.Lênin: Toàn tập, Nhà xuất bản. Tiến bộ, Mátxcova, năm 1976, tập 33, trang 9.

Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam.

Việt Nam hiện nay được phân chia thành 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh), trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm: Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dưới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) và dưới cấp huyện có xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).



Hình 1.1. Bản đồ 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam

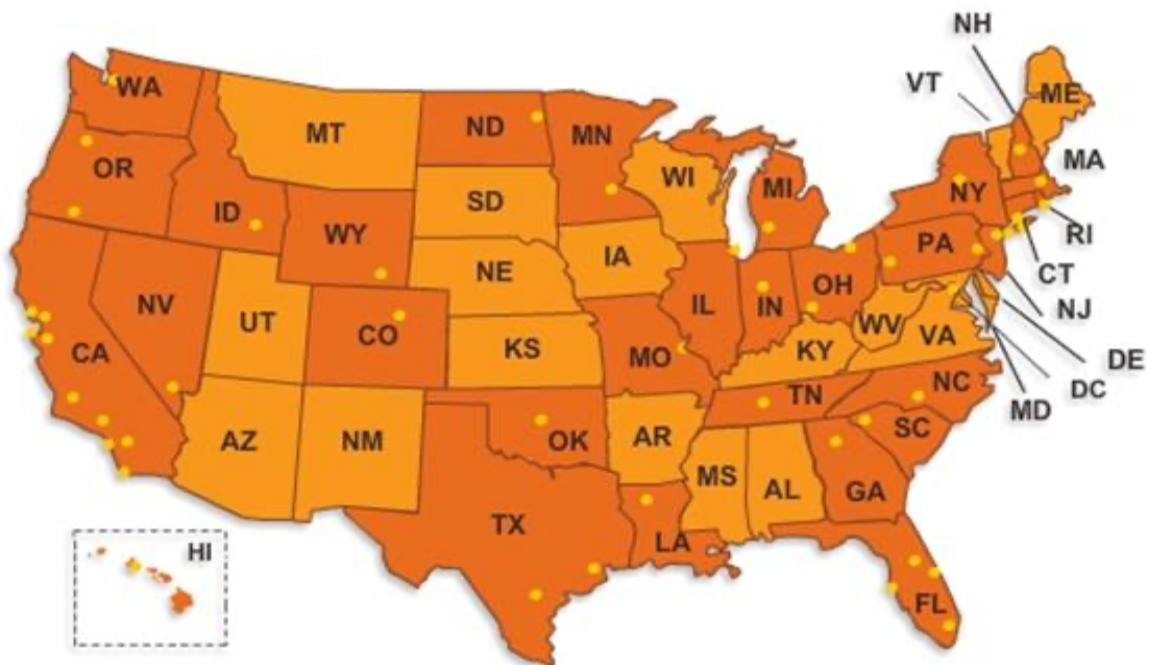
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện có 33 đơn vị hành chính cấp tỉnh, không kể Đài Loan, gồm:

22 tỉnh. Đài Loan (Trung Hoa Dân quốc) được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa coi là tỉnh thứ 23 của mình, 5 Khu tự trị, 2 Đặc khu hành chính, 4 thành phố trực thuộc trung ương là:

- Bắc Kinh (thủ đô),

- Thượng Hải (thủ đô kinh tế),
- Trùng Khánh (thành phố có diện tích lớn nhất và đông dân nhất)
- Thiên Tân.

Phân cấp hành chính Hoa Kỳ: Hoa Kỳ là một quốc gia theo hình thức chính phủ liên bang nên đơn vị hành chính chủ yếu sau liên bang là tiểu bang. Một tiểu bang (*U.S. state*) là một trong số 50 bang "tạo thành" Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Mỗi tiểu bang chia sẻ chủ quyền của mình với chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Các tiểu bang được xem là các thực thể có chủ quyền, quyền lực của các tiểu bang đến trực tiếp từ người dân trong các tiểu bang đó chứ không phải từ chính phủ liên bang. Do đó, tổ chức hành chính địa phương của Hoa Kỳ được qui định bởi luật pháp của từng tiểu bang và do sự khác biệt trong luật pháp của các tiểu bang nên tổ chức hành chính địa phương của Hoa Kỳ rất phức tạp và đa dạng.



Hình 1.2: Bản đồ các tiểu bang của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Đa số các tiểu bang phân chia việc thực thi chủ quyền thông thường qua ba phân cấp hành chính. Phân cấp thứ nhất là chính quyền cấp toàn tiểu bang. Phân cấp thứ hai là chính quyền hạt (County), đây là đơn vị hành chính phổ quát tại hầu hết các tiểu bang. Phân cấp thứ ba thường là các chính quyền đô thị (Municipality), hay thị xã (Township) tên gọi tùy theo tiểu bang. Các khu định cư nhỏ, ít dân nằm xa cách các khu đô thị và các thị xã thường được tổ chức thành các chính quyền thị trấn (Town) hay làng (Village). Ngoài ra, còn có hai thực thể hành chính đặc trách các mục đích đặc biệt hay gọi tắt là Đặc khu, đó là các Đặc khu học chính và các Đặc khu chức năng chuyên biệt như đặc khu cứu hỏa, đặc khu cung cấp nước...

c. Nhà nước có chủ quyền

Nhà nước là một tổ chức quyền lực có chủ quyền. Chủ quyền quốc gia gồm quyền tối cao của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình (đối nội) và quyền độc lập của quốc gia trong quan hệ quốc tế (đối ngoại). Quyền tối cao của quốc gia ở trong nước thể hiện ở quyền lực đầy đủ để giải quyết mọi vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá... không có sự can thiệp từ phía các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế.

Quốc gia có chủ quyền đối với vùng trời, vùng biển, đất liền, hải đảo, trong lòng đất và thềm lục địa. Chủ quyền của quốc gia trên biển được quy định tại Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Công ước này đã quy định rõ về vùng biển tiếp giáp lãnh thổ quốc gia ven biển gồm: vùng nội thủy; vùng lãnh hải; vùng tiếp giáp lãnh hải; vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Quốc gia ven biển có chủ quyền đối với các vùng biển trên, cụ thể:

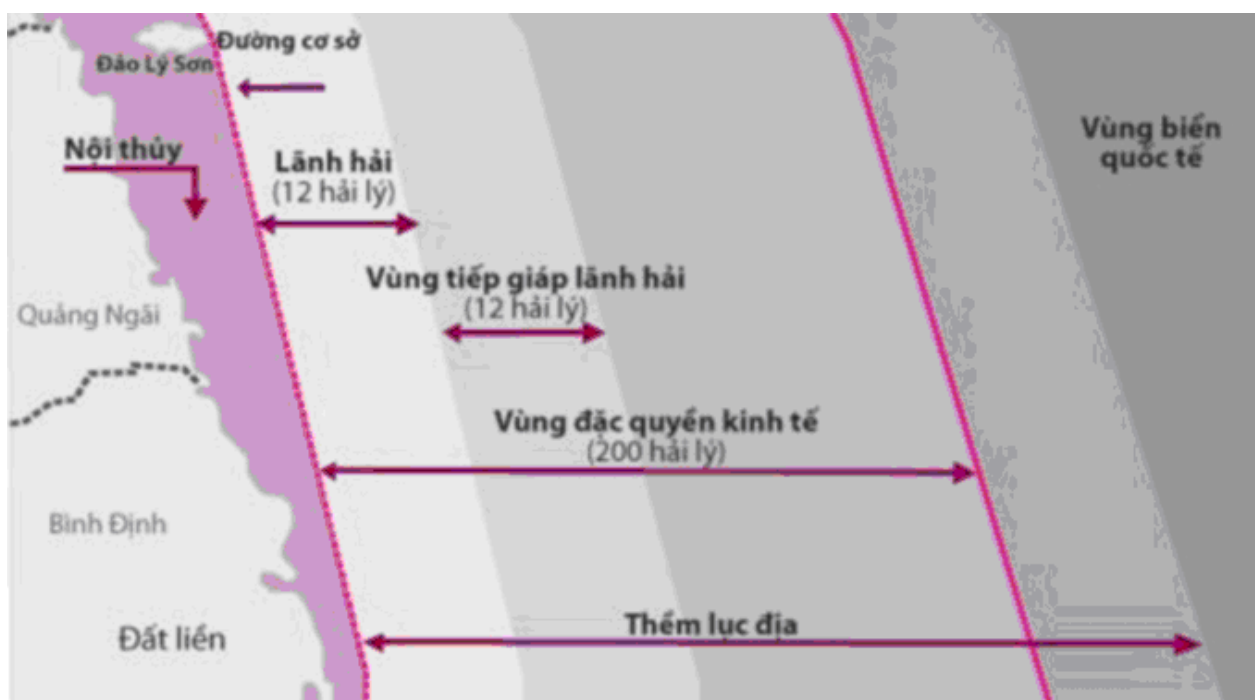
Vùng nội thủy: là vùng nước nằm phía bên trong của đường cơ sở của lãnh hải (quy định tại điều 2), bao gồm: các vùng nước cảng biển, các vùng tàu, cửa sông, các vịnh, các vùng nước nằm giữa lãnh thổ đất liền và đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải. Tại vùng nội thủy quốc gia ven biển thực hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ như trên lãnh thổ đất liền.

Vùng lãnh hải: mỗi quốc gia đều có quyền ấn định chiều rộng lãnh hải của mình, chiều rộng này không vượt quá 12 hải lý kể từ đường cơ sở. Ranh giới ngoài của lãnh hải là đường chạy song song với đường cơ sở và cách đều đường cơ sở một khoảng cách tối đa là 12 hải lý. Ranh giới ngoài của lãnh hải được coi là đường biên giới quốc gia trên biển.

Vùng tiếp giáp lãnh hải: là vùng biển nằm ngoài lãnh hải và tiếp giáp với lãnh hải, phạm vi của vùng tiếp giáp không vượt quá 24 hải lý tính từ đường cơ sở. Trong vùng tiếp giáp lãnh hải quốc gia ven biển thực hiện các thẩm quyền có tính riêng biệt và hạn chế đối với các tàu thuyền nước ngoài.

Vùng đặc quyền kinh tế: là vùng biển nằm ở phía ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải, đặt dưới một chế độ pháp lý riêng, theo đó các quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển cũng như các quyền và các quyền tự do của các quốc gia khác đều do các quy định thích hợp của Công ước điều chỉnh.

Thềm lục địa của một quốc gia ven biển bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải của quốc gia đó, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền của quốc gia đó cho đến bờ ngoài của rìa lục địa, hoặc đến cách đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải 200 hải lý, khi bờ ngoài của rìa lục địa của quốc gia đó có khoảng cách gần hơn.



Hình 1.3: Sơ đồ minh họa năm vùng biển theo Công ước 1982

d. Nhà nước ban hành pháp luật và bảo đảm thực thi trên thực tế.

Với tư cách là đại diện cho xã hội, để quản lý đối với mọi công dân của đất nước, để quản lý các mặt của đời sống xã hội như kinh tế, văn hoá... Nhà nước ban hành pháp luật và đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế.

Nhà nước thông qua các cơ quan của mình hoặc các tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, Nhà nước ban hành pháp luật (Quốc hội thông qua hiến pháp, các đạo luật, các nghị quyết; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh, nghị quyết; Chính phủ ban hành nghị định; Các Bộ trưởng ban hành thông tư; ...)

Nhà nước và pháp luật có mối liên hệ chặt chẽ, tác động qua lại và phụ thuộc lẫn nhau; nhà nước không thể thực hiện được vai trò là người quản lý xã hội nếu không có pháp luật, ngược lại pháp luật phải thông qua nhà nước để ra đời. Trong xã hội có nhà nước chỉ có nhà nước mới có quyền ban hành pháp luật và nhà nước có khả năng bảo đảm cho pháp luật được thực thi trên thực tế thông qua hoạt động của các cơ quan hành pháp (Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp) và tư pháp (Tòa án, Viện Kiểm sát các cấp).

đ. Nhà nước quy định, tiến hành thu các loại thuế và thực hiện các chính sách tài chính, tiền tệ.

- Khi Nhà nước ra đời, Nhà nước đã đặt ra chế độ thuế do dân cư đóng góp để hình thành quỹ tiền tệ của mình (chi trả cho các hoạt động của bộ máy Nhà nước, đầu tư cho hạ tầng, giải quyết các vấn đề xã hội và để tích lũy).

+ Tất cả mọi hoạt động của chính quyền cần phải có nguồn tài chính để chi, nguồn đầu tiên là các khoản thu từ thuế.

+ Thuế là công cụ rất quan trọng để chính quyền can thiệp vào sự hoạt động của nền kinh tế bao gồm cả nội thương và ngoại thương.

+ Chính quyền cung ứng các hàng hóa công cộng cho công dân nên công dân phải có nghĩa vụ ủng hộ tài chính cho chính quyền (ở Việt Nam và nhiều nước có thuật ngữ "nghĩa vụ thuế").

+ Giữa các nhóm công dân có sự chênh lệch về thu nhập và do đó là chênh lệch về mức sống, nên chính quyền sẽ đánh thuế để lấy một phần thu nhập của người giàu hơn và chia cho người nghèo hơn (thông qua cung cấp hàng hóa công cộng).

+ Chính quyền có thể muốn hạn chế một số hoạt động của công dân vì lợi ích cộng đồng (ví dụ hạn chế vi phạm luật giao thông, vì sức khỏe cộng đồng nên hạn chế hút thuốc lá, hạn chế uống rượu) nên đánh thuế cao vào các mặt hàng này.

+ Chính quyền cần khoản chi tiêu cho các khoản phúc lợi xã hội (trợ cấp xã hội cho đối tượng chính sách, xây dựng cầu cống, làm đường, xây dựng bệnh viện, trường học...) và phát triển kinh tế.

- Thống nhất một chính sách tiền tệ quốc gia cũng là quyền thuộc về Nhà nước. Chính sách tiền tệ quốc gia là một bộ phận của chính sách kinh tế tài chính của Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống của nhân dân (Nhà nước quy định lãi suất huy động và lãi suất cho vay theo từng thời kỳ, quy định tỷ giá giữa đồng Việt Nam và các đồng ngoại tệ, quy định và kiểm soát việc kinh doanh vàng miếng...).

1.1.2.2. Bản chất giai cấp của Nhà nước

Nghiên cứu nguồn gốc ra đời của Nhà nước, Mác-Lênin khẳng định: *“Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được”*³.

*“Nhà nước là một bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác, và theo đúng nghĩa của nó, là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với một giai cấp khác”*⁴

Trong xã hội có giai cấp, sự thống trị giai cấp xét về nội dung thể hiện ở 3 mặt: kinh tế, chính trị và tư tưởng. Bằng Nhà nước, giai cấp thống trị về kinh tế trở thành giai cấp thống trị về chính trị, ý chí của giai cấp thống trị được thể hiện một cách tập trung và biến thành ý chí Nhà nước, bắt buộc mọi thành viên trong

³ V.I.Lênin: Toàn tập, Nhà xuất bản. Tiến bộ, Mátxcova, năm 1976, tập 33, trang 9.

⁴ C.Mác và Ăng ghen: Tuyển tập: tập 6, Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội, năm 1984, trang 413.

xã hội phải tuân theo, các giai cấp, các tầng lớp dân cư phải hành động trong một giới hạn và trật tự phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị.

Do nắm được quyền lực Nhà nước, hệ tư tưởng của giai cấp thống trị biến thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội. Trong các xã hội bóc lột, Nhà nước có thuộc tính chung là bộ máy đặc biệt duy trì sự thống trị về kinh tế, chính trị, tư tưởng của thiểu số đối với đa số là nhân dân lao động, thực hiện nền chuyên chính của giai cấp bóc lột. Nhà nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) là Nhà nước kiểu mới, là công cụ thực hiện nền chuyên chính và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nhà nước XHCN là một bộ máy thống trị của đa số với thiểu số.

1.1.2.3. Bản chất xã hội của Nhà nước

Nhà nước ra đời và tồn tại trong xã hội với cơ cấu bao gồm giai cấp thống trị và các giai cấp, các tầng lớp dân cư khác, bản thân giai cấp thống trị cũng chỉ tồn tại trong mối quan hệ với các giai cấp, các tầng lớp dân cư khác. Do vậy, Nhà nước ngoài tính cách là công cụ duy trì sự thống trị và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị còn phải là một tổ chức quyền lực công, bảo đảm lợi ích chung của xã hội. Nhà nước không chỉ phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị mà đứng ra giải quyết những vấn đề nảy sinh từ trong đời sống xã hội, bảo đảm trật tự chung, bảo đảm các giá trị chung của xã hội. Như vậy, Nhà nước không chỉ bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền mà còn phải bảo đảm lợi ích của các giai tầng khác trong xã hội khi mà những lợi ích đó không mâu thuẫn căn bản với lợi ích của giai cấp thống trị.

Tuy nhiên, tính xã hội của Nhà nước còn tùy thuộc vào bản chất giai cấp của Nhà nước. Trong các nhà nước bóc lột, mặt giai cấp và mặt xã hội hầu như luôn đối lập nhau, vai trò xã hội ít được bộc lộ. Còn trong nhà nước XHCN, tính giai cấp và tính xã hội luôn hòa quyện vào nhau tạo thành một thể thống nhất vì trong xã hội có giai cấp, trong giai cấp có xã hội. Chúng là hai mặt của một vấn đề bởi vì lợi ích cơ bản của các giai cấp, các tầng lớp là thống nhất.

Trong tương lai, Nhà nước sẽ ngày càng nhỏ đi và các tổ chức xã hội sẽ rộng và lớn hơn. Xã hội sẽ đảm nhiệm các công việc của Nhà nước. Trong quá trình phát triển thời bình tính xã hội sẽ nổi bật hơn, trước đây nhà nước chăm lo cho con người về phương diện chính trị (vào đội, đoàn, đảng,...) hiện nay chú trọng phương diện xã hội (an sinh xã hội).

1.1.3. Các kiểu nhà nước

1.1.3.1. Khái niệm

Nhà nước là thực thể xã hội tồn tại trong lịch sử. Học thuyết Mác-Lênin đã phân chia các Nhà nước trong lịch sử thành các kiểu khác nhau. Trong đó, kiểu nhà nước được hiểu là tổng thể các dấu hiệu cơ bản của Nhà nước, thể hiện bản

chất, vai trò xã hội, những điều kiện, phát sinh, tồn tại và phát triển của Nhà nước trong hình thái kinh tế-xã hội nhất định.

Từ khi phân chia thành các giai cấp đến nay, xã hội loài người đã và đang trải qua bốn hình thái kinh tế - xã hội là chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư sản và XHCN. Theo các hình thái kinh tế - xã hội đã nêu, có bốn kiểu Nhà nước là: Nhà nước Chủ nô, Nhà nước Phong kiến, Nhà nước Tư sản, Nhà nước XHCN.

1.1.3.2. Các kiểu Nhà nước tồn tại trong lịch sử

Nhà nước là bộ phận quan trọng nhất trong kiến trúc thượng tầng xã hội, khi hạ tầng cơ sở thay đổi, các quan hệ kinh tế mới tiến bộ hơn thay thế các quan hệ kinh tế cũ đã lạc hậu, kéo theo sự thay đổi kiểu Nhà nước thông qua các cuộc cách mạng xã hội. Như vậy, sự thay thế các kiểu Nhà nước trong lịch sử gắn liền và là biểu hiện của sự thay đổi các hình thái kinh tế - xã hội.

Các Nhà nước có sự khác biệt rất lớn về hoàn cảnh ra đời, cơ sở kinh tế, cơ sở xã hội và bản chất.

a. Nhà nước chủ nô

Nhà nước chủ nô là kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử, ra đời khi chế độ thị tộc - bộ lạc tan rã, tư hữu tài sản xuất hiện, sự phân hóa xã hội thành giai cấp và mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được. Cơ sở kinh tế của nhà nước chủ nô là chế độ sở hữu chủ nô đối với tư liệu sản xuất, sản phẩm lao động và người nô lệ. Trong xã hội chiếm hữu nô lệ có hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ, ngoài ra còn có tầng lớp thợ thủ công và những người lao động tự do khác. Chủ nô là một bộ phận thiểu số của xã hội nhưng nắm trong tay toàn bộ tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội, còn nô lệ là lực lượng chủ yếu sản xuất ra của cải vật chất nhưng chỉ là “công cụ biết nói” trong tay chủ nô, phụ thuộc hoàn toàn vào chủ nô. Tầng lớp thợ thủ công và những người lao động tự do có địa vị khác với người nô lệ nhưng vẫn trong quỹ đạo chi phối của chủ nô về chính trị, kinh tế, tư tưởng.

Nhà nước chủ nô, xét về bản chất, là công cụ bạo lực để thực hiện nền chuyên chính của giai cấp chủ nô, duy trì sự thống trị và bảo vệ lợi ích của chủ nô, đàn áp nô lệ và những người lao động khác. Nhà nước chủ nô thực hiện bảo vệ và củng cố chế độ sở hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất, sản phẩm lao động và người nô lệ, đàn áp sự phản kháng của nô lệ và các tầng lớp khác bằng bạo lực, củng cố hệ tư tưởng tôn giáo và sử dụng nó để thống trị về mặt tư tưởng đối với xã hội. Trong một mức độ nhất định, nhà nước chủ nô cũng tổ chức một số hoạt động kinh tế như quản lý đất đai, tổ chức khai hoang, xây dựng và quản lý các công trình thủy nông... Chức năng đối ngoại nổi bật của nhà nước chủ nô là tiến hành chiến tranh xâm lược, bằng chiến tranh, giai cấp chủ nô thực hiện khát vọng làm giàu, cướp bóc của cải, bắt tù binh để bổ sung vào đội quân nô lệ và mở rộng phạm vi thống trị.

b. Nhà nước phong kiến

Khi quan hệ chiếm hữu nô lệ bộc lộ sự lạc hậu và lỗi thời so với sự phát triển của lực lượng sản xuất đã kìm hãm mạnh mẽ sự phát triển xã hội, mâu thuẫn giai cấp giữa chủ nô và nô lệ ngày càng gay gắt, khởi nghĩa của nô lệ xảy ra liên tiếp. Lao động của người nông dân trên đất đai của các chúa đất đưa lại năng suất cao hơn lao động của nô lệ và dần dần đã thay thế lao động của nô lệ, chế độ phong kiến thay thế chế độ chiếm hữu nô lệ. Ở châu Âu, nhìn chung nhà nước phong kiến ra đời khi chế độ chiếm hữu nô lệ sụp đổ, nhưng với dân tộc Giécmanh (châu Âu) và một số dân tộc khác như Triều tiên, Mông Cổ, Việt Nam (Châu Á), nhà nước phong kiến là nhà nước đầu tiên. Nhà nước phong kiến là kiểu nhà nước bóc lột nhưng có những tiến bộ hơn so với kiểu nhà nước chủ nô.

Cơ sở kinh tế của nhà nước phong kiến là chế độ sở hữu của giai cấp địa chủ phong kiến đối với tư liệu sản xuất mà chủ yếu là ruộng đất, người nông dân không có hoặc có rất ít ruộng đất nên phải phụ thuộc vào địa chủ phong kiến.

Cơ cấu giai cấp trong xã hội phong kiến phức tạp, địa chủ và nông dân là hai giai cấp chính, ngoài ra trong xã hội còn có tầng lớp thợ thủ công, thương nhân... Ngay giai cấp địa chủ phong kiến cũng được chia ra nhiều đẳng cấp với những đặc quyền khác nhau về sở hữu ruộng đất, vua hay quốc vương là những thứ bậc cao nhất trong hệ thống các thứ bậc, đẳng cấp của xã hội phong kiến. Các đẳng cấp phong kiến ở Châu Âu như công, hầu, bá, tử, nam... đều gắn liền với những mức độ khác nhau về số lượng điền trang, thái ấp mà họ chiếm hữu.

Địa vị của người nông dân trong xã hội phong kiến có ưu thế hơn so với địa vị của người nô lệ nhưng chưa có sự khác biệt rõ rệt. Nông dân có kinh tế cá thể, được sở hữu nhà cửa, công cụ lao động, sức kéo, ruộng đất (thường với số lượng ít) nên họ quan tâm đến sản xuất và hiệu quả lao động. Địa chủ phong kiến không có quyền định đoạt tính mạng của người nông dân như trong chế độ chiếm hữu nô lệ. Sống trên các lãnh địa của phong kiến, người nông dân bị bóc lột dưới hình thức nộp tô bằng hiện vật (thóc, gạo, vật nuôi...) hoặc bằng tiền, ngoài ra còn bị cưỡng bức lao động cho phong kiến. Mức độ phụ thuộc của người nông dân vào địa chủ phong kiến có khác nhau ở các nước và trong các giai đoạn cụ thể của nhà nước phong kiến.

Về bản chất, nhà nước phong kiến là công cụ trong tay địa chủ phong kiến để thực hiện chuyên chính đối với giai cấp nông dân, những người thợ thủ công và các tầng lớp lao động khác, là phương tiện duy trì địa vị kinh tế, bảo vệ lợi ích và sự thống trị của giai cấp địa chủ phong kiến. Nhà nước phong kiến bảo vệ chế độ sở hữu ruộng đất của địa chủ phong kiến, duy trì các hình thức bóc lột với nông dân và các tầng lớp lao động khác, đàn áp sự chống đối của những người lao động bằng bạo lực và đàn áp tư tưởng, tuyên truyền hệ tư tưởng phong kiến, nô dịch

các tầng lớp lao động bằng hệ tư tưởng tôn giáo và hệ thống tổ chức tôn giáo (thiên chúa giáo, phật giáo,...). Nhà nước phong kiến có thực hiện những hoạt động kinh tế nhưng với mức độ hạn chế. Về đối ngoại, nhà nước phong kiến tiến hành chiến tranh xâm lược, mở rộng đất đai - lãnh thổ, cướp bóc của cải và phòng thủ chống bành trướng, xâm lược.

c. Nhà nước tư sản

Do sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội và sự hình thành quan hệ tư bản trong lòng xã hội phong kiến, quan hệ sản xuất phong kiến trở nên lỗi thời, kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất, chế độ phong kiến rơi vào tình trạng khủng hoảng toàn diện. Đại diện cho phương thức sản xuất mới tiến bộ, giai cấp tư sản có những ưu thế rõ rệt so với giai cấp địa chủ phong kiến. Khi giành được vị trí chủ đạo trong kinh tế, giai cấp tư sản đã tập hợp lực lượng tiến hành cuộc đấu tranh giành quyền lực chính trị, thủ tiêu chế độ phong kiến, thiết lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, mở đường cho sức sản xuất phát triển.

Sự ra đời của nhà nước tư sản đánh dấu sự tiến bộ to lớn trong lịch sử phát triển của nhân loại, trong giai đoạn đầu nhà nước tư sản có vai trò tích cực trong việc giải phóng xã hội khỏi trật tự phong kiến, giải phóng lực lượng sản xuất xã hội, đưa đến bước phát triển nhảy vọt của xã hội loài người. Nhà nước tư sản là kiểu nhà nước bóc lột cuối cùng trong lịch sử, là công cụ duy trì nền thống trị của giai cấp tư sản đối với các tầng lớp nhân dân lao động.

Cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản là quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ tư hữu tư bản về tư liệu sản xuất và bóc lột giá trị thặng dư. Đối tượng sở hữu của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa chủ yếu là công xưởng, hầm mỏ, nhà máy, đồn điền với những phương thức bóc lột giá trị thặng dư.

Cơ cấu giai cấp trong xã hội tư sản gồm hai giai cấp chính là tư sản và vô sản, đây là cơ sở xã hội của nhà nước tư sản. Nằm trong tay những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội, giai cấp tư sản giữ vai trò thống trị xã hội. Về phương diện pháp lý, giai cấp vô sản được tự do nhưng không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động và trở thành người làm thuê cho giai cấp tư sản, chịu sự bóc lột của giai cấp tư sản. Cùng với sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp vô sản đã lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Ngoài giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, trong xã hội tư sản còn có giai cấp nông dân, tầng lớp tiểu tư sản và trí thức... Tôn giáo trong xã hội tư sản có vai trò quan trọng nhưng không còn là quốc giáo như trong xã hội phong kiến, nhà thờ tách khỏi nhà nước, tín ngưỡng là công việc của các cá nhân. Nhà nước tư sản đặc biệt chú trọng truyền bá hệ tư tưởng tư sản, bảo đảm sự thống trị của hệ tư tưởng này trong xã hội, ngăn cản sự phát triển của các tư tưởng tiến bộ và cách mạng.

d. Nhà nước Xã hội chủ nghĩa

Vào nửa cuối thế kỷ 19 quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã bộc lộ tính trì trệ, kìm hãm sự phát triển sản xuất xã hội, không phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất đã phát triển đến mức xã hội hóa cao, mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và lực lượng sản xuất ngày càng gay gắt đòi hỏi phải xóa bỏ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, xác lập kiểu quan hệ sản xuất mới phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đó chính là quan hệ sản xuất dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất - quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Xây dựng quan hệ sản xuất kiểu mới cũng có nghĩa là thay thế phương thức sản xuất của xã hội, thay thế hình thái kinh tế - xã hội cũ bằng hình thái kinh tế - xã hội mới và tất yếu dẫn đến sự thay thế kiểu nhà nước tư sản bằng nhà nước kiểu mới – nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đây là tiền đề kinh tế cho sự ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Về mặt xã hội, do nhu cầu tích lũy tư bản, tìm kiếm lợi nhuận cao, giai cấp tư sản đã thực hiện sự bóc lột dã man và đẩy giai cấp vô sản đến chỗ bần cùng hóa, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản và những người lao động khác ngày càng gay gắt. Cùng với sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp vô sản lớn mạnh không ngừng về số lượng và chất lượng. Là đại biểu cho phương thức sản xuất mới, giai cấp vô sản ý thức được vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình là lãnh đạo quần chúng lao động tiến hành cách mạng xã hội, lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản, giải phóng mình và các tầng lớp nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, thiết lập nhà nước kiểu mới của những người lao động - nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Về mặt tư tưởng và chính trị, những thành tựu vĩ đại mà khoa học tự nhiên thu được đã mở ra khả năng nhận thức đúng đắn hơn bản chất của sự vận động và phát triển của thế giới khách quan. Trên cơ sở đó và tổng kết một cách khoa học lịch sử phát triển của loài người, các lãnh tụ tư tưởng của giai cấp vô sản đã sáng lập ra chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, học thuyết này là vũ khí tư tưởng khoa học để giai cấp công nhân tổ chức và tiến hành cách mạng vô sản, xây dựng một chế độ xã hội văn minh. Sự phát triển của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân đòi hỏi phải có một tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo, vì thế Đảng cộng sản của giai cấp công nhân được thành lập và trở thành hạt nhân lãnh đạo quần chúng nhân dân lao động trong sự nghiệp đấu tranh xóa bỏ chế độ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.

Những tiền đề nói trên là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Giai cấp công nhân liên hiệp với các tầng lớp nhân dân lao động bị áp bức dưới sự lãnh đạo của các chính đảng vô sản phải tiến hành cách mạng xã hội, sử dụng bạo lực cách mạng đập tan bộ máy nhà nước bóc lột, thiết lập nhà nước kiểu mới. Sau khi lật đổ nhà nước bóc lột, xây dựng nhà nước xã hội chủ

nghĩa dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, toàn thể nhân dân lao động phải bảo vệ chính quyền của mình, hoàn thiện nó và sử dụng chính quyền ấy để tổ chức, xây dựng một xã hội không có áp bức, bóc lột, bình đẳng, tự do và nhân đạo – xã hội chủ nghĩa và tiến đến xã hội cộng sản văn minh.

1.1.4. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1.1.4.1. Khái niệm bộ máy nhà nước

Nhà nước là tổ chức quyền lực, chính trị của xã hội có giai cấp, có lãnh thổ, dân cư và chính quyền độc lập, có khả năng đặt ra và thực thi pháp luật nhằm thiết lập trật tự xã hội nhất định trong phạm vi lãnh thổ của mình. Để thực hiện tốt chức năng của nhà nước, cần có một bộ máy quyền lực công được tổ chức chặt chẽ, khoa học. Bộ máy nhà nước là hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương xuống địa phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất, tạo thành một cơ cấu đồng bộ để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước.

Bộ máy nhà nước ở nước ta hiện nay được tổ chức và hoạt động dựa trên các nguyên tắc chung nhất định, bộ máy nhà nước thực chất chỉ là các cơ quan đại diện cho nhân dân, đảm bảo các quyền lợi cho nhân dân. Về bản chất thì người dân có quyết định ra quyết định trong mọi vấn đề của đất nước, các công việc liên quan đến chính trị, tư tưởng, văn hóa. Người dân thực hiện các quyền làm chủ này thông qua hoạt động của các cơ quan nhà nước hoặc trực tiếp tiến hành như trong các đợt bầu cử đại biểu Quốc hội, người dân sẽ được đi bỏ phiếu lựa chọn cho đại biểu mà mình tín nhiệm.

Chế định Nhà nước được quy định trong các bản hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của nhà nước, do quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành, xác định những vấn đề cơ bản, quan trọng nhất của nhà nước và xã hội. Kể từ năm 1945 đến nay, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trải qua các Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 dựa trên những quan điểm và nguyên tắc nhất định. Dựa trên Hiến pháp năm 2013, có thể nêu một số các quan điểm và nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước như sau: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; Nhà nước đại diện cho nhân dân thực hiện quản lý thống nhất mọi mặt hoạt động của đời sống xã hội trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, đối ngoại.

Để thực hiện những nhiệm vụ trên, hệ thống các cơ quan nhà nước được lập ra. Mỗi cơ quan nhà nước là một bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, đảm nhận những chức năng, nhiệm vụ nhất định của nhà nước, có cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động phù hợp với tính chất các chức năng, nhiệm vụ được

giao. Cùng với những chức năng, nhiệm vụ, nhà nước còn trao cho các cơ quan những thẩm quyền tương ứng. Các cơ quan nhà nước sử dụng thẩm quyền vào việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, hoạt động của các cơ quan nhà nước đều hướng tới phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ, chức năng của nhà nước.

1.1.4.2. Các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước

Các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Bộ máy nhà nước là những tư tưởng chỉ đạo làm nền tảng cho tổ chức và hoạt động của tất cả các cơ quan Nhà nước và toàn bộ Bộ máy nhà nước. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước tùy thuộc vào tính chất các nhiệm vụ được giao, nhưng đều theo nguyên tắc chung thống nhất như sau:

a) Nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Đây là nguyên tắc thể hiện bản chất nhân dân của nhà nước ta. Tất cả nhân dân không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính đều có quyền thông qua đầu phiếu phổ thông bầu ra các đại biểu thay mặt mình vào các cơ quan quyền lực nhà nước là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, thực thi quyền lực nhà nước. Nguyên tắc này bắt nguồn từ bản chất của Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhân dân tham gia tổ chức nhà nước, quản lý nhà nước, thực hiện quyền lực nhà nước, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nòng cốt là công nhân, nông dân và trí thức.

Để sử dụng quyền lực nhà nước một cách có hiệu quả, Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành lập ra các cơ quan nhà nước khác để thực hiện những quyền lực nhà nước nhất định, đồng thời giám sát việc thực hiện quyền lực đó. Quốc hội thành lập ra Chính phủ – cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Quốc hội bầu ra Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện KSND Tối cao. Ở địa phương, Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra để thực hiện quyền hành pháp ở địa phương.

Trong thực tiễn tổ chức bộ máy nhà nước, tuy chỉ Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là các cơ quan mà thành viên của cơ quan này do Nhân dân trực tiếp bầu ra nhưng điều đó không có nghĩa rằng chỉ có các cơ quan này mới là các cơ quan được Nhân dân ủy thác quyền lực. Nguyên tắc “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân” hàm ý rằng, quyền lực nhà nước do các cơ quan nhà nước khác thực hiện (dù đó là cơ quan thực hiện quyền hành pháp, cơ quan thực hiện quyền tư pháp hay bất cứ cơ quan nhà nước nào khác) cũng là sản phẩm của sự trao quyền một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ Nhân dân (thông qua Hiến pháp và pháp luật).

Tinh thần đó đòi hỏi, trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, bất kể là cơ quan thực hiện quyền lập pháp (Quốc hội), cơ quan thực hiện quyền hành pháp (Chính phủ), cơ quan thực hiện quyền tư pháp (Tòa án nhân dân) và các cơ quan nhà nước khác trong bộ máy nhà nước đều phải bảo đảm tinh thần vì lợi ích của Nhân dân để phục vụ.

Tất cả hoạt động của các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước đều đặt dưới sự giám sát tối cao của Quốc hội – cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân. Quyền lực tối cao cũng như hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước là cơ sở để đảm bảo tính thống nhất của quyền lực nhà nước, đảm bảo cho hoạt động của bộ máy nhà nước phục vụ cho lợi ích của nhân dân, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

b) Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội

Theo Điều 4 Hiến Pháp 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam: - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

Sự lãnh đạo của Đảng giữ vai trò quyết định đối với việc xác định phương hướng hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, là điều kiện quyết định để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng là sự lãnh đạo chính trị thông qua việc đề ra đường lối, chủ trương, phương hướng lớn, những vấn đề quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước.

c) Nguyên tắc tập trung dân chủ

Đây là một nguyên tắc tổ chức được xác định tại Hiến pháp 2013, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước. Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nguyên tắc tập trung dân chủ còn thể hiện thông qua việc phải thường xuyên kiểm tra cấp dưới, thực hiện thường xuyên chế độ thông tin báo cáo, kiên quyết đấu tranh với thói tập trung quan liêu, bệnh tự do, vô tổ chức, vô chính phủ.

d) Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đối với quyền lập pháp là quyền đại diện cho nhân dân thể hiện ý chí chung của quốc gia. Những người được nhân dân trao cho quyền này là những người do phổ thông đầu phiếu bầu ra hợp thành cơ quan hội là Quốc hội. Quyền hành pháp là quyền tổ chức thực hiện ý chí chung của quốc gia do Chính phủ đảm trách. Thuộc tính cơ bản, xuyên suốt mọi hoạt động của quyền này là đề xuất, hoạch định, tổ chức soạn thảo chính sách quốc gia và sau khi chính sách quốc gia được thông qua là người tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước mà thực chất là tổ chức thực hiện pháp luật để bảo đảm an ninh, an toàn và phát triển xã hội. Quyền tư pháp là quyền xét xử, được nhân dân giao cho Tòa án thực hiện. Độc lập và chỉ tuân theo pháp luật và nguyên tắc xuyên suốt và cao nhất trong tổ chức thực hiện quyền này, nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp và việc xét xử của thẩm phán và hội đồng nhân dân. Đây thực chất là quyền bảo vệ ý chí chung của quốc gia bằng việc xét xử các hành vi vi phạm Hiến pháp, pháp luật từ phía công dân và cơ quan nhà nước. Vì vậy, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân là nhiệm vụ hàng đầu của quyền tư pháp. Mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ tính pháp quyền và công lý trong các phán quyết của Tòa án.

e) Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa

Nội dung của nguyên tắc này thể hiện thông qua việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước phải tiến hành trên cơ sở của pháp luật, đúng pháp luật. Mọi cán bộ, nhân viên và nhân dân phải nghiêm chỉnh tôn trọng pháp luật trong mọi nhiệm vụ, quyền hạn. Việc tổ chức các cơ quan nhà nước phải dựa trên và tuân thủ những quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức, biên chế, quy trình thành lập...

1.1.4.3. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước

Các cơ quan Nhà nước là những thiết chế chủ yếu hợp thành bộ máy nhà nước. Mỗi cơ quan nhà nước đảm nhiệm những chức năng, nhiệm vụ xác định. Các cơ quan này có cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ được Nhà nước quy định.

Cơ quan nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước. Đặc điểm cơ bản của các cơ quan nhà nước là hoạt động của nó mang quyền lực nhà nước. Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích xã hội, hoạt động quyền lực đó mang tính cưỡng chế bằng bộ máy đặc biệt. Quyền lực của mỗi cơ quan nhà nước tùy thuộc vào vị trí, chức năng của cơ quan đó trong hệ thống cơ quan nhà nước và được thể chế hóa thành nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể trong pháp luật. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước tùy thuộc vào tính chất, nhiệm vụ, chức năng của nó, nhưng đều theo những nguyên tắc chung thống nhất.

Cùng với việc quyết định nhiệm vụ, chức năng, Nhà nước còn trao cho các cơ quan này những quyền hạn, thẩm quyền tương ứng để thực hiện các nhiệm vụ của mình. Như vậy, khác với các tổ chức trong xã hội, các cơ quan nhà nước là những tổ chức mang quyền lực Nhà nước, tức là trong phạm vi quyền hạn của mình, các cơ quan này được ban hành các VBPL có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phải đảm nhiệm, các cơ quan trong bộ máy nhà nước ta được phân thành:

- **Hệ thống các cơ quan đại diện (các cơ quan quyền lực nhà nước):** Bao gồm: Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã và cấp tương đương) do nhân dân trực tiếp bầu ra, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quản lý nhà nước (Cơ quan lập pháp).

- **Hệ thống các cơ quan chấp hành (các cơ quan quản lý nhà nước):** Bao gồm: Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các Ủy ban nhà nước, các cơ quan khác thuộc Chính phủ cũng như Ủy ban nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã và cấp tương đương) và các Sở, Phòng, Ban thuộc UBND.

Các cơ quan này dựa trên thẩm quyền luật định, có chức năng thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của Nhà nước (Cơ quan hành pháp)

- **Hệ thống các cơ quan xét xử:** Bao gồm: Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân các cấp (cấp tỉnh, thành phố, cấp huyện và tương đương), Tòa án quân sự (trung ương, quân khu và khu vực). Hệ thống các cơ quan xét xử được hình thành bằng con đường bầu cử và bổ nhiệm.

Xét xử là chức năng duy nhất của các tòa án và chỉ có tòa án mới có quyền xét xử.

- **Hệ thống các cơ quan kiểm sát:** Bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân các cấp (cấp tỉnh, thành phố, cấp huyện và tương đương), Viện kiểm sát Quân sự các cấp (trung ương, quân khu và khu vực). Hệ thống này được hình thành bằng con đường bổ nhiệm. Riêng đối với Viện trưởng VKSND tối cao do Quốc hội bầu và bãi miễn.

Các cơ quan kiểm sát có chức năng công tố và giám sát hoạt động tư pháp.

- Ngoài bốn hệ thống cơ quan nhà nước trên, trong tổ chức bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam còn có **Chủ tịch nước**. Chủ tịch nước là cá nhân, do Quốc hội bầu ra từ trong số các đại biểu quốc hội và đặt dưới sự giám sát của quốc hội. Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, là người đứng đầu Nhà nước thay mặt Nhà nước về mặt đối nội và đối ngoại.

- Chủ tịch nước là một chức vụ nhà nước, một cơ quan đặc biệt thể hiện sự thống nhất quyền lực, có những hoạt động thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp nên không xếp vào bất kỳ một loại cơ quan nào.

Tất cả các cơ quan nhà nước tạo thành bộ máy nhà nước. Nhưng bộ máy nhà nước không phải là một tập hợp đơn giản các cơ quan nhà nước, mà là một hệ thống thống nhất các cơ quan có mối liên hệ ràng buộc qua lại chặt chẽ với nhau vận hành theo một cơ chế đồng bộ.

Đặc điểm của cơ quan nhà nước:

- Các cơ quan nhà nước được thành lập theo trình tự nhất định được quy định trong pháp luật;

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền do pháp luật quy định;

- Hoạt động của cơ quan nhà nước mang tính quyền lực và được đảm bảo bằng quyền lực nhà nước, hoạt động đó được tuân theo thủ tục do pháp luật quy định;

- Những người đảm nhiệm chức trách trong các cơ quan nhà nước phải là công dân Việt Nam.

a) Quốc hội

Trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 05 năm, kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa đó đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa sau.

Thông qua lá phiếu tín nhiệm, nhân dân ủy thác quyền lực của mình cho Quốc hội. Thay mặt nhân dân Quốc hội quy định, thực hiện và bảo đảm thực hiện quyền lực thống nhất trong cả nước. Đây là cơ quan cao nhất của Nhà nước, thực hiện quyền lực nhân dân. Thông qua hoạt động của mình, Quốc hội thực hiện quyền lực của nhân dân thành ý chí của nhà nước, thể hiện trong Hiến pháp, luật, các nghị quyết, mang tính chất bắt buộc thực hiện chung đối với mọi thành viên trong xã hội.

** Quốc hội có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ bản sau đây:*

- Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật;

- Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội; xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;

- Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; các chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước;

- Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước;

- Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập;

- Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;

- Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt;

- Bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;

- Ngoài ra Quốc hội còn có các quyền hạn như: Quyết định đại xá; quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia; quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại,...

* *Cơ cấu tổ chức của Quốc hội* gồm: Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

- *Ủy ban Thường vụ Quốc hội*: Là cơ quan thường trực của Quốc hội, gồm có Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc Hội, các ủy viên, được lập ra tại kỳ họp thứ nhất mỗi khóa Quốc hội. Thành viên Ủy ban Thường vụ quốc hội không thể đồng thời là thành viên Chính phủ.

Ủy ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn cơ bản sau đây:

- + Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội; ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao; giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;

+ Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;

+ Đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ họp gần nhất; bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

+ Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; hướng dẫn và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội;

+ Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước;

+ Giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân; bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; giải tán Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân;

+ Ngoài ra Ủy ban thường vụ Quốc hội còn có những nhiệm vụ quyền hạn: Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh; quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương; tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội.

- Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội có vị trí đặc biệt trong tổ chức của Quốc hội, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội lãnh đạo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo chuẩn bị triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội nghị liên tịch giữa Chủ tịch hội đồng dân tộc và các Chủ nhiệm ủy ban Quốc hội để giải quyết những vấn đề liên quan và bàn chương trình hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội chủ tọa các phiên họp của Quốc hội, ký chứng thực luật, nghị quyết của

Quốc hội; chỉ đạo thực hiện công tác đối ngoại của Quốc hội; chỉ đạo thực hiện ngân sách của Quốc hội; đảm bảo thi hành quy chế đại biểu Quốc hội và giữ mối quan hệ với đại biểu Quốc hội.

- Hội đồng dân tộc:

Hội đồng dân tộc gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Chủ tịch Hội đồng dân tộc do Quốc hội bầu; các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc do Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Hội đồng dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội về công tác dân tộc; thực hiện quyền giám sát việc thi hành chính sách dân tộc, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc được mời tham dự phiên họp của Chính phủ bàn về việc thực hiện chính sách dân tộc. Khi ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc, Chính phủ phải lấy ý kiến của Hội đồng dân tộc.

- Ủy ban của Quốc hội

Các Ủy ban của Quốc hội được thành lập theo các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội nhằm giúp Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các Ủy ban của Quốc hội là hình thức thu hút các đại biểu vào việc thực hiện công tác chung của Quốc hội.

Nhiệm vụ của các Ủy ban Quốc hội là nghiên cứu thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, pháp lệnh và các dự án khác, những báo cáo được Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định; kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Ủy ban.

Cơ cấu của Ủy ban của Quốc hội gồm có Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các ủy viên, trong đó có một số thành viên hoạt động theo chế độ chuyên trách.

- Đại biểu Quốc hội

Là những người trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Tổng số đại biểu Quốc hội không quá năm trăm người, bao gồm đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu hoạt động không chuyên trách. Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là ba mươi lăm phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại biểu Quốc hội:

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách dành toàn bộ thời gian làm việc để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu tại cơ quan của Quốc hội hoặc tại Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương.

Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách phải dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu Quốc hội làm việc có trách nhiệm sắp xếp thời gian, công việc, tạo điều kiện cần thiết cho đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu.

Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm tham dự các phiên họp, tham gia các hoạt động khác của Hội đồng, Ủy ban; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc, Ủy ban mà mình là thành viên.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách có trách nhiệm tham gia hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và các hội nghị khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu tập.

Đại biểu Quốc hội liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử theo chương trình tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi làm việc; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm. Trong quá trình tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và Quốc hội; cử tri hoặc đại diện cử tri ở đơn vị bầu cử có thể góp ý kiến với đại biểu Quốc hội tại hội nghị cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương tổ chức trong trường hợp cần thiết.

Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu Quốc hội về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đúng pháp luật, đại biểu Quốc hội có quyền gặp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại; khi cần thiết, đại biểu Quốc hội yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó giải quyết.

Có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước. Có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu Quốc hội yêu cầu trong thời hạn luật định.

Đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị Quốc hội làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, trưng cầu ý dân, thành lập Ủy ban lâm thời của Quốc hội, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tổ chức phiên họp bất thường, phiên họp kín của Quốc hội và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu Quốc hội thấy cần thiết.

Kiến nghị của đại biểu Quốc hội được gửi bằng văn bản đến Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong đó nêu rõ lý do, nội dung kiến nghị. Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm tổng hợp, xử lý các kiến nghị của đại biểu Quốc hội theo thẩm quyền và báo cáo Quốc hội trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này hoặc trong các trường hợp khác mà Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy cần thiết.

Trường hợp có từ một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội trở lên kiến nghị Quốc hội làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, trưng cầu ý dân, thành lập Ủy ban lâm thời của Quốc hội, quyết định họp bất thường, họp kín hoặc có từ hai mươi phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội trở lên kiến nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với một người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn thì Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo để Quốc hội xem xét, quyết định.

Số lượng kiến nghị cần thiết quy định tại khoản 3 Điều này là tổng số kiến nghị mà Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp nhận được trong khoảng thời gian từ

ngày khai mạc kỳ họp này đến trước ngày khai mạc kỳ họp tiếp theo hoặc đến trước ngày tiến hành phiên họp của Quốc hội về nội dung có liên quan trong trường hợp đại biểu Quốc hội kiến nghị Quốc hội tổ chức phiên họp kín.

Đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để thực hiện Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Ngoài ra, các Đại biểu quốc hội còn có quyền yêu cầu khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, quyền yêu cầu cung cấp thông tin, quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân và một số quyền miễn trừ

b) Chủ tịch nước

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước. Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

** Chủ tịch nước có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ bản sau đây:*

Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;

Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;

Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá;

Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam;

Thông lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước.

c) Chính phủ

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

**** Thành phần Chính phủ***

Chính phủ có các Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu từ số đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ do Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Trong hoạt động của Chính phủ, chế độ trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân được quy định rõ. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch nước; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng mà Chính phủ phải giải quyết. Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, trước Quốc hội về lĩnh vực, ngành mình phụ trách.

Hiệu quả hoạt động của Chính phủ được đảm bảo bằng hiệu quả hoạt động của tập thể Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và từng thành viên Chính phủ.

Trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, tập thể Chính phủ ban hành nghị quyết, nghị định,; Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định, chỉ thị.

** Chính phủ có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ bản sau đây:*

Chính phủ thống nhất quản lý tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; lãnh đạo thống nhất bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương; đảm bảo thi hành Hiến pháp và Pháp luật; quản lý việc xây dựng kinh tế quốc dân, thực hiện chính sách tài chính tiền tệ quốc gia; quản lý về y tế, giáo dục; quản lý ngân sách nhà nước; thi hành các biện pháp cần thiết bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công dân; quản lý công tác đối ngoại; thực hiện chính sách xã hội... của nhà nước.

Khi thực hiện chức năng quản lý, điều hành các quá trình xã hội, hoạt động của Chính phủ chỉ tuân theo hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của các cơ quan quyền lực nhà nước.

Những quy định trên đảm bảo cho Chính phủ phát huy được vai trò là cơ quan đứng đầu thực hiện quyền hành pháp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, Chính phủ có toàn quyền giải quyết công việc với tính sáng tạo, chủ động, linh hoạt trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định...

Chính phủ có quyền tham gia vào hoạt động lập pháp bằng quyền trình dự án luật trước Quốc hội, dự án pháp lệnh trước Ủy ban Thường vụ quốc hội; trình Quốc hội các dự án kế hoạch, ngân sách nhà nước và các dự án khác.

Trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật: Ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản pháp luật để thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước và để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và của chính quyền địa phương; kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái Hiến pháp và pháp luật. Quyết định các biện pháp để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; chỉ đạo triển khai và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, nghị định, chương trình công tác của Chính phủ. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và các nguồn lực khác để thi hành Hiến pháp và pháp luật; thống nhất quản lý công tác hành chính tư pháp, hỗ trợ tư pháp, bồi thường nhà nước, thi hành án. Tổng hợp đánh giá tình hình thi hành Hiến

pháp, pháp luật và báo cáo với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước theo quy định của pháp luật.

Trong hoạch định chính sách và trình dự án luật, pháp lệnh: Đề xuất, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và các chương trình, dự án khác trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Quyết định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và các chương trình, dự án khác theo thẩm quyền. Xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội. Báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ý kiến của Chính phủ về các dự án luật, pháp lệnh do các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình.

Trong quản lý kinh tế và phát triển kinh tế: Thống nhất quản lý nhà nước nền kinh tế quốc dân, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; củng cố và phát triển kinh tế nhà nước; thúc đẩy liên kết kinh tế vùng; phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế, các nguồn lực xã hội để phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế quốc dân. Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường bình đẳng, cạnh tranh và hợp tác giữa các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế; tạo lập, phát triển đầy đủ, đồng bộ các yếu tố thị trường và bảo đảm vận hành có hiệu quả các loại thị trường. Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trình Quốc hội; quyết định chính sách cụ thể về tài chính, tiền tệ quốc gia, tiền lương, giá cả. Quyết định, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trình Quốc hội dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương hằng năm; quyết toán ngân sách nhà nước, quyết toán chương trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; tổ chức và điều hành thực hiện ngân sách nhà nước theo nghị quyết của Quốc hội. Báo cáo Quốc hội về tình hình tài chính nhà nước, các rủi ro tài khóa gắn với yêu cầu bảo đảm tính bền vững của ngân sách và an toàn nợ công. Quyết định chính sách cụ thể thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế về kinh tế, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với các tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, thực hiện chức năng chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật. Thống nhất quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực quốc gia; thống nhất quản lý việc sử dụng ngân sách nhà nước, các tài sản công khác và thực hiện các chế độ tài chính theo quy định của pháp luật trong các cơ quan nhà nước; thi hành chính sách tiết kiệm, chống lãng phí. Thống nhất quản lý hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế trên cơ sở phát huy nội lực của đất nước, phát triển các hình thức hợp tác kinh tế với các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và cùng có lợi,

hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất trong nước. Quyết định chính sách cụ thể khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế về kinh tế; khuyến khích đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước. Chỉ đạo, tổ chức và quản lý việc thực hiện công tác kế toán và công tác thống kê của Nhà nước.

Ngoài ra, Chính phủ còn thực hiện nhiệm vụ trong quản lý tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; quản lý văn hóa thể thao và du lịch; quản lý thông tin và truyền thông; quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân và dân số; thực hiện các chính sách xã hội; trong công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quản lý về quốc phòng; quản lý cơ yếu; quản lý về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân; đối ngoại và hội nhập quốc tế;...

d) Chính quyền địa phương

Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau:

Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương; huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã; quận chia thành phường.

Chính quyền địa phương tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên.

Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương.

Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định.

- Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên; đồng thời quyết định các vấn đề của địa phương do luật định.

Trong quá trình hoạt động, Hội đồng nhân dân chịu sự giám sát, hướng dẫn của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất thông qua Ủy ban thường vụ Quốc hội;

sự kiểm tra hướng dẫn của Chính phủ; chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Đại diện cho nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân căn cứ vào quyết định của cơ quan nhà nước ở trung ương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh nâng cao mức sống nhân dân, làm tròn nghĩa vụ đối với cả nước, giám sát hoạt động Thường trực của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, việc tuân theo Hiến pháp, luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân địa phương. Những nhiệm vụ, quyền hạn trên được cụ thể hóa ở từng lĩnh vực của đời sống xã hội trong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Để thực hiện những nhiệm vụ trên, Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết để định ra chủ trương, biện pháp lớn và giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân được thực hiện thông qua các hình thức hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân. Hình thức hoạt động chủ yếu là các kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

Kỳ họp của Hội đồng nhân dân là hoạt động duy nhất để ra các Nghị quyết có ý nghĩa pháp lý. Thông qua các kỳ họp, ý chí của nhân dân địa phương trở thành quyết định của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Hội đồng nhân dân họp thường lệ một năm hai kỳ. Trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường. Các kỳ họp tiến hành công khai, theo trình tự, thủ tục nghiêm ngặt dưới sự điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân (ở cấp xã do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân chủ trì). Kết quả kỳ họp thể hiện bằng Nghị quyết do Chủ tịch Hội đồng nhân dân cùng cấp ký hoặc chứng thực.

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có Thường trực Hội đồng nhân dân; cấp xã không thành lập Thường trực. Chức năng Thường trực của Hội đồng nhân dân cấp xã do Chủ tịch và Phó chủ tịch giúp việc thực hiện.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được thành lập 03 ban: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa xã hội. Ở nơi có nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống có thể thành lập Ban dân tộc. Cấp huyện được lập hai ban: Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế.

Các thành viên Thường trực và các ban của Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cùng cấp. Trưởng ban cấp tỉnh có thể hoạt động chuyên trách, còn Trưởng ban cấp Huyện không hoạt động chuyên trách.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

- Ủy ban nhân dân:

Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

Ủy ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Ủy ban nhân dân có nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội tại địa phương. Thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp tại cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang; bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng quốc phòng toàn dân; quản lý hộ khẩu, hộ tịch, quản lý công tác tổ chức biên chế, lao động tiền lương; tổ chức thu chi ngân sách của địa phương theo quy định của pháp luật.

Thành phần của Ủy ban nhân dân có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên, trong đó Chủ tịch nhất thiết phải là đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp do Hội đồng nhân dân bầu. Các chức danh khác trong Ủy ban nhân dân không nhất thiết phải bầu từ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân là người lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định cùng với tập thể Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân cấp mình và trước cơ quan nhà nước cấp trên.

Ủy ban nhân dân thảo luận tập thể, quyết định theo đa số những vấn đề lớn của địa phương, được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Ủy ban nhân dân được ban hành quyết định và chỉ thị để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Ủy ban nhân dân có các cơ quan chuyên môn để giúp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và đảm bảo sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác từ Trung ương tới cơ sở.

Quy định Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước cấp trên bảo đảm tính thống nhất trong thi hành Hiến pháp, luật.

Tất cả những quy định trên đảm bảo được nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công, phối hợp giữa các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

e) Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân

- Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định.

Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

+ Hoạt động xét xử của các Tòa án có đặc điểm là:

Nhân danh nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ vào pháp luật của Nhà nước đưa ra phán xét, quyết định cuối cùng nhằm kết thúc vụ án; là thể hiện trực tiếp thái độ, quan điểm của Nhà nước đối với một vụ án cụ thể. Thái độ, quan điểm đó chính là sự thể hiện trực tiếp bản chất của Nhà nước. Nhà nước chịu trách nhiệm về nội dung và hậu quả của các quyết định giải quyết các vụ việc do các Tòa án đưa ra.

Xét xử nhằm ổn định trật tự pháp luật, giữ vững kỷ cương xã hội, tự do an toàn của con người, làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội.

Xét xử mang nội dung giáo dục pháp luật với bản thân đương sự cũng như với xã hội, tạo ý thức pháp luật cho mỗi cá nhân, từ đó có được những hành vi phù hợp với yêu cầu của pháp luật trong mối quan hệ xã hội, tạo tinh thần tích cực đấu tranh của công dân chống các hành vi vi phạm pháp luật.

Hiến pháp và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân quy định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án:

+ Về nguyên tắc tổ chức, các Tòa án được tổ chức theo nguyên tắc sau:

Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ và có thể bị miễn nhiệm, cách chức nếu không hoàn thành chức trách. Thực hiện nguyên tắc này nhằm tạo điều kiện cho Thẩm phán có công tác ổn định trong thời gian tương đối dài, có thời gian tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện nghiệp vụ, bảo đảm tính độc lập, chỉ tuân theo pháp luật khi xét xử.

Việc xét xử của Tòa án nhân dân có Hội thẩm nhân dân tham gia theo quy định của pháp luật. Đối với Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án quân sự được thực hiện theo chế độ cử còn đối với các Tòa án nhân dân địa phương thực hiện theo chế độ bầu. Đây là nguyên tắc cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ và bảo đảm nhân dân tham gia vào tổ chức, hoạt động của cơ

quan nhà nước. Thực hiện nguyên tắc này nhằm đảm bảo hoạt động xét xử của Tòa án chính xác, sát thực tế của cuộc sống xã hội.

Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số. Nguyên tắc đòi hỏi việc xét xử được tiến hành bởi một hội đồng và khi quyết định tiến hành theo đa số. Thực hiện nguyên tắc này đảm bảo sự thận trọng, chín chắn của các quyết định xét xử.

Các Chánh án Tòa án nhân dân phải chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp. Nguyên tắc này đảm bảo tính thống nhất của quyền lực nhà nước, nhưng trong tổ chức thực hiện có sự phân công, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

- Viện kiểm sát nhân dân

Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định.

Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

+ Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình bằng công tác sau đây:

Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự của cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

Điều tra một số loại tội phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp;

Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự;

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật;

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành bản án, quyết định của tòa án nhân dân;

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù

1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT

1.2.1. Nguồn gốc của pháp luật

Muốn hiểu rõ bản chất và những quy luật phát sinh, phát triển của pháp luật, trước hết cần phải làm sáng tỏ nguyên nhân và giải thích sự xuất hiện của nó trong lịch sử. Tuy nhiên, trong nhận thức cũng như trong đời sống thực tiễn thì pháp luật luôn là một hiện tượng phức tạp. Lịch sử tư tưởng và khoa học pháp lý nhân loại từ xưa đến nay chưa có được sự thống nhất nhận thức giữa các quan niệm về pháp luật.

Từ thời kỳ cổ, trung đại đã có nhiều nhà tư tưởng tiếp cận và đưa ra những kiến giải khác nhau về nguồn gốc của pháp luật. Các nhà tư tưởng theo quan niệm thần học cho rằng luật pháp được quy về cội nguồn là của Thượng đế, do Thượng đế tạo nên. Về bản chất đó là ý của Chúa trời, là thứ luật chỉ tồn tại ở sự quy phục của con người và nó nhất thành, bất biến. Các tộc người nguyên thủy cổ đại ở Ai Cập, Babilon, Ấn Độ, Ba Tư, Hi Lạp đều coi quyền lực và những quy tắc sinh hoạt nói chung là do thần linh ban phát. Chẳng hạn, theo quan niệm thần thoại của người Ai Cập cổ đại, nữ thần Maat tượng trưng cho chân lý, công bằng xã hội và toà án. Các quan toà mang hình nữ thần được xem là những người phụng sự của nữ thần.

Đến khoảng thế kỷ 16, 17, 18 đã xuất hiện hàng loạt quan niệm mới về pháp luật. Tiêu biểu như quan niệm của J.J Rousseau (1712-1778), ông cho rằng pháp luật là phương tiện để liên kết mọi thành viên trong xã hội, đó chính là công ước chung cho mọi người. Để có công ước đó, các thành viên trong xã hội phải từ bỏ một số quyền riêng của mình góp vào cái chung. Theo ông, *“chỉ có một đạo luật duy nhất đòi hỏi phải được sự đồng ý của tất cả mọi người, đó là công ước xã hội”*.

Theo quan điểm Mác-Lênin, ***pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội theo những mục tiêu, định hướng cụ thể***. Như vậy, pháp luật là một thứ chuẩn mực xã hội được hình thành bằng con đường nhà nước và mang tính quyền lực nhà nước. Do đó, những nguyên nhân làm xuất hiện nhà nước đồng thời là những nguyên nhân làm xuất hiện pháp luật. Nhà nước cũng như pháp luật không có con đường phát triển riêng ngoài sự vận động của cơ sở kinh tế. Vì lẽ đó, theo Mác, nghiên cứu nguồn gốc của pháp luật trước hết phải đi từ căn nguyên kinh tế và xem xét cả hai giai đoạn phát triển của xã hội loài người là giai đoạn xã hội chưa có giai cấp, chưa có pháp luật và giai đoạn có giai cấp, có pháp luật. Pháp luật không phải là sản phẩm hình thành một cách chủ quan, tức thời mà nó là kết quả tất yếu, khách quan của quá trình vận động lịch sử với những nguyên nhân, điều kiện cụ thể.

Với tính cách là công cụ quản lý đời sống của con người, pháp luật sẽ không xuất hiện nếu nhu cầu của xã hội không đặt ra. Xã hội cộng sản nguyên thủy dựa

trên nền tảng kinh tế tự nhiên chưa có sự khác biệt về lao động và hưởng thụ, chưa có sự phân hoá xã hội, tính chất các quan hệ xã hội đơn giản nên việc quản lý được thực hiện bằng các hình thức, phương tiện như: Sự ràng buộc của huyết thống; sự quản lý của Hội đồng thị tộc, bào tộc và bộ lạc; phong tục, tập quán, quy tắc đạo đức; các quan niệm tôn giáo nguyên thủy; uy tín của các vị trưởng lão, thủ lĩnh quân sự.

Cùng với sự vận động phát triển của lực lượng sản xuất, chế độ tư hữu xuất hiện, yếu tố xã hội trong phân công lao động hình thành. Theo đó, một nền kinh tế sản xuất-xã hội-trao đổi đã thay thế cho nền kinh tế tự nhiên nguyên thủy. Xung đột về lợi ích ngày càng gay gắt đã kéo theo sự biến đổi căn bản về kết cấu, quyền lực xã hội cũng như tính chất của các quan hệ xã hội. Khoảng cách về sự phân hoá xã hội ngày càng lớn khi xã hội xuất hiện giai cấp và sự thống trị giai cấp. Việc quản lý thị tộc, bộ lạc bằng những hình thức, phương tiện như trước không còn hiệu lực và hiệu quả. Trong lúc đó, nhu cầu quản lý xã hội vẫn đặt ra, tầng lớp trên (giai cấp thống trị) bắt đầu đưa ra những quy định mới có lợi cho mình, từng bước loại bỏ các phương tiện cũ trong điều chỉnh và quản lý xã hội. Những quy định đó thể hiện ý chí, bảo vệ lợi ích cho giai cấp thống trị và nhanh chóng được áp đặt vào xã hội và buộc mọi người thừa nhận, dần dần được hiểu đó là pháp luật.

Như vậy, pháp luật chỉ xuất hiện khi nhu cầu quản lý xã hội thực sự cần thiết và chỉ khi điều kiện về kinh tế, xã hội đạt đến một trình độ phát triển nhất định. Đó là:

Thứ nhất, về mặt kinh tế có sự chuyển đổi từ nền kinh tế tự nhiên nguyên thủy sang nền kinh tế sản xuất-xã hội-trao đổi. Sự chuyển đổi này chỉ diễn ra một lần duy nhất trong toàn bộ lịch sử phát triển của xã hội loài người. Bởi vậy, xét về điều kiện kinh tế pháp luật cũng chỉ có thể xuất hiện một lần như chính nó đã và đang hiện hữu trong thực tế lịch sử mà thôi.

Thứ hai, về mặt xã hội có sự phân chia thành các giai cấp đối kháng và mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được. Chính vì vậy cần phải có pháp luật với tư cách là phương tiện kiểm soát xã hội, kìm giữ cho các xung đột, mâu thuẫn giai cấp nằm trong một trật tự nhất định.

Có thể thấy, không phải ngay từ khi ra đời pháp luật đã được hoàn thiện cả về nội dung, hình thức mà nó từng bước được hoàn thiện phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội và khả năng nhận thức của con người. Trong lịch sử, có các cách thức cơ bản tạo nên pháp luật như sau:

Một là, giai cấp thống trị thông qua nhà nước chọn lọc, thừa nhận các quy tắc xử sự thông thường trong xã hội (như các quy tắc đạo đức, phong tục tập quán) nâng lên thành các quy định pháp luật (**Tập quán pháp**).

Hai là, nhà nước ban hành các **Văn bản quy phạm pháp luật**. Văn bản quy phạm pháp luật là những văn bản do các cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo một trình tự, thủ tục được pháp luật quy định, chứa đựng quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo những mục đích cụ thể.

Ba là, nhà nước thừa nhận các cách thức xử lý được đưa ra trong các quyết định áp dụng pháp luật như của Tòa án, cơ quan hành chính nâng lên thành các quy định pháp luật (**Tiền lệ pháp**).

1.2.2. Bản chất của pháp luật

Nói đến bản chất của pháp luật là nói đến **“tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định ở bên trong”** của pháp luật quy định sự vận động và phát triển của nó, hay tìm hiểu những đặc tính cơ bản, thực chất bên trong của pháp luật và những quá trình sâu xa diễn ra trong nội bộ của nó.

Tuỳ theo cách lý giải về nguồn gốc ra đời của pháp luật mà người ta có quan niệm về bản chất của pháp luật tương ứng. Theo chủ nghĩa Mác Lênin, xét về bản chất, pháp luật luôn có tính giai cấp và tính xã hội.

Trước hết, nói về bản chất giai cấp của pháp luật. Cũng như nhà nước, pháp luật chỉ ra đời trong xã hội có giai cấp. Vì thế bất cứ ở đâu và khi nào pháp luật cũng thể hiện bản chất giai cấp của nó. Không có pháp luật tự nhiên hay pháp luật phi giai cấp.

Làm sáng tỏ bản chất giai cấp của pháp luật tức là trả lời cho câu hỏi pháp luật đó là của ai, do giai cấp nào thiết lập nên và nhằm phục vụ cho ai, giai cấp nào trong xã hội.

Bản chất giai cấp của pháp luật được thể hiện trên hai phương diện sau:

Thứ nhất: Pháp luật là những quy tắc thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội, giai cấp nắm quyền lực nhà nước. Thông qua nhà nước, giai cấp thống trị thể hiện ý chí của giai cấp mình một cách tập trung, thống nhất và hợp pháp hoá thành pháp luật.

Ăngghen đã khẳng định: Pháp luật tư sản chẳng qua chỉ là ý chí của giai cấp tư sản được đề lên thành luật.

Thứ hai: Tính giai cấp của pháp luật còn thể hiện ở mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội của nó.

Mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội của pháp luật là nhằm thiết lập một trật tự xã hội phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ và củng cố địa vị thống trị của giai cấp này trong xã hội. Vì thế, có thể nói pháp luật là công cụ để thực hiện sự thống trị giai cấp.

Tính giai cấp là thuộc tính chung và cơ bản của bất kỳ một kiểu pháp luật nào. Mỗi hình thái kinh tế – xã hội của nhân loại có một kiểu pháp luật tương ứng cũng giống như nhà nước. Tuy nhiên mức độ thể hiện tính giai cấp ở các kiểu pháp luật khác nhau là không giống nhau.

Tiếp theo là tính xã hội của pháp luật. Nó cũng được thể hiện trên hai khía cạnh.

Một là, pháp luật do nhà nước - đại diện chính thức của toàn xã hội - ban hành, nên nó cũng góp phần giải quyết các vấn đề chung của toàn xã hội như pháp lệnh đề điều, phòng chống lụt bão... Đồng thời, trong những điều kiện hoàn cảnh cụ thể và ở mức độ nhất định, pháp luật còn thể hiện ý chí của các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội. Ví dụ khi có đấu tranh chống giặc ngoại xâm để tập hợp các lực lượng khác nhau trong xã hội pháp luật phải phản ánh ý chí của toàn xã hội.

Hai là, pháp luật mang tính quy luật, phản ánh chân lý khách quan. Giai cấp thống trị không thể tự nghĩ ra pháp luật mà pháp luật phải xuất phát từ điều kiện kinh tế xã hội mà nó tồn tại. Anghen cũng đã khẳng định điều này khi nói về pháp luật tư sản: Pháp luật tư sản chẳng qua chỉ là ý chí của giai cấp tư sản được đề lên thành luật, cái ý chí mà nội dung của nó là do nhiều điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp tư sản quyết định.

Như vậy, pháp luật là một hiện tượng vừa mang tính giai cấp lại vừa thể hiện tính xã hội, không có pháp luật chỉ thể hiện duy nhất tính giai cấp hoặc tính xã hội.

1.2.3. Các đặc trưng cơ bản của pháp luật

Trên cơ sở quan niệm về pháp luật nêu trên, ta thấy, pháp luật có các đặc trưng cơ bản sau:

1.2.3.1. Tính quyền lực nhà nước:

Pháp luật có tính quyền lực nhà nước bởi vì pháp luật được hình thành bằng con đường nhà nước, do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận. Đồng thời, pháp luật được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp mang tính quyền lực nhà nước, như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tổ chức thực hiện và đặc biệt là áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước.

1.2.3.2. Tính quy phạm phổ biến

Các quy định của pháp luật là những khuôn mẫu, chuẩn mực để hướng dẫn cách xử sự cho mọi người trong xã hội, để bất kỳ ai khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh do pháp luật dự liệu thì đều xử sự theo những cách thức mà nó đã nêu ra.

1.2.3.3. Tính hệ thống

Bản thân pháp luật là một hệ thống các quy tắc xử sự chung, các nguyên tắc, định hướng... để điều chỉnh nhiều loại quan hệ xã hội phát sinh trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống. Song các quy định của pháp luật không tồn tại một cách biệt lập mà giữa chúng có mối liên hệ nội tại và thống nhất với nhau để tạo nên một chỉnh thể là hệ thống pháp luật.

1.2.3.4. Tính xác định chặt chẽ về hình thức

Pháp luật có tính xác định về hình thức, tức là nó thường được thể hiện trong những hình thức nhất định, có thể là tập quán pháp, tiền lệ pháp hoặc văn bản quy phạm pháp luật. Trong các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của pháp luật được thể hiện thành văn nên thường rõ ràng, cụ thể, bảo đảm có thể được hiểu và thực hiện thống nhất trong một phạm vi rộng.

1.2.3.5. Tính có ý chí

Pháp luật luôn thể hiện ý chí của con người mà cụ thể là ý chí của nhà nước, của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền và của toàn xã hội nên có tính ý chí.

1.2.4. Chức năng của pháp luật

Khái niệm chức năng của pháp luật phản ánh nhưng phương diện, mặt tác động chủ yếu của pháp luật.

Pháp luật có ba chức năng cơ bản là: Chức năng điều chỉnh, chức năng bảo vệ và chức năng giáo dục.

1.2.4.1. Chức năng điều chỉnh của pháp luật:

Được thể hiện thông qua việc quy định pháp luật quy định tư cách chủ thể, quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong các mối quan hệ xã hội. Bằng cách thức điều chỉnh đặc biệt này, pháp luật vừa củng cố các quan hệ xã hội, đưa các quan hệ xã hội vào những trật tự, những phạm vi và khuôn mẫu nhất định, vừa tạo điều kiện cho các quan hệ xã hội phát triển theo chiều hướng phù hợp với quy luật vận động khách quan của các quan hệ xã hội.

1.2.4.2. Chức năng bảo vệ của pháp luật:

Được thực hiện thông qua việc pháp luật quy định các hình thức trách nhiệm pháp lý đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật. Bằng cách này, pháp luật bảo vệ các quan hệ xã hội trước các vi phạm và loại trừ những quan hệ xã hội lạc hậu, những hành vi tùy tiện, tiêu cực kìm hãm sự phát triển của xã hội.

1.2.4.3. Chức năng giáo dục của pháp luật:

Được thể hiện thông qua sự tác động của pháp luật vào ý thức con người, hướng dẫn mọi người tiến hành những cách thức xử sự phù hợp với pháp luật, đạo đức và tiến bộ xã hội.

1.2.5. Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật

1.2.5.1. Quy phạm pháp luật

a) Khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật

Để quản lý xã hội, nhà nước đặt ra rất nhiều quy định để tác động đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua các quy định đó, ý chí của nhà nước được thể hiện ở nhiều các thức và mức độ khác nhau; có thể là nhà nước tuyên bố một vấn đề nào đó, quy định nguyên tắc hoạt động của các cơ quan nhà nước, của các tổ chức xã hội hay đề ra các cách xử sự cho hành vi của con người khi tham gia vào các mối quan hệ xã hội cụ thể. Trong toàn bộ những quy định mà nhà nước ban hành thì quy phạm pháp luật chiếm đa số. Quy phạm pháp luật là yếu tố, thành phần cơ bản của pháp luật. Từ đó có thể hiểu quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh quan hệ xã hội theo hướng nhất định và nhằm đạt được mục đích mà nhà nước đặt ra.

Quy phạm pháp luật có những đặc điểm sau:

- Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung;
- Quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện, nó luôn thể hiện ý chí của nhà nước;
- Quy phạm pháp luật thể hiện hai mặt bắt buộc và cho phép;
- Quy phạm pháp luật luôn mang tính xác định chặt chẽ.

b) Cơ cấu của quy phạm pháp luật

Quy phạm pháp luật một mặt là quy tắc xử sự của công dân, của các tổ chức, cơ quan nhà nước; mặt khác, nó là sự thể hiện ý chí của nhà nước. Do vậy, nội dung của quy phạm pháp luật phải vừa thể hiện ý chí của nhà nước, đồng thời vừa là khuôn mẫu cho hành vi của các thành viên trong xã hội. Thông qua nội dung của quy phạm pháp luật, các thành viên của xã hội sẽ biết được:

- Trong trường hợp, hoàn cảnh nào của đời sống thì đối tượng tiếp nhận quy phạm pháp luật phải tuân theo quy tắc mà nhà nước đề ra;
- Khi gặp những điều kiện, hoàn cảnh mà nhà nước dự kiến xảy ra trong thực tế thì phải xử sự như thế nào;
- Biện pháp nào nhà nước dự kiến sẽ tác động nhằm bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng và tự giác thực hiện.

Các câu trả lời cho các vấn đề trên tạo nên các thành phần của quy phạm pháp luật. Theo đó, quy phạm pháp luật có ba thành phần là phần giả định, phần quy định và phần bảo đảm (chế tài).

Phần giả định:

Giả định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên hoàn cảnh, điều kiện có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật. Bộ phận này trả lời cho câu hỏi: Ai? Khi nào? Trong những điều kiện, hoàn cảnh nào?

Ví dụ: Khoản 1 – Điều 31 – Bộ luật Lao động 2014 quy định: “Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động”

Phần quy định:

Quy định là biện pháp nêu lên bằng cách thức xử sự bắt buộc mà mọi người phải tuân theo khi ở vào hoàn cảnh, điều kiện đã nêu lên trong phần giả định. Bộ phận này trả lời cho câu hỏi: Phải làm gì? Được làm gì? Làm như thế nào?

Phần chế tài:

Chế tài là bộ phận nêu lên những biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể không thực hiện đúng mệnh lệnh đã nêu ở bộ phận quy định. Đây chính là hậu quả bất lợi đối với chủ thể vi phạm pháp luật. Bộ phận này trả lời cho câu hỏi: Hậu quả gì nếu không làm đúng những mệnh lệnh nêu ở phần quy định mà chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu.

Ví dụ: Điều 132 – Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng như sau: “Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm”.

Chế tài không chỉ nhằm mục đích trừng phạt chủ thể vi phạm pháp luật mà còn có mục đích giáo dục họ có ý thức chấp hành pháp luật, ngăn ngừa họ tiếp tục vi phạm pháp luật.

Có bốn loại chế tài là:

- *Chế tài hình sự (hình phạt)*: Là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của chủ thể vi phạm pháp luật hình sự. Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 có các hình phạt sau: Hình phạt chính bao gồm: Cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình; hình phạt bổ sung bao gồm: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, tịch thu tài sản, phạt tiền, trục xuất (khi không áp dụng là hình phạt chính).

- *Chế tài hành chính*: Là biện pháp cưỡng chế nhà nước do các cơ quan nhà nước và cán bộ có thẩm quyền quyết định áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính, bao gồm: Hình thức phạt chính: Cảnh cáo, phạt tiền; Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật phương tiện vi phạm.

- *Chế tài dân sự*: Gồm các biện pháp trách nhiệm vật chất là: Bồi thường thiệt hại và phạt hợp đồng do toà án quyết định.

- *Chế tài kỷ luật*: Đối tượng áp dụng là người lao động vi phạm nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, đơn vị hoặc vi phạm kỷ luật lao động, do người đứng đầu cơ quan, tổ chức áp dụng. Bao gồm các hình thức từ nhẹ nhất là khiển trách đến nặng nhất là sa thải người lao động.

c) Cách trình bày quy phạm pháp luật trong các điều luật

Trong thực tế các quy định của pháp luật (các điều luật) không phải bao giờ quy phạm cũng được diễn đạt đầy đủ các bộ phận giả định, quy định và chế tài. Có nhiều lý do khác nhau dẫn đến có các cách trình bày quy phạm pháp luật khác nhau, chẳng hạn như để cho việc quy định được ngắn gọn hoặc để thuận tiện cho việc áp dụng pháp luật...

Thông thường có các cách trình bày sau:

- *Một quy phạm pháp luật trình bày trong một điều luật*. Tức là tất cả các bộ phận của một quy phạm được thể hiện đầy đủ trong một điều luật (Đó có thể là cả ba bộ phận hoặc chỉ có hai bộ phận quy phạm đối với loại quy phạm mà nhà nước cho phép các chủ thể được hưởng quyền. Ví dụ: “Mọi người có quyền tự doanh kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm” - Điều 33 – Hiến pháp 2013).

- *Các bộ phận của một quy phạm pháp luật trình bày ở các điều luật khác nhau trong một văn bản quy phạm pháp luật*. Ví dụ: Điều 204 – Bộ luật Lao động 2014 quy định: “Trình tự hoà giải tranh chấp lao động tập thể được thực hiện theo quy định tại Điều 201 của Bộ luật này. Biên bản hòa giải phải nêu rõ loại tranh chấp lao động tập thể.

Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền các bên có quyền yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết;

b) Đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết.

- Các bộ phận của một quy phạm pháp luật trình bày ở các điều luật khác nhau ở các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau.

Ví dụ: Khoản 2 - Điều 5 – Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: “Cấm các hành vi sau đây:

- a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
- b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
- e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;”

Và Điều 181 - Bộ luật Hình sự 2015 quy định: “Người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ, cản trở người khác kết hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ hoặc cưỡng ép hoặc cản trở người khác ly hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm”.

- Trật tự trình bày các bộ phận của quy phạm pháp luật có thể thay đổi.

Bên cạnh đó, còn có một số loại quy phạm pháp luật đặc biệt như:

- Quy phạm định nghĩa: Là loại quy phạm nội dung giải thích, xác định một vấn đề nào đó hoặc nêu lên các khái niệm pháp lý.

Ví dụ: Điều 22 – Bộ luật Hình sự 2015 quy định: “Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc của nhà nước, của cơ quan tổ chức mà có hành vi chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên”.

- Quy phạm nguyên tắc: Là loại quy phạm có nội dung nêu lên các nguyên tắc cơ bản để xử sự mà không đưa ra cách xử sự cụ thể. Thông thường, các quy phạm của Luật Hiến pháp thuộc loại quy phạm này.

Ví dụ: Khoản 1 - Điều 2 - Hiến pháp 2013 quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”.

1.2.5.2. Văn bản quy phạm pháp luật

a) Khái niệm và đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật là một trong những hình thức biểu hiện của pháp luật. Đó là văn bản do cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền ban hành ra theo trình tự, thủ tục và hình thức do pháp luật quy định, trong đó có các quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo mục đích của nhà nước.

Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp luật thành văn, nó ra đời sau tập quán pháp, sự xuất hiện của nó đánh dấu một bước phát triển của pháp luật.

Văn bản quy phạm pháp luật có các đặc điểm cơ bản sau:

- Chỉ do chủ thể có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành (Theo Hiến pháp năm 2013, và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 các chủ thể có thẩm quyền ban hành là: Quốc hội, Ủy ban thường vụ QH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ, Hội đồng Thẩm phán TANDTC, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng kiểm toán nhà nước, Đoàn chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc VN, Hội đồng ND các cấp và Ủy ban ND các cấp.

- Được ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục luật định.

- Có nội dung chứa đựng các quy phạm pháp luật (quy tắc xử sự) mang tính bắt buộc chung điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản.

- Được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế.

- Được áp dụng nhiều lần trong đời sống (sự thực hiện văn bản không làm chấm dứt hiệu lực của nó).

Bên cạnh văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp lý còn có một loại khác là văn bản áp dụng pháp luật.

Văn bản áp dụng pháp luật là hình thức văn bản cá biệt do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành trên cơ sở các quy phạm pháp luật, trong đó có quy tắc xử sự riêng dùng cho một hoặc một nhóm đối tượng, sự việc cụ thể không có tính quy phạm phổ biến, được thực hiện một lần trong đời sống

Ví dụ: Quyết định của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc bổ nhiệm cán bộ; bản án, quyết định của Tòa án về việc giải quyết một vụ án cụ thể...

b) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Như chúng ta thấy là các quan hệ xã hội hết sức đa dạng, phức tạp. Và để điều chỉnh các quan hệ đó, nhà nước phải ban hành một khối lượng rất lớn các văn bản quy phạm pháp luật, với tư cách là công cụ chủ yếu và quan trọng nhất. Tuy nhiên để đảm bảo cho sự điều chỉnh của pháp luật được thực hiện một cách hiệu quả, có trật tự thì đòi hỏi các văn bản quy phạm pháp luật mà nhà nước ban hành ra phải tuân theo một trật tự nhất định và trong một mối quan hệ mật thiết với nhau, tức là tạo thành một hệ thống.

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật chính là hình thức biểu hiện bên ngoài của pháp luật

Phụ thuộc vào thẩm quyền của cơ quan ban hành, các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị hiệu lực cao thấp khác nhau. Cụ thể theo Hiến pháp 2013 và

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước ta hiện nay bao gồm các loại văn bản sau:

- Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội;
- Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH);
- Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước;
- Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
- Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC);
- Thông tư của Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) và của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;
- Nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH hoặc Chính phủ với Đoàn chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc VN;
- Thông tư liên tịch giữa Chánh án TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp, Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp.

c) Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

Việc sử dụng các văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi phải tuân thủ những yêu cầu nhất định, trong đó có việc xác định hiệu lực của chúng. Công việc này đòi hỏi người áp dụng phải biết văn bản đã được áp dụng chưa, còn hiệu lực không, được áp dụng ở đâu và với những đối tượng nào. ***Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật là giá trị tác động của văn bản quy phạm pháp luật lên các quan hệ xã hội được xác định trong phạm vi thời gian, không gian và đối tượng tác động nhất định.*** Như vậy, muốn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật phải xác định hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo các giới hạn về thời gian, không gian và đối tượng tác động.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được xem xét như sau:

Hiệu lực về thời gian của văn bản quy phạm pháp luật

Là xác định giới hạn thời điểm phát sinh và chấm dứt hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, được quy định như sau:

Về xác định ***thời điểm có hiệu lực*** của văn bản quy phạm pháp luật được quy định như sau (Điều 151 – Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015):

- Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

- Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, đồng thời phải được đăng ngay trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc Công báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chậm nhất là sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

Việc xác định ***thời điểm chấm dứt hiệu lực*** của văn bản quy phạm pháp luật (toàn bộ hoặc một phần) có thể dựa vào những căn cứ sau (Điều 154 – Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015):

- Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;
- Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;
- Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.

Hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật (Hiệu lực hồi tố)

Hiệu lực trở về trước là trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với những hành vi xảy ra trước thời điểm văn bản đó có hiệu lực. Về nguyên tắc văn bản quy phạm pháp luật không có hiệu lực trở về trước. Tuy nhiên, chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương mới được quy định hiệu lực trở về trước.

Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp sau đây:

- a) Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý;
- b) Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn.

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt không được quy định hiệu lực trở về trước.

Hiệu lực về không gian của văn bản quy phạm pháp luật được hiểu là giá trị tác động của văn bản được xác định trong phạm vi lãnh thổ, vùng hay khu vực nhất định.

Theo đó, văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương có hiệu lực trong phạm vi cả nước và được áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính nào thì có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó và phải được quy định cụ thể ngay trong văn bản đó.

Trường hợp có sự thay đổi về địa giới hành chính thì hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương được xác định như sau:

+ Trường hợp một đơn vị hành chính được chia thành nhiều đơn vị hành chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được chia vẫn có hiệu lực đối với đơn vị hành chính mới cho đến khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế;

+ Trường hợp nhiều đơn vị hành chính được nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập vẫn có hiệu lực đối với đơn vị hành chính đó cho đến khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế;

+ Trường hợp một phần địa phận và dân cư của đơn vị hành chính được điều chỉnh về một đơn vị hành chính khác thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được mở rộng có hiệu lực đối với phần địa phận và bộ phận dân cư được điều chỉnh.

Hiệu lực theo đối tượng tác động của văn bản quy phạm pháp luật

Hiệu lực theo đối tượng tác động của văn bản là giá trị tác động của văn bản lên các quan hệ xã hội với những chủ thể nhất định. Các chủ thể có thể là cá nhân hoặc các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hay các đơn vị kinh tế... Hiệu lực theo đối tượng tác động của văn bản thường được xác định trực tiếp trong văn bản đó (thường là theo đối tượng điều chỉnh của văn bản).

d) Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật là hoạt động thực hiện pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với những trường hợp cụ thể. Nói cách

khác, đó là sự cá biệt hoá những quy phạm pháp luật vào những trường hợp cụ thể (đối với những cá nhân, tổ chức cụ thể trong những hoàn cảnh cụ thể).

Có thể thấy, những văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ra là nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, nhưng nếu không có hoạt động áp dụng pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì những quy phạm pháp luật không thể đi vào cuộc sống được. Tuy nhiên, với sự đa dạng, phong phú của các quan hệ xã hội thì khối lượng văn bản QPPL cũng hết sức khổng lồ, để đảm bảo cho việc áp dụng chúng được thực hiện một cách thống nhất, có trật tự thì đòi hỏi phải đặt ra những nguyên tắc khi áp dụng.

Một số nguyên nguyên tắc cơ bản khi tiến hành áp dụng văn bản quy phạm pháp luật bao gồm (Điều 156 – Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015):

- Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

- Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

- Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

- Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.

- Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong nước không được cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.

1.2.6. Hệ thống pháp luật Việt Nam

Hệ thống được hiểu là tập hợp nhiều yếu tố, đơn vị cùng loại hoặc cùng chức năng, có quan hệ hoặc liên hệ chặt chẽ, làm thành một thể thống nhất; hoặc tập hợp những tư tưởng, nguyên tắc, quy tắc liên kết với nhau một cách logic, làm thành một thể thống nhất.

Hệ thống pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau, được phân thành các chế định pháp luật, các ngành luật và được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành.

Hệ thống pháp luật gồm hai bộ phận:

- Hệ thống cấu trúc bên trong (Quy phạm pháp luật – Chế định pháp luật – Ngành luật);
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Trong đó, **quy phạm pháp luật** là đơn vị nhỏ nhất cấu thành hệ thống pháp luật. Nói cách khác, quy phạm pháp luật đóng vai trò là tế bào của hệ thống cấu trúc pháp luật. **Chế định pháp luật** là một nhóm quy phạm pháp luật có đặc điểm chung, cùng điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội có cùng tính chất. **Ngành luật** là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ cùng loại trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội.

Căn cứ chủ yếu để phân định ngành luật là:

- Đối tượng điều chỉnh
- Phương pháp điều chỉnh

Đối tượng điều chỉnh: Là những quan hệ xã hội cùng loại, thuộc một lĩnh vực của đời sống xã hội cần có sự điều chỉnh bằng pháp luật. Mỗi ngành luật sẽ điều chỉnh một loại quan hệ xã hội đặc thù.

Phương pháp điều chỉnh: Là cách thức tác động vào quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của ngành luật đó. Mỗi ngành luật cũng có phương pháp điều chỉnh đặc thù. Hai phương pháp điều chỉnh chính được sử dụng là phương pháp bình đẳng thoả thuận và phương pháp quyền uy-phục tùng.

+ **Phương pháp bình đẳng, thoả thuận:** Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào các quan hệ pháp luật mà chỉ định ra khuôn khổ và các bên tham gia quan hệ pháp luật có thể thoả thuận với nhau (về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ pháp luật, cách thức giải quyết khi có tranh chấp xảy ra...) trong khuôn khổ đó, các bên tham gia quan hệ pháp luật bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ.

+ **Phương pháp quyền uy - phục tùng:** Một bên trong quan hệ pháp luật (Nhà nước) có quyền ra mệnh lệnh, còn bên kia phải phục tùng.

Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm:

- Luật Hiến pháp: (Còn gọi là Luật Nhà nước)
- Luật Hành chính
- Luật Hình sự
- Luật Tố tụng Hình sự
- Luật Dân sự
- Luật Tố tụng Dân sự
- Luật Hôn nhân - Gia đình
- Luật Lao động
- Luật Kinh tế
- Luật Đất đai
- Luật Tài chính
- Luật Ngân hàng

Chương 2

LUẬT DÂN SỰ

2.1. Khái quát chung về Luật dân sự

Luật dân sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam – tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa – tiền tệ và các quan hệ nhân thân trên cơ sở bình đẳng, độc lập của các chủ thể tham gia quan hệ đó.

Luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. Với quy định đó, luật dân sự trở thành luật chung có thể được áp dụng trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động.

Với tư cách là một ngành luật trong hệ thống pháp luật, luật dân sự có đối tượng và phương pháp điều chỉnh riêng. Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự là những nhóm quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản trong các lĩnh vực nêu trên. Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự là phương pháp bình đẳng, tự định đoạt, theo đó các chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự được bình đẳng với nhau về địa vị pháp lý và tự định đoạt tham gia các quan hệ tài sản.

Hiện nay, luật dân sự Việt Nam được chia thành hai phần là phần chung và phần riêng. Phần chung là những quy định chung, xuyên suốt toàn bộ hệ thống pháp luật dân sự, quy định về nguyên tắc, về chủ thể, căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền dân sự, thời hạn, thời hiệu. Phần riêng bao gồm các chế định pháp lý như: chế định tài sản, quyền sở hữu; chế định nghĩa vụ và hợp đồng, chế định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; chế định quyền sở hữu trí tuệ; chế định quyền thừa kế...

2.2. Chế độ pháp lý về hợp đồng

2.2.1. Khái niệm, phân loại hợp đồng

2.2.1.1. Khái niệm hợp đồng

Hợp đồng là loại giao dịch phổ biến và là căn cứ chủ yếu làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể. Hiện nay, khái niệm pháp lý chung nhất về hợp đồng được quy định tại Điều 385- Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau “*Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ đối với nhau*”. Cùng với Bộ luật Dân sự, một số luật chuyên ngành khác cũng quy định riêng về một số loại hợp đồng mang đặc thù như: hợp đồng xây dựng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng vận tải, hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản...Tuy nhiên, theo tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thì những quy định về hợp đồng đặc thù trong các văn bản pháp luật

chuyên ngành phải tuân theo những quy định chung về hợp đồng quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 hiện nay.

Xét về bản chất, hợp đồng phải có sự thỏa thuận giữa các bên về quyền và nghĩa vụ. Sự thỏa thuận ở đây chính là việc các bên tự do ý chí, tự nguyện tham gia quan hệ hợp đồng, ở đó các bên được tự do định đoạt việc giao kết hợp đồng với ai, như thế nào, về cái gì, vào thời điểm nào... Thông qua hợp đồng, các bên hướng tới các đối tượng, nghĩa vụ của hợp đồng. Nhưng hợp đồng chỉ có hiệu lực khi sự thỏa thuận đó không trái quy định của pháp luật hay đạo đức xã hội.

2.2.1.2 Phân loại hợp đồng

Hợp đồng là loại giao dịch dân sự phổ biến, vì thế việc phân loại hợp đồng được thực hiện dựa trên các tiêu chí sau đây:

a. Theo nội dung của hợp đồng

- Hợp đồng không có tính chất kinh doanh hay hợp đồng dân sự theo nghĩa hẹp. Những hợp đồng giữa cá nhân, hộ gia đình để thực hiện những giao dịch dân sự nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt.

- Hợp đồng kinh doanh, thương mại. Hợp đồng giữa các thương nhân để thực hiện các hoạt động kinh doanh, thương mại.

- Hợp đồng lao động là hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động.

b. Theo tính chất đặc thù của hợp đồng

- Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.

- Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.

- Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó

- Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.

c. Theo sự tương xứng về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng

- Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.

- Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ.

d. Theo hình thức của hợp đồng

- Hợp đồng bằng văn bản.

- Hợp đồng bằng lời nói.

- Hợp đồng bằng hành vi cụ thể.

e. Theo lĩnh vực áp dụng của hợp đồng

- Hợp đồng thương mại.

- Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.

- Hợp đồng chuyển giao quyền tài sản của quyền tác giả.
- Hợp đồng chuyển giao công nghệ.
- Hợp đồng xây dựng.
- Hợp đồng bảo hiểm.

f. Theo tính thông dụng của hợp đồng

- Hợp đồng mua bán tài sản: Theo Điều 430, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: *“Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán”*.

- Hợp đồng trao đổi tài sản: Theo Điều 457, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: *“Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau”*.

- Hợp đồng tặng cho tài sản: Điều 457, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: *“Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận”*.

- Hợp đồng vay tài sản: Điều 463, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: *“Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”*.

- Hợp đồng thuê tài sản: Điều 472, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: *“Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê”*.

- Hợp đồng thuê khoán tài sản: Điều 483, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: *“Hợp đồng thuê khoán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê”*.

- Hợp đồng mượn tài sản: Điều 494, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: *“Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được”*.

- Hợp đồng về quyền sử dụng đất: Điều 500, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: *“Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất”*.

- Hợp đồng hợp tác: Điều 504, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “*Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm*”

- Hợp đồng dịch vụ: Điều 513, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “*Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ*”

- Hợp đồng vận chuyển:

+ Hợp đồng vận chuyển hành khách: Điều 522, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “*Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển*”.

+ Hợp đồng vận chuyển tài sản: Điều 530, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “*Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển*”.

- Hợp đồng gia công: Điều 542, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “*Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công*”.

- Hợp đồng gửi giữ tài sản: Điều 554, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “*Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công*”.

- Hợp đồng ủy quyền: Điều 562, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “*Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định*”.

2.2.2. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng và hợp đồng vô hiệu

2.2.2.1. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

Quan hệ hợp đồng thể hiện sự ràng buộc pháp lý về quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia, nhằm hướng tới lợi ích nhất định. Để đảm bảo cho các quyền và nghĩa vụ đó có hiệu lực thì quan hệ hợp đồng phải đạt được điều kiện nhất định. Điều 117 BLDS năm 2015 quy định một quan hệ hợp đồng có hiệu lực pháp lý cần phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

2.2.2.1.1. Các chủ thể giao kết hợp đồng phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với quan hệ hợp đồng được xác lập

Chủ thể giao kết hợp đồng là các bên tham gia xác lập quan hệ hợp đồng. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì chủ thể tham gia vào hợp đồng bao gồm có cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác và Nhà nước. các chủ thể này khi tham gia quan hệ hợp đồng phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự phù hợp. Cụ thể như sau:

a. Đối với cá nhân.

Theo quy định, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau, có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết. Như vậy, bất kỳ người nào cũng có năng lực pháp luật dân sự.

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Pháp luật quy định năng lực hành vi của mỗi người là nhau, mức độ năng lực hành vi mỗi người phụ thuộc vào khả năng nhận thức và độ tuổi của người đó, được chia thành các trường hợp sau:

- Người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên (không bị mất năng lực hành vi, hạn chế năng lực hành vi, người có khó khăn trong nhận thức). Theo quy định, người đủ năng lực hành vi được tự mình xác lập và thực hiện quan hệ hợp đồng mà pháp luật cho phép.

- Người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi. Theo quy định, người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế năng lực hành vi khi xác lập và thực hiện các hợp đồng phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ hợp đồng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được tự mình xác lập, thực hiện hợp đồng trừ hợp đồng liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch khác theo quy định phải có người đại diện theo pháp luật đồng ý. Người chưa đủ 6 tuổi, người bị mất năng lực hành vi thì mọi giao dịch phải do người đại diện theo pháp luật xác lập và thực hiện.

b. Đối với pháp nhân

Pháp nhân là các tổ chức được thành lập đảm bảo các yêu cầu quy định tại Điều 74 của BLDS 2015. Pháp nhân được chia thành pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại.

Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận, nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên. Pháp nhân phi thương mại bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân,

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.

Theo quy định, pháp nhân chỉ có năng lực pháp luật. Năng lực pháp luật của pháp nhân phát sinh từ thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập và chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân. Việc xác lập các hợp đồng của pháp nhân phải thông qua người đại diện, bao gồm: đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo uỷ quyền.

c. Các chủ thể khác

- Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân khi tham gia xác lập và thực hiện hợp đồng thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác đó là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện hợp đồng hoặc ủy quyền cho người đại diện thực hiện. Trường hợp không được các thành viên khác ủy quyền làm người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ hợp đồng do mình xác lập và thực hiện.

- Nhà nước là chủ thể đặc biệt khi tham gia một số quan hệ hợp đồng ngoại thương.

2.2.2.1.2. Chủ thể tham gia hợp đồng hoàn toàn tự nguyện

Tự nguyện là sự thống nhất giữa hai yếu tố tự do ý chí và bày tỏ ý chí. Nếu thiếu một trong hai yếu tố này hoặc không có sự thống nhất giữa hai yếu tố này sẽ không thể có tự nguyện. BLDS năm 2015 quy định liệt kê một số trường hợp hợp đồng được xác lập không có sự tự nguyện sẽ bị coi là vô hiệu. Đó là các trường hợp hợp đồng được xác lập do giả tạo, do nhầm lẫn, do bị lừa dối, bị đe dọa, cưỡng ép.

2.2.2.1.3. Mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội

Mục đích của hợp đồng là lợi ích hợp pháp mà các bên mong muốn đạt được khi xác lập hợp đồng đó. Nội dung của hợp đồng là tổng hợp các điều khoản mà các bên đã cam kết, thoả thuận trong hợp đồng. Mục đích và nội dung của hợp đồng có quan hệ gắn bó chặt chẽ: để đạt được mục đích phải thoả thuận về nội dung của hợp đồng, ngược lại việc thoả thuận về nội dung của hợp đồng là nhằm đạt được mục đích đã đặt ra.

Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng. Một hợp đồng nói riêng và một giao dịch dân sự nói chung được xác lập và thực hiện có mục đích hoặc nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội sẽ có thể làm ảnh hưởng hoặc xâm phạm đến lợi của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể khác. Vì vậy, pháp luật

quy định một trong các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng đó là mục đích và nội dung không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội là hoàn toàn phù hợp với lợi ích chung.

2.2.2.1.4. Hình thức của hợp đồng phải phù hợp trong trường hợp pháp luật có quy định điều kiện về hình thức

Hình thức của hợp đồng là cách thức thể hiện nội dung của hợp đồng. Hiện nay, pháp luật quy định hợp đồng có thể được thể hiện dưới hình thức bằng lời nói, bằng hành vi hoặc bằng văn bản. Đối với hình thức văn bản bao gồm văn bản thường và văn bản công chứng. Tùy thuộc vào tính chất của hợp đồng mà pháp luật có những quy định cụ thể về hình thức của hợp đồng. Những hợp đồng mà pháp luật quy định hình thức là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, nếu các bên không tuân thủ theo hình thức đó thì hợp đồng không có hiệu lực.

Ví dụ: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nếu không lập thành văn bản và không có công chứng thì sẽ vô hiệu.

2.2.2.1.5. Đối tượng của hợp đồng có thể thực hiện được

Theo quy định của pháp luật, một trong các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng đó là đối tượng của hợp đồng phải thực hiện được. Trường hợp ngay từ khi giao kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được thì hợp đồng vô hiệu.

2.2.2.2. Hợp đồng vô hiệu và hậu quả pháp lý

Hợp đồng vô hiệu là hợp đồng được xác lập không đảm bảo một trong các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng.

Các trường hợp hợp đồng vô hiệu được quy định từ Điều 123 đến Điều 130 BLDS năm 2015. Hậu quả pháp lý chung khi hợp đồng vô hiệu đó là:

- Không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ ư của các bên kể từ thời điểm xác lập;
- Các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả. Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó;
- Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2.2.3. Giao kết hợp đồng

Giao kết hợp đồng là quá trình thương lượng, đàm phán giữa các bên theo những nguyên tắc và trình tự nhất định để đạt được sự thống nhất về nội dung của hợp đồng, từ đó xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên với nhau.

2.2.3.1. Nguyên tắc giao kết hợp đồng

- Tự do giao kết hợp đồng nhưng không trái pháp luật, đạo đức xã hội.
- Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác.

2.2.3.2. Trình tự giao kết hợp đồng

Trình tự giao kết hợp đồng có thể chia thành hai giai đoạn: Đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.

a. Đề nghị giao kết hợp đồng

Theo khoản 1, Điều 386 BLDS 2015 quy định: “*Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng*”.

Đề nghị giao kết hợp đồng được tiến hành bằng nhiều phương thức khác nhau, các bên có thể trực tiếp gặp nhau bàn bạc đi đến thỏa thuận về nội dung của hợp đồng hoặc có thể gián tiếp thương lượng trao đổi qua điện thoại, điện báo và thư điện tử.

Trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, nếu bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh.

Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực do bên đề nghị ấn định. Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó.

Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi, rút lại đề nghị trong trường hợp: Bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước hoặc cùng với thời điểm nhận được đề nghị; Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề nghị có nêu rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó phát sinh.

b. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

Theo khoản 1, Điều 393 BLDS năm 2015 quy định “*Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị*”.

Khi bên được đề nghị chấp nhận toàn bộ nội dung các điều khoản được bên đề nghị đưa ra thì coi như chấp nhận đề nghị. Nếu bên được đề nghị chỉ chấp nhận một phần trong nội dung đó thì coi như bên được đề nghị muốn thay đổi, bổ sung nội dung mà bên đề nghị đưa ra. Vì thế, bên được đề nghị trở thành bên đề nghị giao kết hợp đồng mới, bên đề nghị trước đó lại trở thành bên được đề nghị.

Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả lời. Trường hợp bên đề nghị không ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn hợp lý.

Quá trình đưa ra đề nghị và chấp nhận đề nghị lặp lại đến khi nào các bên có thể thống nhất toàn bộ nội dung các điều khoản trong hợp đồng thì tiến đến việc chính thức giao kết hợp đồng.

2.2.3.3. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

Theo quy định tại Điều 401 BLDS năm 2015, hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

Thời điểm giao kết hợp đồng được xác định tùy theo phương thức giao kết và hình thức hợp đồng mà các bên lựa chọn. Theo Điều 400 BLDS năm 2015, thời điểm giao kết hợp đồng dân sự được quy định như sau:

- Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết.

- Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đồng được tính từ thời điểm cuối cùng của thời hạn đó.

- Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

- Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.

Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

2.2.4. Nội dung của hợp đồng

Nội dung của hợp đồng là tổng hợp các điều khoản mà các bên tham gia giao kết đã thống nhất. Theo Điều 398 BLDS năm 2015 quy định các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng. Nội dung thông thường của hợp đồng bao gồm:

- Đối tượng của hợp đồng;
- Số lượng, chất lượng;
- Giá, phương thức thanh toán;
- Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
- Quyền, nghĩa vụ của các bên;
- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
- Phương thức giải quyết tranh chấp.
- Các nội dung khác.

Trong các điều khoản nói trên, có thể phân chia các điều khoản trong nội dung của hợp đồng thành ba loại sau:

a. Điều khoản cơ bản

Điều khoản cơ bản là những điều khoản xác định nội dung chủ yếu của hợp đồng. Đó là những điều khoản không thể thiếu được đối với từng loại hợp đồng. Nếu các bên không thỏa thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng không thể

giao kết được. Điều khoản cơ bản có thể do tính chất của từng hợp đồng quyết định hoặc do pháp luật quy định. Tùy theo từng loại hợp đồng mà điều khoản cơ bản có thể là đối tượng, giá cả, địa điểm...

b. Điều khoản thông thường

Là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật đã quy định. Khác với điều khoản cơ bản, các điều khoản thông thường không làm ảnh hưởng tới quá trình giao kết hợp đồng. Để giảm bớt những công việc không cần thiết trong giao kết hợp đồng, các bên có thể không cần thoả thuận và không cần ghi vào văn bản hợp đồng những điều khoản mà pháp luật đã quy định nhưng các bên vẫn phải thực hiện những điều khoản đó.

c. Điều khoản tùy nghi

Điều khoản tùy nghi là những điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng tự ý lựa chọn và thoả thuận với nhau để xác định quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên. Thông qua điều khoản tùy nghi, bên có nghĩa vụ được phép lựa chọn một trong những cách thức nhất định để thực hiện hợp đồng, sao cho thuận lợi mà vẫn bảo đảm được quyền yêu cầu của bên kia.

2.2.5. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng

Để ràng buộc và tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện các nghĩa vụ của hợp đồng, các bên có thể thoả thuận áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng theo quy định của pháp luật. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mang tính chất dự phòng, nó chỉ có ý nghĩa khi nghĩa vụ chính theo hợp đồng không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng để qua đó bảo vệ quyền lợi cho bên có quyền. Hiện nay, BLDS năm 2015 có quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng bao gồm:

2.2.5.1. Cầm cố tài sản

Cầm cố tài sản là việc một bên (gọi là bên cầm cố) chuyển giao tài sản cho bên kia (gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của chính mình hoặc của người khác.

2.2.5.2. Thế chấp tài sản

Thế chấp tài sản là việc một bên (gọi là bên thế chấp) dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của chính mình hoặc của người khác và không chuyển giao tài sản cho bên kia (gọi là bên nhận thế chấp).

2.2.5.3. Cầm giữ tài sản

Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (gọi là bên cầm giữ) đang chiếm giữ hợp pháp động sản là đối tượng của hợp đồng song vụ trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thoả thuận.

2.2.5.4. Bảo lưu quyền sở hữu tài sản

Là việc bên bán tài sản theo hợp đồng mua bán tài sản bảo lưu quyền sở hữu đối với tài sản mua bán cho đến khi bên mua tài sản thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ.

2.2.5.5. Đặt cọc

Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng

2.2.5.6. Ký cược

Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (gọi là tài sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê.

2.2.5.7. Ký quỹ

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong toả để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự.

2.2.5.8. Bảo lãnh

Bảo lãnh là việc người thứ ba (gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

2.2.6. Thực hiện hợp đồng

Thực hiện hợp đồng là việc các bên tiến hành các hành vi mà mỗi bên tham gia hợp đồng phải thực hiện nhằm đáp ứng những quyền tương ứng của bên kia.

2.2.6.1. Nội dung thực hiện hợp đồng

- Đối với hợp đồng đơn vụ, bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng như đã thoả thuận, chỉ được thực hiện trước hoặc sau thời hạn nếu được bên có quyền đồng ý.

- Trong hợp đồng song vụ, khi các bên đã thoả thuận thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì mỗi bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn; không được hoãn thực hiện với lý do bên kia chưa thực hiện nghĩa vụ đối với mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 411 và Điều 413 của BLDS năm 2015. Trường hợp các bên không thoả thuận bên nào thực hiện nghĩa vụ trước thì các bên phải đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhau; nếu nghĩa vụ không thể thực hiện đồng thời thì nghĩa vụ nào khi thực hiện mất nhiều thời gian hơn thì nghĩa vụ đó phải được thực hiện trước.

- Bên phải thực hiện nghĩa vụ trước có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ, nếu khả năng thực hiện nghĩa vụ của bên kia đã bị giảm sút nghiêm trọng đến mức không thể thực hiện được nghĩa vụ như đã cam kết cho đến khi bên kia có khả năng thực hiện được nghĩa vụ hoặc có biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Bên

phải thực hiện nghĩa vụ sau có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ đến hạn nếu bên thực hiện nghĩa vụ trước chưa thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn.

- Trong hợp đồng song vụ, khi một bên không thực hiện được nghĩa vụ của mình do lỗi của bên kia thì có quyền yêu cầu bên kia vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình hoặc huỷ bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nếu một bên không thực hiện được nghĩa vụ mà các bên đều không có lỗi thì bên không thực hiện được nghĩa vụ không có quyền yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ đối với mình. Trường hợp một bên đã thực hiện được một phần nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu bên kia thực hiện phần nghĩa vụ tương ứng đối với mình.

- Khi thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba thì người thứ ba có quyền trực tiếp yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình; nếu các bên trong hợp đồng có tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng thì người thứ ba không có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cho đến khi tranh chấp được giải quyết. Bên có quyền cũng có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.

- Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án: Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định; Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Tòa án chỉ được quyết định việc sửa đổi hợp đồng trong trường hợp việc chấm dứt hợp đồng sẽ gây thiệt hại lớn hơn so với các chi phí để thực hiện hợp đồng nếu được sửa đổi.

2.2.6.2. Giải thích hợp đồng

Điều 404 BLDS năm 2015 quy định những nguyên tắc cụ thể cho việc giải thích hợp đồng như sau:

- Khi hợp đồng có điều khoản không rõ ràng thì việc giải thích điều khoản đó không chỉ dựa vào ngôn từ của hợp đồng mà còn phải căn cứ vào ý chí của các bên được thể hiện trong toàn bộ quá trình trước, tại thời điểm xác lập, thực hiện hợp đồng.

- Khi hợp đồng có điều khoản hoặc ngôn từ có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì phải giải thích theo nghĩa phù hợp nhất với mục đích, tính chất của hợp đồng.

- Khi hợp đồng có điều khoản hoặc ngôn từ khó hiểu thì phải được giải thích theo tập quán tại địa điểm giao kết hợp đồng.

- Các điều khoản trong hợp đồng phải được giải thích trong mối liên hệ với nhau, sao cho ý nghĩa của các điều khoản đó phù hợp với toàn bộ nội dung hợp đồng.

- Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa ý chí chung của các bên với ngôn từ sử dụng trong hợp đồng thì ý chí chung của các bên được dùng để giải thích hợp đồng.

- Trường hợp bên soạn thảo đưa vào hợp đồng nội dung bất lợi cho bên kia thì khi giải thích hợp đồng phải theo hướng có lợi cho bên kia.

2.2.6.3. Sửa đổi nội dung hợp đồng

Hợp đồng dân sự được giao kết và có hiệu lực pháp lý nhưng do điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của mỗi bên mà các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong trường hợp hợp đồng được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực, đăng ký thì việc sửa đổi hợp đồng cũng phải tuân theo hình thức đó.

2.2.7. Vi phạm hợp đồng và trách nhiệm pháp lý

2.2.7.1. Khái niệm

Vi phạm hợp đồng là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

2.2.7.2. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng là một loại của trách nhiệm dân sự và cũng là một trong những trách nhiệm pháp lý nên có những đặc điểm sau đây:

- Được áp dụng chỉ khi có hành vi vi phạm pháp luật, và chỉ đối với người có hành vi vi phạm đó.

- Là biểu hiện sự cưỡng chế của Nhà nước đối với hành vi vi phạm và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng.

- Bao giờ cũng là hậu quả bất lợi cho bên có hành vi vi phạm pháp luật.

Về nguyên tắc, khi một bên vi phạm hợp đồng thì bên kia được áp dụng các hình thức trách nhiệm mà pháp luật quy định. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hành vi vi phạm hợp đồng của một bên là do sự tác động của các yếu tố khách quan, nằm ngoài mong muốn của bên vi phạm. Để đảm bảo cho việc áp dụng trách nhiệm do vi phạm hợp đồng hợp lý và có hiệu quả, pháp luật quy định trong các trường hợp sau đây, bên vi phạm hợp đồng sẽ được miễn trừ trách nhiệm:

- Xảy ra sự kiện bất khả kháng.

- Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thỏa thuận.

- Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia.

- Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

2.2.7.3. Các hình thức trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

a. Buộc thực hiện đúng hợp đồng

Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng xây dựng đã ký kết hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh.

b. Phạt vi phạm hợp đồng

Phạt vi phạm hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận.

Căn cứ áp dụng: Phạt vi phạm chỉ áp dụng trong trường hợp các bên trong hợp đồng có thoả thuận về việc áp dụng chế tài này.

c. Bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm. Tổn thất phải bồi thường bao gồm những tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

d. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng

Tạm ngừng thực hiện hợp đồng là việc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng.

Hậu quả pháp lý của việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng: Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực; Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu BTTH theo quy định của pháp luật.

e. Đình chỉ thực hiện hợp đồng

Đình chỉ thực hiện hợp đồng là việc một bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thực hiện hợp đồng: Khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo đình chỉ. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán hoặc thực hiện nghĩa vụ đối ứng; Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

f. Huỷ bỏ hợp đồng

Huỷ bỏ hợp đồng là việc một bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và làm cho hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết.

Hậu quả pháp lý của việc huỷ bỏ hợp đồng: Sau khi huỷ bỏ, hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng, trừ các thoả thuận về các quyền và nghĩa vụ sau khi huỷ bỏ hợp đồng và giải quyết tranh chấp. Các bên có quyền đòi lại lợi ích do việc đã thực hiện phần nghĩa vụ của mình; trường hợp không thể hoàn trả bằng chính lợi ích đã nhận thì bên có nghĩa vụ phải hoàn trả bằng tiền; Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

2.2.8. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tranh chấp hợp đồng là những mâu thuẫn, bất đồng về lợi ích giữa các bên tham gia quan hệ hợp đồng đó.

Tranh chấp phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết bằng các phương thức sau đây:

- Thương lượng giữa các bên.
- Hòa giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hòa giải.
- Giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án.

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

2.3. Chế độ pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

2.3.1. Khái niệm và đặc điểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

2.3.1.1. Khái niệm

Trong lịch sử pháp luật thế giới, chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đã có từ rất lâu. Việc quy định về người phải bồi thường, cách thức bồi thường, mức độ bồi thường... ở các nước khác nhau phụ thuộc vào quan điểm giai cấp, điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.

Các bộ luật cổ của Việt Nam cũng đã có quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tuy nhiên còn mang nặng tính chất hình sự. Do sự phát triển của xã hội, các chế định pháp luật cũng dần thay đổi, trách nhiệm bồi thường thiệt hại không còn được coi là hình phạt mà là nghĩa vụ, bổn phận của người gây thiệt hại phải bồi thường cho người bị thiệt hại nhằm phục hồi tình trạng tài sản của người bị thiệt hại.

Pháp luật Việt Nam không đưa ra khái niệm cụ thể về trách nhiệm bồi thường thiệt hại (BTTH) cũng như khái niệm trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng mà chỉ nêu lên căn cứ phát sinh trách nhiệm, nguyên tắc bồi thường, năng lực chịu trách nhiệm, thời hạn hưởng bồi thường...

Tiếp cận dưới góc độ khoa học pháp lý chúng ta thấy rằng, mỗi người sống trong xã hội đều phải tôn trọng quy tắc chung của xã hội, không thể vì lợi ích của mình mà xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Khi một người vi phạm nghĩa vụ pháp lý của mình gây tổn hại cho người khác thì chính người đó phải chịu bất lợi do hành vi của mình gây ra. Sự gánh chịu một hậu quả bất lợi bằng việc bù đắp tổn thất cho người khác được hiểu là BTTH. Như vậy, có thể hiểu *trách nhiệm BTTH là một loại trách nhiệm Dân sự mà theo đó thì khi một người vi phạm nghĩa vụ pháp lý của mình gây tổn hại cho người khác phải bồi thường những tổn thất mà mình gây ra.*

Điều 584 BLDS 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

“1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Từ quy định trên, có thể nêu khái niệm về nghĩa vụ bồi thường thiệt hại như sau:

- Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại là một loại quan hệ dân sự trong đó người xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp của người khác mà gây ra thiệt hại phải bồi thường những thiệt hại do mình gây ra.

- Chủ thể tham gia trong quan hệ nghĩa vụ (người bị thiệt hại - người có quyền; người gây thiệt hại – người có nghĩa vụ) này có thể là: công dân, pháp nhân, tổ gia đình, tổ hợp tác, ngoài ra trong một số trường hợp, các cơ quan nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng cũng có thể trở thành bên có quyền hoặc bên có nghĩa vụ. Bên có quyền cũng như bên có nghĩa vụ có thể có một hoặc nhiều người tham gia. Nghĩa vụ, quyền của họ có thể là liên đới, riêng rẽ hoặc theo phần tùy điều kiện hoàn cảnh và đối tượng bị xâm hại.

- Khách thể của quan hệ nghĩa vụ bồi thường thể hiện dưới dạng “hành động” phải thực hiện hành vi “bồi thường” cho người bị thiệt hại. Cơ sở phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại là sự kiện “gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật” cho các chủ thể khác. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại thể hiện trong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại được gọi là trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng:

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại (BTTH) ngoài hợp đồng là loại trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với người có hành vi trái pháp luật xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm đến danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà trước đó giữa các bên hoàn toàn không có quan hệ hợp đồng hoặc

có quan hệ hợp đồng nhưng hành vi gây thiệt hại không liên quan đến các hành vi thực tế hợp đồng.

Ý nghĩa của việc quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

- Bảo đảm việc đền bù tổn thất đã gây ra cho người bị thiệt hại;
- Giáo dục mọi người về ý thức tuân thủ pháp luật, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

2.3.1.2. Đặc điểm của trách nhiệm BTTH

Là một loại trách nhiệm pháp lý nên ngoài những đặc điểm của trách nhiệm pháp lý nói chung như do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng, áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật, luôn mang đến hậu quả bất lợi cho người bị áp dụng, được đảm bảo thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước.... thì trách nhiệm BTTH còn có những đặc điểm riêng sau đây:

– Về cơ sở pháp lý: Trách nhiệm BTTH là một loại trách nhiệm Dân sự và chịu sự điều chỉnh của pháp luật Dân sự. Khi một người gây ra tổn thất cho người khác thì họ phải bồi thường thiệt hại và bồi thường thiệt hại chính là một quan hệ tài sản do Luật Dân sự điều chỉnh.

– Về điều kiện phát sinh: trách nhiệm BTTH chỉ đặt ra khi thoả mãn các điều kiện nhất định đó là: Có thiệt hại xảy ra, có hành vi vi phạm nghĩa vụ dân sự (nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng), có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại với thiệt hại xảy ra, có lỗi của người gây thiệt hại (không phải là điều kiện bắt buộc). Đây là những điều kiện chung nhất để xác định trách nhiệm của một người phải bồi thường những thiệt hại do mình gây ra. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt trách nhiệm BTTH có thể phát sinh khi không có đủ các điều kiện trên điển hình là các trường hợp bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra.

– Về hậu quả: trách nhiệm BTTH luôn mang đến một hậu quả bất lợi về tài sản cho người gây thiệt hại. Bởi lẽ, khi một người gây ra tổn thất cho người khác thì tổn thất đó phải tính toán được bằng tiền hoặc phải được pháp luật quy định là một đại lượng vật chất nhất định nếu không sẽ không thể thực hiện được việc bồi thường. Do đó, những thiệt hại về tinh thần mặc dù không thể tính toán được nhưng cũng sẽ được xác định theo quy định của pháp luật để bù đắp lại tổn thất cho người bị thiệt hại. Và cũng chính vì vậy, thực hiện trách nhiệm bồi thường sẽ giúp khôi phục lại thiệt hại cho người bị thiệt hại.

– Về chủ thể bị áp dụng trách nhiệm: Ngoài người trực tiếp có hành vi gây thiệt hại thì trách nhiệm BTTH còn được áp dụng cả đối với những chủ thể khác đó là cha, mẹ của người chưa thành niên, người giám hộ của người được giám hộ, pháp nhân đối với người của pháp nhân gây ra thiệt hại, trường học, bệnh viện trong trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự gây

thiệt hại hoặc tổ chức khác như cơ sở dạy nghề...

2.3.2. Căn cứ phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng

Căn cứ phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng là những yếu tố, những cơ sở để xác định trách nhiệm bồi thường, người phải bồi thường, người được bồi thường và mức độ bồi thường. Xuất phát từ những quy định, nguyên tắc của pháp luật dân sự, trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng chỉ phát sinh khi có đủ các căn cứ sau:

- ***Phải có thiệt hại xảy ra;***
- ***Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật;***
- ***Có mối liên hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi trái pháp luật.***

a. Phải có thiệt hại xảy ra

Thiệt hại là những tổn thất thực tế được tính thành tiền do việc xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, tài sản của cá nhân, tổ chức.

- Thiệt hại về tài sản, biểu hiện cụ thể là mất tài sản, giảm sút tài sản, những chi phí để ngăn chặn, hạn chế, thay thế, những lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác công dụng của tài sản;

- Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe làm phát sinh các thiệt hại về vật chất bao gồm các chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng bị mất, bị giảm sút do thiệt hại về tính mạng, sức khỏe; chi phí hợp lý cho việc mai táng phù hợp với phong tục, tập quán; tiền cấp dưỡng cho những người mà người chết có nghĩa vụ phải cấp dưỡng (con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động); một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa là 50 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định;

- Thiệt hại do uy tín, nhân phẩm bị xâm hại bao gồm: chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại. Những thiệt hại về tinh thần về nguyên tắc không thể giá trị được bằng tiền và không thể phục hồi được. Tuy nhiên, với mục đích an ủi, động viên đối với người bị thiệt hại trách nhiệm BTTH vẫn được đặt ra trong trường hợp này. Mức bù đắp tối đa trong trường hợp hai bên không tự thỏa thuận được là 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

b. Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật

Quyền được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, tài sản là một quyền tuyệt đối của mọi công dân, tổ chức. Mọi người đều phải tôn trọng những quyền đó của chủ thể khác, không được thực hiện bất cứ hành vi nào xâm phạm

đến các quyền tuyệt đối đó. Việc xâm phạm mà gây thiệt hại có thể là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, dân sự, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước... Hành vi gây thiệt hại có thể là hành vi hợp pháp nếu người thực hiện hành vi đó theo nghĩa vụ mà pháp luật hoặc nghề nghiệp buộc họ phải làm. *Vd: công an gây thiệt hại tài sản khi truy bắt tội phạm, bác sỹ cắt bỏ các bộ phận trên cơ thể bị bệnh... gây thiệt hại trong trường hợp phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết...* Đối với những hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại phải bồi thường.

c. Có mối liên hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi trái pháp luật

Thiệt hại xảy ra là kết quả của hành vi trái pháp luật hay ngược lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân của thiệt hại xảy ra. Việc xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra trong nhiều trường hợp rất khó khăn. Vì vậy cần phải xem xét, phân tích đánh giá tất cả các sự kiện liên quan một cách thận trọng, khách quan và toàn diện, từ đó mới có thể rút ra được kết luận chính xác về nguyên nhân, xác định đúng trách nhiệm của người gây ra thiệt hại.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định ngay khi có yếu tố thiệt hại xảy ra trên thực tế, có hành vi trái pháp luật và có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế với hành vi trái pháp luật mà không cần xem xét người gây thiệt hại có lỗi hay không có lỗi. Tuy nhiên, mặc dù yếu tố lỗi không tồn tại trong danh sách các căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nhưng lỗi vẫn có giá trị trong việc xem xét mức độ thiệt hại được bồi thường.

2.3.3. Năng lực, nguyên tắc bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ hạn chế tổn thất và vấn đề xác định thiệt hại.

a. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Người gây thiệt hại có thể là bất kỳ ai: cá nhân, pháp nhân, cơ quan nhà nước... nhưng việc bồi thường phải do người có “khả năng” bồi thường. Theo quy định tại Điều 586 BLDS 2015 thì:

Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi đầy đủ phải tự bồi thường thiệt hại do họ gây ra. Trong trường hợp người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ nhưng không có tài sản để bồi thường, Tòa án sẽ động viên cha mẹ bồi thường thay họ để kịp thời khắc phục thiệt hại xảy ra. Trong trường hợp này, người gây thiệt hại là bị đơn trong vụ án dân sự.

Người dưới 18 tuổi không có hoặc không có đủ năng lực hành vi, khi đó cha mẹ là người phải bồi thường thiệt hại do con họ gây ra. Nếu người chưa đủ 15 tuổi, cha mẹ phải dùng tiền của mình để bồi thường; nếu cha mẹ không đủ để bồi thường mà con có tài sản riêng thì lấy thêm tài sản của con. Nếu người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì lấy tài sản riêng của con bồi thường nếu con có, nếu thiếu thì mới bổ sung bằng tài sản của bố mẹ.

Theo nguyên tắc loại trừ thì người từ đủ 15 – 18 tuổi không còn cha mẹ, cha mẹ mất năng lực hành vi không buộc phải có người giám hộ. Trong trường hợp họ gây ra thiệt hại mà không có bất kỳ tài sản nào để bồi thường cũng như không có người giám hộ thì không phải bồi thường thiệt hại.

Người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại trong thời gian ở trường học, bệnh viện quản lý thì trường học, bệnh viện phải liên đới cùng cha mẹ, người giám hộ bồi thường. Nếu các tổ chức đó không có lỗi thì cha mẹ, người giám hộ phải bồi thường.

Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

b. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ hạn chế tổn thất

Nguyên tắc chung là phải bồi thường *toàn bộ*. Bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi trái pháp luật gây ra là nguyên tắc công bằng, phù hợp để khắc phục được tình trạng tài sản bị thiệt hại một cách tốt nhất. Cần phải tôn trọng thỏa thuận của các bên về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, hiện vật, hay công việc, phương thức bồi thường một lần hay nhiều lần nếu thỏa thuận đó không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Để đảm bảo tính dễ dàng thực hiện của bản án, quyết định của Tòa án, phù hợp với những điều kiện thực tế của đương sự, nguyên tắc “*giảm mức bồi thường*” được quy định. Việc giải quyết mức bồi thường phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh, mức độ lỗi của người bị thiệt hại, người gây thiệt hại. Tòa án căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để quyết định giảm mức bồi thường. Tuy nhiên, Tòa chỉ chấp nhận giải quyết giảm mức bồi thường thiệt hại khi có các điều kiện sau: thứ nhất, không có lỗi hoặc do lỗi vô ý mà gây thiệt hại; thứ hai: thiệt hại xảy ra quá lớn cho với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài, có nghĩa là thiệt hại xảy ra so với hoàn cảnh thực tế trước mắt và lâu dài của họ là không có khả năng bồi thường. Khái niệm “quá lớn” không được quy định ở mức cụ thể nào bởi cùng thiệt hại với một đại lượng không đổi, đối với người này là rất lớn nhưng đối với người khác lại là không lớn.

Mức bồi thường thiệt hại có thể do các bên thỏa thuận hoặc do TA quyết định. Tuy nhiên, mức bồi thường đó cũng có thể thay đổi, nếu mức bồi thường “không còn phù hợp với thực tế”. Mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế có nghĩa là do sự thay đổi về kinh tế, xã hội, sự biến động về giá cả mà mức bồi thường đang được thực hiện không còn phù hợp trong điều kiện đó hoặc do có sự thay đổi về thương tật, khả năng lao động của người bị thiệt hại nên mức bồi

thường không còn phù hợp với sự thay đổi sự thay đổi đó hoặc do có sự thay đổi về khả năng kinh tế của người gây thiệt hại. Việc xem xét tăng hay giảm mức bồi thường do Tòa án xác định theo yêu cầu của các bên.

Khoản 4 Điều 585 BLDS 2015 quy định: "Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại do chính mình". Quy định trên góp phần nâng cao ý thức cũng như thiện chí giữa các bên nhằm hạn chế tối đa thiệt hại thực tế xảy ra. Việc hạn chế thiệt hại trong điều kiện có thể không những có lợi cho người có hành vi xâm phạm mà còn cho chính người bị thiệt hại. Nhìn từ góc độ kinh tế, việc thừa nhận trách nhiệm hạn chế thiệt hại đem lại lợi ích cho cả xã hội: hạn chế được thiệt hại cho nạn nhân, cho người có hành vi gây thiệt hại (do không phải bồi thường) nên kết quả là có lợi cho cả xã hội.

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm kể từ ngày biết hoặc buộc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm

c. Xác định thiệt hại

Thiệt hại là điều kiện đầu tiên làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường. Xác định thiệt hại là một việc rất khó khăn và phức tạp. Tại Mục 2 Chương XX Bộ luật Dân sự 2015 quy định về các loại thiệt hại được bồi thường và cách thức xác định thiệt hại một cách khái quát như sau:

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm gồm: Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; Thiệt hại khác do luật quy định.

Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại; Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại; Thiệt hại khác do luật quy định.

Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: Chi phí hợp lý cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; Thiệt hại khác do luật quy định. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho

một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm: Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Thiệt hại khác do luật quy định. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

2.3.4. Bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể

2.3.4.1. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Khái niệm phòng vệ chính đáng: Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.

Hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng được hiểu là khi bị người khác gây thiệt hại, người phòng vệ chính đáng đã có hành vi gây thiệt hại ngược lại nhưng có sự sai lầm trong việc đánh giá mức độ của sự tấn công, điều kiện hoàn cảnh của hành vi tấn công và hành vi chống trả do đó vượt quá giới hạn cần thiết nên đã gây thiệt hại cho người có hành vi gây thiệt hại ban đầu. Việc vượt quá giới hạn đó bị coi là trái pháp luật.

Việc xác định một hành vi gây thiệt hại được coi là phòng vệ chính đáng phải dựa trên các căn cứ sau:

- Thứ nhất: có hành vi trái pháp luật xâm phạm tới lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc xâm phạm tới lợi ích của chính bản thân người phòng vệ chính đáng;
- Thứ hai: hành vi trái pháp luật của người khác đang gây thiệt hại hoặc có nguy cơ gây thiệt hại cho đối tượng bị xâm phạm. Nếu thiệt hại đã xảy ra mà người bị thiệt hại mới có hành vi chống trả và gây thiệt hại trở lại thì không thể coi là phòng vệ chính đáng;
- Thứ ba: hành vi phòng vệ chính đáng phải gây thiệt hại cho chính người có hành vi xâm phạm (tính mạng, sức khỏe, tài sản của người có hành vi xâm phạm), nếu gây thiệt hại cho người không có hành vi xâm phạm thì không coi là phòng vệ chính đáng mà có thể coi là gây thiệt hại do yêu cầu của tình thế cấp thiết nếu thỏa mãn các điều kiện nhất định;

- Thứ tư: hành vi gây thiệt hại trong trường hợp phòng vệ chính đáng phải là cần thiết và tương xứng với hành vi xâm phạm thiệt hại, nếu không cần thiết hoặc không tương xứng thì người gây thiệt hại vẫn phải bồi thường thiệt hại.

Vì phòng vệ chính đáng không bị coi là trái pháp luật, người phòng vệ chính đáng không bị coi là có lỗi nên pháp luật dân sự quy định người phòng vệ chính đáng không phải bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, nếu người phòng vệ chính đáng gây thiệt hại mà thiệt hại đó là hậu quả của hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì người này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi của mình gây ra.

2.3.4.2. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết

Khái niệm tình thế cấp thiết: Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn cần phải ngăn ngừa.

Hành vi gây thiệt hại được coi là gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết và người gây thiệt hại không phải bồi thường thiệt hại khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Thứ nhất: có một nguy cơ đang thực tế đe dọa cho lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Tình thế cấp thiết chỉ là nguy cơ đe dọa gây thiệt hại nhưng thiệt hại chưa xảy ra.

- Thứ hai: Nguy cơ phải có thực, tức là phải đang bắt đầu, đang diễn ra và chưa kết thúc.

- Thứ ba: Nguy cơ đang đe dọa lợi ích được pháp luật bảo vệ, những lợi ích này phải hợp pháp.

- Thứ tư: Việc gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết là biện pháp tốt nhất để ngăn chặn thiệt hại có nguy cơ xảy ra.

- Thứ năm: Thiệt hại trong tình thế cấp thiết phải là thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Trong trường hợp người gây thiệt hại vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, tức là không thỏa mãn điều kiện thứ năm, thì họ phải bồi thường thiệt hại cho phần vượt quá. Người đã gây ra tình thế cấp thiết dẫn đến thiệt hại xảy ra phải bồi thường cho người bị thiệt hại

2.3.4.3. Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra là trách nhiệm liên đới bồi thường của những người cùng gây thiệt hại. Trách nhiệm BTTH liên đới của nhiều người chỉ phát sinh khi có đủ 4 điều kiện sau:

- Thứ nhất: có hành vi gây thiệt hại của nhiều người. Thiệt hại xảy ra phải do nhiều người cùng thực hiện. Người gây thiệt hại có thể là cá nhân, pháp nhân hoặc bất cứ chủ thể nào khác nhưng phải từ 2 chủ thể trở lên.

- Thứ hai: hành vi gây thiệt hại của nhiều người có sự thống nhất. Mặc dù hành vi gây thiệt hại của nhiều người nhưng không phải có nhiều người gây thiệt hại thì phát sinh trách nhiệm liên đới. Để phát sinh trách nhiệm liên đới giữa họ phải có sự thống nhất về hành vi gây thiệt hại, mức độ gây thiệt hại của từng người có thể khác nhau.

- Thứ ba: hành vi gây thiệt hại của nhiều người gây thiệt hại có thể khác nhau về mức độ nhưng cùng đem lại hậu quả cho người bị thiệt hại.

- Thứ tư: phải có lỗi của những người cùng gây thiệt hại, không kể là lỗi vô ý hay cố ý.

Tóm lại, khi hành vi gây thiệt hại thỏa mãn 4 điều kiện trên thì phát sinh trách nhiệm liên đới bồi thường của những người cùng gây thiệt hại. Việc bồi thường của mỗi người tương ứng với mức độ lỗi họ gây ra. Nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.

2.3.4.4. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Khái niệm nguồn nguy hiểm cao độ: Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

- Phương tiện giao thông vận tải cơ giới: hiện nay chưa có một văn bản pháp luật chính thức nào đưa ra khái niệm “phương tiện giao thông vận tải cơ giới”. Theo Luật Giao thông đường bộ thì phương tiện giao thông vận tải cơ giới đường bộ gồm: xe ô tô, máy kéo, xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự kể cả xe cơ giới dành cho người tàn tật...

- Hệ thống tải điện được hiểu là dây truyền dẫn điện, mô tơ, máy phát điện, cầu dao...; nhà máy công nghiệp như nhà máy công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ... cũng như phương tiện giao thông vận tải cơ giới chỉ được coi là nguồn nguy hiểm cao độ khi nó “đang hoạt động”, điều đó có nghĩa là nếu nó đang ở trạng thái tĩnh thì không tạo nguy hiểm cho những người xung quanh.

- Vũ khí bao gồm: vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn, công cụ hỗ trợ...

- Chất cháy, chất nổ là chất lỏng, chất khí, chất rắn... dễ gây cháy nổ. Cháy cháy có đặc tính tự bốc cháy khi tiếp xúc với oxy trong không khí, nước hoặc dưới tác động của các yếu tố khác ở nhiệt độ cao hoặc không cao (diêm, phốt pho, xăng dầu...).

- Chất độc là những chất có độc tính cao, rất nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng của con người, động vật, cũng như đối với môi trường xung quanh (kẽm photpho, nicotin...)

- Thú dữ là động vật bậc cao, có lông mao, có tuyến vú, nuôi con bằng sữa, lớn, rất dữ, có thể làm hại người.

Trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra được xác định như sau:

- Thiệt hại phải do chính nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Vd: thú đang biểu diễn xiếc thì nhảy ra gây thiệt hại cho khán giả...

- Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Người được chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, trừ trường hợp giữa chủ sở hữu và người được giao chiếm hữu, sử dụng có thỏa thuận khác không trái pháp luật, đạo đức xã hội hoặc không nhằm trốn tránh việc bồi thường.

Ví dụ: Các thỏa thuận sau đây là không trái pháp luật, đạo đức xã hội hoặc không nhằm trốn tránh việc bồi thường:

- + Thỏa thuận cùng nhau liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;
- + Thỏa thuận chủ sở hữu bồi thường thiệt hại trước, sau đó người được giao chiếm hữu, sử dụng sẽ hoàn trả cho chủ sở hữu khoản tiền đã bồi thường;
- + Thỏa thuận ai có điều kiện về kinh tế hơn thì người đó thực hiện việc bồi thường thiệt hại trước.

- Khi nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì người đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại. Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Theo nguyên tắc chung, chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra ngay cả khi không có lỗi, trừ các trường hợp sau **(các trường hợp loại trừ nghĩa vụ bồi thường)**:

- Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

Ví dụ: xe ô tô tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật thì bất ngờ có người lao vào xe để tự tử và hậu quả là người này bị chết;

- Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nếu trong trường hợp pháp luật có quy định khác về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết thì trách nhiệm bồi

thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật đó.

2.4. Chế độ pháp lý về quyền sở hữu

2.4.1. Quyền sở hữu tài sản

2.4.1.1. Khái niệm tài sản và quyền sở hữu

Quyền sở hữu chỉ ra đời khi xã hội có sự phân chia giai cấp và có nhà nước. Pháp luật về sở hữu được đặt ra nhằm mục đích xác nhận và bảo vệ bằng pháp luật việc chiếm giữ những tư liệu sản xuất chủ yếu của giai cấp thống trị cũng như bảo vệ những quan hệ sở hữu phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị, tạo điều kiện pháp lý cần thiết bảo đảm cho giai cấp thống trị khai thác được nhiều nhất những tư liệu sản xuất đang chiếm hữu. Chính vì vậy, có thể hiểu quyền sở hữu là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội pháp sinh trong lĩnh vực chiếm hữu, sử dụng và định đoạt các tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, những tài sản khác theo quy định của pháp luật (**là mức độ xử sự mà pháp luật cho phép chủ sở hữu được thực hiện trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của mình**).

Quan hệ dân sự về sở hữu cũng như các quan hệ pháp luật dân sự khác bao gồm những yếu tố cấu thành quan hệ đó là : chủ thể, khách thể và nội dung quyền sở hữu. Ba yếu tố trên thường có mối quan hệ khăng khít, thiếu một trong các yếu tố đó thì không thể hình thành quan hệ pháp luật dân sự về sở hữu.

• Chủ thể của quyền sở hữu

Chủ thể của quyền sở hữu là những người tham gia quan hệ pháp luật dân sự về sở hữu. Chủ sở hữu trong luật dân sự rất đa dạng tương ứng với các hình thức sở hữu, bao gồm :

- Nhà nước là chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân ;
- Các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội , các tập thể ;
- Các công dân, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các tổ chức kinh tế tư nhân...

Để trở thành chủ sở hữu, trong một số trường hợp pháp luật dân sự quy định phải có những điều kiện nhất định :

Đối với công dân : phải có năng lực pháp luật (có từ khi sinh ra – và mất đi khi người đó chết), trong một số trường hợp phải có năng lực hành vi ;

Đối với những tài sản vô hình (quyền sở hữu trí tuệ): chủ thể có quyền sở hữu là những người được pháp luật dân sự công nhận;

Có những tài sản Nhà nước quy định chỉ thuộc quyền sở hữu của những chủ thể riêng biệt như : Tài sản thuộc sở hữu Nhà nước bao gồm : đất đai, rừng tự nhiên, rừng trồng có vốn từ ngân sách nhà nước, núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất...

- **Khách thể của quyền sở hữu**

Khách thể của quyền sở hữu có thể là đối tượng của thế giới vật chất hoặc là kết quả những hoạt động sáng tạo tinh thần.

Tài sản với tư cách là khách thể của quyền sở hữu đã được xác định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 gồm: vật, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản.

- Vật được coi là khách thể của quyền sở hữu phải là một vật có thực có nghĩa là vật đó phải tồn tại hiện hữu hoặc là những vật chắc chắn sẽ có. Vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng. Ngoài việc phân loại vật thành động sản và bất động sản, BLDS còn có những cách phân loại vật như sau :

+ Hoa lợi, lợi tức : Hoa lợi là những sản vật tự nhiên có tính chất hữu ích do tài sản mang lại cho chủ sở hữu ; Lợi tức là khoản lợi mà chủ sở hữu thu được từ việc khai thác công dụng của tài sản ;

+ Vật chính, vật phụ : Vật chính là vật thể độc lập, có thể khai thác công dụng theo tính năng ; Vật phụ là vật trực tiếp phục vụ cho việc khai thác công dụng của vật chính ;

+ Vật chia được và vật không chia được : Vật chia được là những vật khi được phân chia thành các phần nhỏ thì mỗi phần đó vẫn giữ nguyên các tính chất ban đầu và giữ nguyên tính năng sử dụng của vật đó (vd : xăng, dầu, gạo..) ; Vật không chia được là những vật khi phân chia thành những phần nhỏ, nó không còn giữ được tính chất và tính năng sử dụng ban đầu (vd : xe máy, đồng hồ...). Trong quan hệ dân sự, việc phân loại vật chia được và không chia được chỉ mang tính chất tương đối.

+ Vật tiêu hao và không tiêu hao: Vật tiêu hao là những vật qua một lần sử dụng thì mất đi hoặc không còn dự nguyên được hình dạng, tính chất ban đầu ; Vật không tiêu hao là những vật mà khi đã qua quá trình sử dụng nhiều lần mà cơ bản vẫn giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu ;

+ Vật cùng loại và vật đặc định: Vật cùng loại là những vật có cùng hình dáng, tính chất ; Vật đặc định là những vật có thể phân biệt với vật khác bằng các dấu hiệu đặc trưng riêng biệt, trong vật đặc định, người ta xác định vật độc nhất và vật đặc định hóa.

- Quyền tài sản là quyền giá trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao lưu dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ.

Tài sản có thể được phân loại thành động sản và bất động sản. Theo đó, Bất động sản bao gồm: đất đai, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; tài sản khác gắn liền với đất đai, các tài sản khác do quy định của pháp luật. Động sản là những tài sản không phải bất động sản.

2.4.1.2. Các căn cứ xác lập quyền sở hữu

Pháp luật chỉ công nhận và bảo vệ các quyền của chủ sở hữu nếu quyền đó được xác lập trên những căn cứ do pháp luật quy định. Căn cứ xác lập quyền sở hữu là những sự kiện pháp lý do BLDS quy định. Dựa vào nguồn gốc của những sự kiện pháp lý người ta có thể phân chia làm các nhóm sau:

- Xác lập theo hợp đồng

Các hợp đồng mua bán, tặng, cho, cho vay, v.v.v. nếu được xác lập phù hợp với quy định của BLDS thì những người chuyển giao tài sản thông qua các giao dịch hợp pháp có quyền sở hữu các tài sản đó. Những tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký, sang tên, xin phép thì quyền sở hữu được xác lập kể từ thời điểm hoàn tất các thủ tục đó.

- Xác lập theo quy định của pháp luật như: thu nhập hợp pháp; do các sự kiện sát nhập, trộn lẫn, chế biến là sự hợp nhất tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau (trường hợp chế biến mà người chế biến đã dùng nguyên vật liệu không thuộc sở hữu của mình nhưng ngay tình thì quyền sở hữu đối với tài sản mới được xác lập khi đã thanh toán giá trị nguyên vật liệu cho chủ sở hữu nguyên vật liệu đó); do các sự kiện không xác định được chủ sở hữu hoặc do bị chôn giấu, đánh rơi, bỏ quên; do các sự kiện gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc, do được thừa kế;

- Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản được hình thành do hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. Về bản chất đây là các tài sản được tạo ra do lao động trí tuệ, tuy nhiên không phải các sản phẩm nào của lao động trí tuệ cũng được coi là tài sản mà để công nhận và bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện do Luật Sở hữu trí tuệ quy định

- Xác lập theo căn cứ riêng biệt khác (bản án, quyết định của tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Chủ thể chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai được áp dụng thời hiệu hưởng quyền và được hưởng hoa lợi, lợi tức mà tài sản mang lại theo quy định của luật Dân sự và các luật khác có liên quan.

2.4.1.3. Nội dung của quyền sở hữu tài sản

Quyền sở hữu bao gồm: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Đây là những quyền dân sự cụ thể của chủ sở hữu hay còn gọi là quyền dân sự chủ quan.

a. Quyền chiếm hữu

Quyền chiếm hữu là quyền năng của chủ sở hữu tự mình nắm giữ, quản lý tài sản thuộc sở hữu. Đó cũng là quyền kiểm soát, làm chủ và chi phối vật đó theo ý chí của mình, không bị hạn chế và gián đoạn về thời gian.

Chủ sở hữu thường tự mình bằng các hành vi của bản thân để thực hiện quyền chiếm hữu tài sản hay còn gọi là quyền chiếm hữu thực tế. Trong một số trường hợp, chủ sở hữu chuyển quyền này cho người khác thông qua một hợp đồng dân sự theo ý chí của họ hoặc không theo ý chí của họ như : bị đánh rơi, thất lạc, chôn dấu chưa tìm thấy... Pháp luật vẫn công nhận quyền chiếm hữu của chủ sở hữu dù người đó không trực tiếp nắm giữ và chi phối tài sản. Quyền chiếm hữu của chủ sở hữu chỉ chấm dứt hoàn toàn khi chủ sở hữu từ bỏ quyền chiếm hữu của mình.

Có 2 hình thức chiếm hữu sau : Chiếm hữu có căn cứ pháp luật và chiếm hữu không có căn cứ pháp luật.

Chiếm hữu có căn cứ pháp luật : là hình thức chiếm hữu tài sản một cách hợp pháp (chiếm hữu tài sản của chủ sở hữu). Người không phải là chủ sở hữu tài sản được coi là chiếm hữu hợp pháp khi: Được chủ sở hữu tài sản ủy quyền quản lý tài sản; Được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với ý chí của chủ sở hữu.

Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật bao gồm: chiếm hữu không có căn cứ pháp luật ngay tình và chiếm hữu không có căn cứ pháp luật không ngay tình.

- **Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật ngay tình**: là người chiếm hữu không có căn cứ theo pháp luật nhưng không biết và không thể biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có căn cứ pháp luật.

- **Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật không ngay tình**: là người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật biết đó là chiếm hữu bất hợp pháp hoặc tuy không biết nhưng cần phải biết rằng người chuyển dịch tài sản cho mình là người không có quyền dịch chuyển, hoặc buộc phải biết tài sản đó bị cấm chuyển dịch. *Vd* : người mua biết là của gian nhưng vẫn mua vì giá rẻ.

b. Quyền sử dụng

Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng và khai thác những lợi ích vật chất (hưởng hoa lợi, lợi tức) của tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép. Thông thường, khi chủ sở hữu muốn chuyển quyền sử dụng cho người khác thì phải chuyển luôn quyền chiếm hữu tài sản.

c. Quyền định đoạt

Quyền định đoạt: là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho người khác hoặc từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản.

Chủ sở hữu thực hiện quyền định đoạt biểu hiện ở hai khía cạnh:

- Định đoạt về số phận thực tế của các vật (làm cho vật không còn trong thực tế nữa) như: tiêu dùng hết, hủy bỏ hoặc từ bỏ quyền sở hữu đối với vật;

- Định đoạt về số phận pháp lý của vật là việc chuyển giao quyền sở hữu đối với vật từ người này sang người khác. Thông thường định đoạt về số phận

pháp lý của vật phải thông qua các giao dịch phù hợp với ý chí của chủ sở hữu như : bán, tặng cho, trao đổi, để thừa kế... thông qua việc định đoạt mà chủ sở hữu có thể tiêu dùng hết, chuyển quyền chiếm hữu tạm thời (hợp đồng gửi giữ), chuyển quyền chiếm hữu và quyền sử dụng trong một khoảng thời gian dài hạn (cho thuê, mượn)...

Người định đoạt tài sản phải là người có năng lực hành vi. Chủ sở hữu tài sản có thể ủy quyền cho người khác định đoạt tài sản, người được ủy quyền phải thực hiện việc định đoạt theo phương pháp, cách thức phù hợp với ý chí của chủ sở hữu.

2.4.1.4. Hạn chế quyền sở hữu

Cùng với việc ghi nhận và bảo vệ các quyền năng của quyền sở hữu thì pháp luật cũng quy định một số hạn chế đối với quyền sở hữu của chủ sở hữu nhằm bảo vệ các lợi ích chung của cộng đồng. Các hạn chế này bao gồm:

- Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do an ninh, quốc phòng và vì lợi ích quốc gia nhà nước trưng mua, trưng dụng có bồi thường tài sản cá nhân, pháp nhân hoặc các chủ thể khác theo quy định của pháp luật.

- Trong tình thế cấp thiết, chủ sở hữu không được cản trở người khác dùng tài sản của mình hoặc cản trở người khác gây thiệt hại đối với tài sản đó để ngăn chặn, làm giảm mỗi nguy hiểm hoặc thiệt hại lớn hơn có nguy cơ xảy ra.

- Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu công trình phải tuân theo pháp luật về bảo đảm an toàn, không được xây quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định, không được xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh. Khi có nguy cơ xảy ra sự cố đối với công trình xây dựng, ảnh hưởng đến bất động sản liền kề và xung quanh thì chủ sở hữu công trình phải cho ngừng ngay việc xây dựng, sửa chữa hoặc dỡ bỏ theo yêu cầu, nếu gây thiệt hại phải bồi thường.

- Khi xây dựng công trình vệ sinh, khi chứa hoá chất độc hại và các công trình khác mà việc sử dụng có khả năng gây ô nhiễm môi trường, chủ sở hữu phải xây cách mốc giới một khoảng cách, vị trí hợp lý, phải đảm bảo vệ sinh an toàn không làm ảnh hưởng đến chủ sở hữu liền kề xung quanh. Khi đào giếng, đào ao hoặc xây dựng công trình dưới mặt đất, chủ sở hữu công trình phải đào, xây cách mốc giới một khoảng cách do pháp luật về xây dựng quy định, nếu gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh thì phải bồi thường.

- Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi thuận tiện và hợp lý ra đến đường công cộng, người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề nếu không có thoả thuận khác.

- Trong xây dựng chủ sở hữu nhà xây dựng sau còn bị hạn chế quyền trở cửa ra vào, cửa sổ theo quy định của pháp luật về xây dựng...

- Quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu bị hạn chế khi tài sản bị đem đi làm vật bảo đảm cho thực hiện nghĩa vụ như đặt cọc, thế chấp... Nếu các quan hệ đặt cọc, thế chấp chấm dứt, quyết định kê biên tài sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không còn hiệu lực, thì quyền định đoạt của chủ sở hữu lại được khôi phục. Những tài sản đem bán, đổi là cổ vật, di tích lịch sử văn hóa thì Nhà nước có quyền ưu tiên mua. Trường hợp tổ chức, cá nhân có quyền ưu tiên mua đối với tài sản nhất định theo quy định của pháp luật thì khi bán tài sản, chủ sở hữu phải dành quyền ưu tiên mua cho tổ chức, cá nhân đó.

- Các hạn chế khác theo quy định của pháp luật

2.4.1.5. Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu

Về nguyên tắc chung, những căn cứ xác lập quyền sở hữu cũng đồng thời là những căn cứ chấm dứt quyền sở hữu. Việc chấm dứt quyền sở hữu cũng có thể theo ý chí của chủ sở hữu hoặc do pháp luật quy định.

- Chấm dứt quyền sở hữu theo ý chí của chủ sở hữu;
- Chấm dứt quyền sở hữu theo căn cứ do pháp luật quy định như: tài sản bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu, tài sản bị trưng mua, bị tịch thu, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc mà đã bị người khác xác lập quyền sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Các trường hợp khác mà pháp luật quy định.

2.4.1.6. Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu

Ở Việt Nam, quyền sở hữu được bảo vệ thông qua nhiều biện pháp khác nhau, do nhiều ngành luật điều chỉnh. Trong các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu, biện pháp dân sự có ý nghĩa thực tế nhất vì nó khôi phục lại tình trạng ban đầu về mặt vật chất cho chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu hợp pháp. Bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự là việc chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp, Tòa án hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền chiếm hữu hợp pháp phải trả lại tài sản, chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật việc thực hiện quyền sở hữu, quyền chiếm hữu và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Có các phương thức hợp pháp khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu:

- Tự sử dụng các biện pháp bảo vệ tài sản thuộc sở hữu của mình, tài sản đang được chiếm hữu hợp pháp miễn là không trái pháp luật và đạo đức xã hội;
- Kiện đòi lại tài sản là việc chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp yêu cầu tòa án hoặc người có hành vi chiếm hữu bất hợp pháp phải trả lại tài sản cho mình;
- Kiện yêu cầu ngăn chặn hoặc chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đối với việc thực hiện quyền sở hữu, quyền chiếm hữu hợp pháp. Phương thức kiện

này nhằm bảo đảm để chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu sử dụng và khai thác công dụng của tài sản một cách bình thường;

- Kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại.

2.4.2. Quyền sở hữu công nghiệp

2.4.2.1. Khái niệm và đặc điểm của quyền sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, quyền sử dụng đối với chỉ dẫn địa lý và quyền sở hữu đối với các đối tượng khác do pháp luật quy định.

Quyền sở hữu công nghiệp có những đặc điểm sau đây :

- Bị giới hạn về thời gian. Nhà nước chỉ bảo hộ các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp trong một thời gian nhất định. Thời gian này là thời gian có hiệu lực của văn bằng bảo hộ.

- Đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp mang tính phi vật chất và bị giới hạn về không gian. Chủ sở hữu muốn được Nhà nước bảo hộ thì phải đăng ký và nộp lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ. Trường hợp các đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ tại Việt Nam và ở nước ngoài thì sẽ được pháp luật của nước mà đối tượng đã đăng ký bảo hộ hoặc theo Điều ước quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp mà Việt Nam đã ký kết.

- Tại cùng một thời điểm, các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp được nhiều người cùng sử dụng một cách độc lập.

Quyền sở hữu công nghiệp khác với quyền tác giả, và một đối tượng có thể vừa được bảo hộ dưới dạng quyền sở hữu công nghiệp, vừa được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả. Thí dụ một bộ quần áo thời trang vừa có thể được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả (đối với một tác phẩm tạo hình), vừa được bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp (nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng độc quyền bảo hộ). Quyền sở hữu công nghiệp có thể phân biệt với quyền tác giả dựa vào một số tính chất như sau:

Thứ nhất là quyền sở hữu công nghiệp chỉ bảo vệ nội dung sáng tạo và uy tín kinh doanh, không bảo vệ hình thức sáng tạo (khác với quyền tác giả).

Thứ hai là một trong những tiêu chuẩn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là tính mới so với thế giới, khác với quyền tác giả bảo vệ tính nguyên gốc của tác phẩm. Chính vì thế mà trong khái niệm bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp có ngày ưu tiên và quyền ưu tiên (trong khi quyền tác giả không đề cập đến vấn đề này).

Thứ ba là đối với một số đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá), chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp cần phải được cấp văn bằng bảo hộ. Văn bằng bảo hộ là cơ sở pháp lý duy nhất xác định quyền sở hữu công nghiệp

của chủ sở hữu. Nó còn được gọi dưới các tên như patent, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, v.v. Trừ trường hợp của Liên minh Châu Âu, các văn bằng bảo hộ do cơ quan sở hữu công nghiệp (hay cơ quan patent) của các nước cấp. Văn bằng của cơ quan nước nào chỉ có giá trị trên lãnh thổ nước đó. Một chủ thể muốn được bảo hộ tại nhiều nước phải xin cấp nhiều văn bằng bảo hộ.

2.4.2.2 Các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp và quy chế pháp lý với các đối tượng

2.4.2.2.1. Sáng chế và giải pháp hữu ích

a. Khái niệm sáng chế, giải pháp hữu ích

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề được xác định bằng việc ứng dụng các quy luật của tự nhiên. Giải pháp kỹ thuật được hiểu là cơ cấu, phương pháp hay chất mới hay sử dụng cơ cấu, phương pháp cũ theo chức năng mới.

Ví dụ: Thomas Alva Edison sáng chế ra bóng đèn sợi tóc;

Alexander Graham Bell sáng chế ra điện thoại.

Giải pháp hữu ích: là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Giữa GPI và sáng chế chỉ khác nhau về trình độ sáng tạo.

Về bản chất, quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế là quyền của chủ sở hữu sáng chế được độc quyền khai thác sáng chế của họ và ngăn cản người khác sử dụng sáng chế có tính năng tương tự trong một thời gian nhất định và trên một lãnh thổ nhất định. Việc công nhận danh hiệu sáng chế được thực hiện thông qua cấp bằng. Bản thân việc cấp bằng bảo hộ dựa trên nguyên tắc có đi có lại: chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích phải mô tả đầy đủ sáng chế, giải pháp hữu ích của mình để thế giới có kiến thức áp dụng sau khi hết thời hạn bảo hộ. Ngược lại, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích được độc quyền khai thác các đối tượng này một thời gian để có một khoản lợi nhuận từ việc sáng tạo.

b. Điều kiện bảo hộ

Một sáng chế muốn được bảo hộ phải đáp ứng được 4 tiêu chí cơ bản sau:

- ***Phải là giải pháp kỹ thuật;***
- ***Có tính mới;***
- ***Có trình độ sáng tạo;***
- ***Có khả năng áp dụng công nghiệp.***

Một giải pháp hữu ích để được bảo hộ phải thỏa mãn 3 tiêu chí cơ bản sau:

- Phải là giải pháp kỹ thuật;
- Có tính mới;
- Có khả năng áp dụng công nghiệp.

- Phải là giải pháp kỹ thuật

Trước hết sáng chế, giải pháp hữu ích phải là những GPKT, có nghĩa là tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một vấn đề xác định. Các giải pháp này có thể thuộc các dạng như vật thể (dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện); chất thể (vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm); vật liệu sinh học (gen; thực vật, động vật biến đổi gen...); và quy trình (quy trình công nghệ; phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý). Tất cả các GPKT được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định, được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về trình tự, điều kiện, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được một mục đích nhất định. Các GPKT chỉ khác nhau bởi chức năng hoặc mục đích sử dụng cũng được coi là các GPKT khác nhau. Các thông tin chỉ là ý tưởng hoặc ý đồ, chỉ đặt vấn đề mà không phải là cách giải quyết vấn đề, không trả lời được câu hỏi “bằng cách nào” hoặc/và “bằng phương tiện gì” thì không được coi là GPKT. Ngoài ra, những cách giải quyết không phải là vấn đề kỹ thuật và không thể giải quyết được bằng cách thức kỹ thuật cũng không được coi là GPKT. Thí dụ: các loại luật lệ, trò chơi, các định luật toán học, vật lý học; phương pháp và hệ thống tổ chức, quản lý, đào tạo, huấn luyện; hệ thống ngôn ngữ; phương pháp sắp xếp thông tin; sơ đồ quy hoạch vùng lãnh thổ; hình dáng của sản phẩm chỉ mang đặc tính thẩm mỹ. Các sản phẩm của tự nhiên hoặc do tự nhiên chi phối, không phải là sản phẩm sáng tạo của con người cũng không được coi là GPKT (phát minh khoa học, thuật toán, phương pháp chẩn đoán bệnh, quản lý kinh tế, đào tạo, hệ thống ngôn ngữ, các giải pháp chỉ đề cập đến hình thức). Ngoài ra, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam không bảo hộ chương trình máy tính, mạch IC, giống thực vật, động vật. Ở một số nước như Nhật, Hàn Quốc, còn có qui định các sáng chế trái với đạo đức xã hội sẽ không được bảo hộ, thí dụ như máy in tiền giả hoặc áo dùng để dấu ma túy.

- ***Có tính mới:***

Điều kiện thứ hai của sáng chế là các GPKT này phải có tính mới. Ở đây “mới” có nghĩa là không trùng với những GPKT đã nộp đơn hoặc được bảo hộ; chưa bị bộc lộ công khai ngoài ý muốn của chủ thể, dưới hình thức sử dụng hoặc mô tả tới mức một người trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể thực hiện được giải pháp đó. Thời điểm xác định tính mới là ngày ưu tiên (đó là ngày nộp đơn hợp lệ, hoặc ngày ưu tiên theo Công ước Paris). Trình độ kỹ thuật trên thế giới (state of the arts) là tất cả những gì đã được công bố vào ngày được hưởng quyền ưu tiên (là ngày nộp đơn hoặc ngày được hưởng quyền ưu tiên theo yêu cầu của chủ thể)

Sáng chế được công nhận là có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Sáng chế nêu trong đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế không trùng với giải pháp được mô tả trong đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế đã được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền với ngày ưu tiên sớm hơn;
- Trước ngày ưu tiên của đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn chưa bị bộc lộ công khai ở trong nước và ở ngoài nước dưới hình thức sử dụng hoặc mô tả trong bất kỳ nguồn thông tin nào (báo cáo khoa học, triển lãm, bài giảng, truyền hình...) tới mức mà căn cứ vào đó người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng cũng có thể thực hiện được giải pháp đó.

Khái niệm về "ngày ưu tiên" là khái niệm đặc thù trong luật sở hữu công nghiệp. Luật sở hữu công nghiệp bảo vệ sự sáng tạo. Vì thế nó được bảo hộ theo nguyên tắc "ai sáng tạo trước được bảo hộ trước" - hay ai sáng tạo trước sẽ được quyền ưu tiên cấp bằng bảo hộ. Ngày người đó sáng tạo sẽ được gọi là ngày ưu tiên. Tuy nhiên, rất khó biết ai là người sáng tạo trước, vì pháp luật không bắt buộc hề ai sáng tạo ra được cái gì là phải nộp đơn yêu cầu bảo hộ cái đó. Thí dụ như Enrico Macconi là người đầu tiên sáng chế ra điện thoại, song ông đã không xin đăng ký ngay. Chính vì thế mà sau đó nảy sinh ra vấn đề tranh chấp giữa Macconi và Graham Bell (người sáng chế sau, song đã nộp đơn bảo hộ trước). Phần lớn các nước đã giải quyết khúc mắc trên theo phương hướng "ai đến nộp đơn yêu cầu bảo hộ trước sẽ được quyền ưu tiên". Theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, ngày ưu tiên là ngày được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận là ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục hay tại một nước thành viên khác của Công ước Paris trong vòng 12 tháng đối với sáng chế, 6 tháng đối với giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp - trước khi nộp đơn tại Cục. Trường hợp sau được gọi là ngày ưu tiên theo Công ước Paris. Ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục Sở hữu trí tuệ là ngày mà Cục công nhận là chủ thể nộp đơn đã thoả mãn các điều kiện về hình thức của đơn (đơn phải viết bằng tiếng Việt, đã đóng lệ phí, thể hiện tính thống nhất trong yêu cầu bảo hộ, khai đầy đủ các mục cần khai trong mẫu đơn và có đầy đủ các hồ sơ đi kèm). Như vậy ngày nộp đơn hợp lệ có thể là ngày chủ thể nộp đơn, hay ngày sửa chữa, bổ sung đơn lần cuối cùng (nếu trong quá trình xét đơn Cục Sở hữu trí tuệ thấy hồ sơ nộp lên chưa đầy đủ). Để xác định ngày nộp đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải tiến hành xét nghiệm về hình thức. Muốn được hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris, chủ thể nộp đơn phải cung cấp bằng chứng là mình đã nộp đơn trong thời hạn cho phép tại một nước thành viên Công ước Paris.

Pháp luật đã quy định các trường hợp nhằm loại trừ khả năng làm mất tính mới của sáng chế như:

- Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu sáng chế bị người khác do biết được thông tin đó tự ý công bố nhưng không được phép của người nộp đơn

và ngày người đó công bố nằm trong thời hạn 6 tháng trước ngày nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế;

- Sáng chế được người có quyền đăng ký theo quy định của pháp luật công bố dưới dạng báo cáo khoa học trong thời hạn 6 tháng trước ngày nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế;

- Sáng chế được người có quyền đăng ký theo quy định của pháp luật trưng bày tại cuộc triển lãm trong thời hạn 6 tháng trước ngày nộp đơn đăng ký.

- ***Có trình độ sáng tạo***

Theo Điều 61 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các GPKT đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

- ***Có khả năng áp dụng công nghiệp***

Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu: GPKT trong sáng chế đó có thể thực hiện được trong điều kiện kỹ thuật hiện tại hoặc tương lai và thu được kết quả ổn định như mô tả trong đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ

Tóm lại, bất kỳ giải pháp kỹ thuật nào đáp ứng được 4 điều kiện: là GPKT, trình độ sáng tạo, tính mới, tính hữu ích thì đều có thể cấp văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế. Tuy nhiên, sáng chế nếu không đáp ứng được tiêu chí về trình độ sáng tạo nhưng không phải là hiểu biết thông thường, có tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp thì cũng sẽ được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

c. Phạm vi bảo hộ sáng chế

Tại Việt Nam, theo quy định của pháp luật, những đối tượng sau không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế:

- Các đối tượng không đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn ứng dụng công nghiệp của sáng chế (nguyên lý khoa học, phương pháp toán học...)

- Các đối tượng được bảo hộ theo quy định của quyền tác giả (sơ đồ kế hoạch, chương trình máy tính...)

- Các đối tượng cần phải được mở rộng phạm vi áp dụng vì mục đích nhân đạo hay nhu cầu cấp bách để phát triển nền kinh tế xã hội của đất nước (phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa trị bệnh)

- Các đối tượng có thể được bảo hộ ở lĩnh vực khác (giống cây trồng, giống động vật...)

d. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế

- ***Quyền nộp đơn xin đăng ký xác lập quyền sở hữu sáng chế***

Sáng chế nằm trong nhóm đối tượng quyền sở hữu công nghiệp có tính sáng tạo là đặc trưng nổi bật. Chính vì vậy, bên cạnh chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp, pháp luật còn ghi nhận tác giả đã sáng tạo ra chúng.

Các tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế:

- Tác giả đã tạo ra đối tượng trên bằng công sức và chi phí của mình;
- Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
- Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ cơ sở vật chất, kinh phí thì quyền đăng ký sẽ thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện cho Nhà nước thực hiện quyền đăng ký này. Nếu nhà nước chỉ góp 1 phần vốn hoặc có ký kết hợp đồng hợp tác nghiên cứu – phát triển với các tổ chức, cá nhân khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tương ứng với tỉ lệ đóng góp thuộc về Nhà nước

Những chủ thể trên có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho cá nhân, tổ chức khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản để thừa kế, hay thừa kế theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

- ***Đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu sáng chế***

Theo quy định tại Điều 100 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, hồ sơ xin đăng ký quyền sở hữu công nghiệp phải bao gồm các tài liệu sau đây:

- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
- Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ.

Cụ thể đối với đơn đăng ký đối với sáng chế cần có 2 phần chính là: bản mô tả sáng chế và bản tóm tắt sáng chế.

- Phần mô tả phải làm rõ được các tiêu chuẩn bảo hộ cụ thể của sáng chế: tính mới, trình độ sáng tạo, tính ứng dụng công nghiệp; giải thích vắn tắt các hình vẽ kèm theo
- Bản tóm tắt sáng chế phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của sáng chế

- ***Thủ tục xử lý đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu sáng chế***

Cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp sau khi đã tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu sáng chế sẽ tiến hành các bước cơ bản sau đây để cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho người đăng ký:

- Thứ nhất: bước thẩm định hình thức hợp lệ của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp để công nhận tính hợp lệ của đơn. Thời hạn để thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

- Thứ hai: công bố đơn đăng ký sở hữu sáng chế trên công báo sở hữu công nghiệp trong tháng thứ 19 kể từ ngày nộp đơn hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn. Việc công khai các thông tin về đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp để cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ giải quyết bất kỳ ý kiến phản đối của người thứ 3 nào về việc cấp văn bằng bảo hộ chính thức cho các đối tượng trên.

- Thứ ba: thẩm định nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Đối với sáng chế việc thẩm định nội dung không mặc nhiên được tiến hành mà phải có đơn yêu cầu.

Ở Việt Nam, đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế sau khi có trình tự thẩm định hình thức nếu đáp ứng được về mặt hình thức sẽ được công bố công khai **19** tháng sau khi nộp đơn. Người nộp đơn có 1 thời hạn nhất định để chuẩn bị và cân nhắc trong việc tiếp tục gửi đơn yêu cầu xin thẩm định về nội dung của sáng chế.

Trong thời hạn 42 tháng kể từ ngày nộp đơn, nếu người nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc không bất kỳ người thứ ba nào khác yêu cầu thẩm định nội dung của sáng chế thì đơn đăng ký sáng chế được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

- ***Văn bằng bảo hộ và hiệu lực của văn bằng bảo hộ***

Cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp (Cục sở hữu trí tuệ) sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho những đơn đáp ứng được tất cả các điều kiện theo quy định của pháp luật và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp. Văn bằng bảo hộ sẽ có hiệu lực từ ngày cấp và được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài **20** năm kể từ ngày nộp đơn.

e. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối tượng sở hữu sáng chế

- ***Quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp***

Chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích được độc quyền sử dụng và định đoạt sản phẩm có sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ. Quyền sử dụng bao gồm các quyền sau đây:

Quyền thứ nhất là quyền sản xuất sản phẩm được bảo hộ: sản xuất có nghĩa là áp dụng GPKT theo bản mô tả để tạo ra sản phẩm. Sản phẩm bảo hộ có thể là sản phẩm được nêu trong bản mô tả hay sản phẩm có tính chất tương tự. Vấn đề sản phẩm nào là sản phẩm tương tự tùy thuộc vào việc giải thích yêu cầu bảo hộ và việc phân tích bản mô tả. Thí dụ, có thể tạo ra sản phẩm tương tự bằng nguyên liệu khác, sản phẩm có kích cỡ khác, hay sản phẩm được dùng vào mục đích khác, tuy nhiên phương pháp sản xuất đều như đã được mô tả trong đơn yêu cầu bảo hộ thì sản phẩm đó vẫn được coi là sản phẩm được bảo hộ.

Quyền thứ hai là quyền khai thác sản phẩm, áp dụng quy trình được bảo hộ. Nếu đối tượng bảo hộ là quy trình, và quy trình này không nhằm sản xuất sản phẩm, thì quyền sử dụng chỉ bao gồm quyền này thôi (thí dụ quy trình sản xuất vật liệu siêu dẫn ở -100 độ C). Tuy nhiên, phạm vi bảo hộ quy trình thường rộng hơn phạm vi bảo hộ sản phẩm, bao gồm các phương án khác nhau của cùng một quy trình. Việc áp dụng quy trình nếu trực tiếp tạo ra sản phẩm, thì sản phẩm đó cũng được bảo hộ.

Quyền thứ ba là quyền đưa vào lưu thông để bán, nhập khẩu sản phẩm được bảo hộ. Như vậy chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích có quyền không cho người khác nhập khẩu sản phẩm đã được bảo hộ tại Việt Nam vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, quyền nhập khẩu và bán này có một ngoại lệ - đó là hành vi sử dụng hạn chế sản phẩm được bảo hộ do chính chủ sở hữu đưa ra thị trường.

Quyền định đoạt của chủ sở hữu sáng chế bao gồm các quyền chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp thông qua hợp đồng bằng văn bản (đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ - gọi là hợp đồng li-xăng). Trong hợp đồng này, các bên có thể thỏa thuận về việc sử dụng độc quyền hay không độc quyền, có giới hạn về mục đích, thời gian, lãnh thổ và khối lượng sử dụng).

Đối tượng của sáng chế, giải pháp hữu ích có thể có nhiều người thừa kế, việc thừa kế phải được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Tất cả các quyền trên phải được thực hiện dựa trên nguyên tắc không trái với pháp luật, đạo đức xã hội, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác. Việc sử dụng quyền trái với các nguyên tắc trên được coi là hành vi lạm dụng quyền sở hữu công nghiệp.

• ***Nghĩa vụ của chủ sở hữu sáng chế***

Một số sáng chế, giải pháp hữu ích có vai trò quan trọng đối với nhu cầu xã hội. Nếu các sáng chế này được cấp cho những công ty chỉ quan tâm đến lợi nhuận (bán giá thuốc quá cao) mà không quan tâm đến lợi ích xã hội (số phận của các bệnh nhân), thì luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không đem lại lợi ích cho đất nước. Chính vì thế mà ở các nước thường có quy định, rằng chủ thể được cấp văn bằng sáng chế, giải pháp hữu ích có vai trò quan trọng đối với xã hội (về an ninh quốc phòng, sức khỏe, lương thực và môi trường), có nghĩa vụ phải sử dụng chúng sao cho phù hợp với nhu cầu xã hội. Trường hợp ngược lại sẽ bị cơ quan patent buộc phải giao quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích đó cho các chủ thể khác (gọi là "li-xăng bắt buộc").

Chủ văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích có nghĩa vụ phải nộp lệ phí bảo hộ theo quy định của pháp luật. Theo quy định, chủ sở hữu sáng chế hàng năm phải nộp một khoản lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Tác giả của sáng chế và giải pháp hữu ích được quyền ghi tên mình là tác

giả trên văn bằng bảo hộ (được quy định ở Điều 4ter Công ước Paris), và được trả thù lao, giải thưởng cho những ý tưởng sáng tạo của mình. Một số nước quy định (trong đó có Việt Nam) rằng nếu văn bằng bảo hộ không ghi đúng tên tác giả, thì tác giả có quyền yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ. Một số nước khác quy định cơ quan patent có nghĩa vụ phải kiểm tra kỹ trước khi cấp bằng ai là tác giả của ý tưởng sáng tạo. Một vài nước (trong đó có Hoa Kỳ) quy định chủ thể nộp đơn phải là tác giả của sáng chế.

f. Hạn chế quyền sở hữu sáng chế

Về nguyên tắc, các quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ tuyệt đối trong thời gian còn hiệu lực bảo hộ. Chủ sở hữu có độc quyền trong việc khai thác, sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, pháp luật lại quy định hạn chế các quyền nêu trên của chủ sở hữu.

Theo quy định, bất kỳ chủ thể nào khác muốn có được các quyền đối với đối tượng sở hữu công nghiệp đều phải có được sự cho phép chủ sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, ngoại lệ đối với đối tượng sở hữu công nghiệp là sáng chế là:

- Trường hợp chủ sở hữu sáng chế phải thực hiện quyền của mình theo mệnh lệnh bắt buộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: (trường hợp bắt buộc chuyển quyền sử dụng)

Trường hợp chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là trường hợp cơ quan NN có thẩm quyền buộc chủ sở hữu sáng chế phải chuyển quyền sở hữu cho 1 người khác mà chủ sở hữu đó ko muốn. Hợp đồng bắt buộc này được áp dụng trong những trường hợp như:

- + Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thực hiện nghĩa vụ sáng chế sau khi kết thúc 4 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế và kết thúc 3 năm kể từ ngày cấp bằng độc quyền sáng chế để đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh... các nhu cầu cấp thiết của xã hội

- + Từ chối ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế mặc dù người có nhu cầu sử dụng đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện hợp lý

- Người được chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc cũng phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây:

- + Là người có nhu cầu và năng lực để sử dụng sáng chế

- + Không đạt được thỏa thuận với người nắm độc quyền sáng chế mặc dù trong thời gian hợp lý đã cố gắng thương lượng với mức giá và điều kiện hợp lý;

Người được chuyển giao quyền sử dụng phải trả cho chủ sở hữu 1 khoản tiền đền bù thỏa đáng tùy thuộc vào giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó.

Việc chuyển quyền sử dụng sáng chế bắt buộc chỉ có hiệu lực khi được cơ quan NN có thẩm quyền cho phép, Bộ Khoa học và công nghệ là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc chuyển quyền sử dụng bắt buộc đối với sáng chế.

- Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và cá nhân, tổ chức được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn sáng chế không có quyền cấm người khác thực hiện các hành vi như: sử dụng sáng chế phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại, giảng dạy, nghiên cứu.

2.4.2.2. Nhãn hiệu

a. Khái niệm và phân loại nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức; cá nhân khác nhau.

Như vậy, nhãn hiệu chủ yếu dùng để gắn lên các loại hàng hóa và các loại dịch vụ để chỉ ra chúng do ai sản xuất hay cung cấp. Cũng có thể nói cách khác, nhãn hiệu gồm 2 loại cơ bản là: nhãn hiệu dùng cho hàng hóa và nhãn hiệu dùng cho dịch vụ.

- Nhãn hiệu dùng cho hàng hóa: là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa của các cá nhân, tổ chức kinh doanh khác nhau. Nó chủ yếu trả lời cho câu hỏi ai là người sản xuất ra những hàng hóa chứ không phải trả lời hàng hóa đó là cái gì? Nhãn hiệu dùng cho hàng hóa có thể gắn ngay trên chính hàng hóa hay trên bao bì của hàng hóa.

- Nhãn hiệu dùng cho dịch vụ: là những dấu hiệu để phân biệt dịch vụ của các cá nhân, tổ chức kinh doanh khác nhau. Khái niệm dịch vụ được hiểu là những dịch vụ độc lập, bao gồm một hay hành vi cụ thể để thực hiện một yêu cầu nhất định, qua đó mang lại lợi ích cho chủ thể phía bên kia. Chẳng hạn, việc sửa chữa đồ điện là một hoạt động dịch vụ nhưng việc sửa chữa các sản phẩm đồ điện tử một quan hệ mua bán đã được thiết lập thông qua khâu bảo hành thì không phải là một quan hệ dịch vụ. Nhãn hiệu dịch vụ thường được gắn trên các bảng hiệu dịch vụ để người có nhu cầu hưởng thụ dịch vụ đó có thể nhận biết.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 ta còn có thể chia ra các loại nhãn hiệu cụ thể khác như: nhãn hiệu tập thể (ví dụ như Việt Nam hiện nay đã bảo hộ cho rất nhiều các đặc sản của địa phương thành nhãn hiệu tập thể, ví dụ như Vải Thiều Thanh Hà, gôm Bát Tràng..), nhãn hiệu chứng nhận (vd: ISO 9000- cho các sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế; CE – chứng nhận cho chất lượng của các sản phẩm hàng hóa khi xuất khẩu sang thị trường EU), nhãn hiệu liên kết (vd: các nhãn hiệu như Pepsi Miranda hay Pepsi 7up được dùng cho loại đồ uống là nước cam úp hay nước chanh có ga... nhãn hiệu liên kết tạo nên sự yên tâm cho người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm hay dịch vụ mới bởi họ biết được về nguồn gốc xuất xứ hay mối liên kết với các sản phẩm hay dịch vụ mà họ đã sử dụng trước đây), nhãn hiệu nổi tiếng.

b. Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu

Nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ phải đồng thời đáp ứng được 2 tiêu chí sau:

- **Tiêu chí bảo hộ thứ nhất:** nhãn hiệu phải hội đủ 2 yếu tố: nhìn thấy được và phải được thể hiện bằng các dấu hiệu cụ thể dưới dạng các chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hay nhiều màu sắc.

Yếu tố màu sắc đóng vai trò vô cùng quan trọng, ko thể thiếu đối với nhãn hiệu hàng hóa bởi ưu điểm gây ấn tượng đối với thị giác con người, nó giúp cho nhãn hiệu thực hiện được chức năng phân biệt của mình.

Tuy nhiên, theo pháp luật một số nước trên thế giới (vd: pháp luật Sở hữu trí tuệ CHLBang Đức) thì việc bảo hộ đối với nhãn hiệu được áp dụng đối với cả các loại nhãn hiệu là những dấu hiệu âm thanh như âm nhạc, tiết nhạc mà con người có thể nhận biết được quan thính giác hoặc nhãn hiệu là các dấu hiệu mùi hương mà con người có thể nhận biết thông qua khứu giác hay nhãn hiệu hàng hóa chỉ đơn thuần được thể hiện thông qua một màu sắc nhất định.

- **Tiêu chí bảo hộ thứ hai:** các dấu hiệu trên nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Hay nói cách khác là nhãn hiệu đó phải ***có tính độc đáo*** được thể hiện ở 2 yếu tố: tính khác biệt và tính không thông dụng.

Tính khác biệt của nhãn hiệu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và nhãn hiệu đó không được trùng hay tương tự tới mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ hoặc đang được sử dụng rộng rãi hoặc nhãn hiệu của các hàng hóa, dịch vụ không trùng hoặc không tương tự nhưng có khả năng làm tổn hại đến khả năng phân biệt hay uy tín của các loại nhãn hiệu đó.

Nhãn hiệu dễ nhận biết là nhãn hiệu bao gồm các yếu tố đủ để tác động vào nhận thức, tạo nên ấn tượng có khả năng lưu giữ trong trí nhớ hay tiềm thức của con người. Bất kỳ ai khi tiếp xúc với chúng đều dễ dàng tri giác và dễ ghi nhớ nhận biết về chúng khi đặt bên cạnh các loại nhãn hiệu khác.

Việc xác định một nhãn hiệu có trùng với 1 nhãn hiệu khác không chúng ta chỉ cần xem xét là chúng có phải là bản photocopy y nguyên của nhau hay không, điều đó không khó khăn nhưng để xác định “tương tự tới mức gây nhầm lẫn giữa các loại nhãn hiệu với nhau” lại không hề dễ dàng. Tuy nhiên, ta có thể tham khảo một số tiêu chí sau đây để xác định tính tương tự gây nhầm lẫn giữa 2 hay nhiều nhãn hiệu:

- Sự tương tự về cấu trúc (như thêm các thành phần thứ yếu không có khả năng phân biệt vào một nhãn hiệu đã tồn tại từ trước hoặc ngược lại loại bỏ hay thay đổi thành phần thứ yếu của nhãn hiệu khác để làm thành nhãn hiệu của mình.

Ví dụ: Tổng công ty Thép VN (VNSTEEL) đang có tranh chấp với Công ty CP Thép Đông Nam Á (ASC) về nhãn hiệu dập nổi trên thân thanh thép của 2 công ty.



- Sự tương tự về bản chất, phương thức lưu thông (kênh thương mại) trên thị trường của các loại nhãn hiệu;

- Mức độ nổi tiếng của một trong các nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn.

Ví dụ: Một người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Nokia cho các sản phẩm đồ gia dụng sẽ không được chấp nhận mặc dù nó không trùng hay tương tự với các sản phẩm điện thoại của nhãn hiệu nổi tiếng Nokia.

Tính không thông dụng của nhãn hiệu. Một nhãn hiệu được coi là không thông dụng nếu nó không phải là:

- Các hình và hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc ngôn ngữ không thông dụng trừ trường hợp dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu. Ví dụ: hình tròn, chữ A, B, C...

Hiện nay, pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định, một dấu hiệu có khả năng đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ nếu dấu hiệu này thuộc ngôn ngữ Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung Quốc --- là những ngôn ngữ được nhiều người Việt Nam biết và sử dụng.

- Dấu hiệu, biểu tượng, quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên. *Vd:* hình cán cân công lý biểu tượng cho ngành tư pháp...

- Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, thành phần, tính chất, công dụng, giá trị hoặc đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ là nếu các dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thì cũng sẽ được chấp nhận làm nhãn hiệu.

- Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;

- Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi hoặc được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận.

- Dấu hiệu có tính chất lừa đảo. Các dấu hiệu không được phép là những dấu hiệu thuộc về quyền uy của quốc gia như quốc kỳ, quốc huy, hình ảnh lãnh tụ, tên

cơ quan nhà nước...

c.Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

• Quyền đăng ký nhãn hiệu

Với chức năng cơ bản là chỉ dẫn nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng cho nên theo quy định của pháp luật những chủ thể sau có quyền đăng ký đối với nhãn hiệu (Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009):

- Những chủ thể tiến hành sản xuất hàng hóa hay cung cấp dịch vụ trên thị trường;

- Những chủ thể tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp cũng có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất phải thỏa mãn 2 điều kiện: người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm; họ đã biết việc đăng ký đó nhưng không phản đối.

Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của Điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được đăng ký nhãn hiệu trừ trường hợp được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc đưa ra lý do chính đáng.

- Tổ chức, tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế nhãn hiệu tập thể

- Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.

• Đơn đăng ký sở hữu nhãn hiệu:

Theo quy định tại Điều 100 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, hồ sơ xin đăng ký quyền sở hữu công nghiệp phải bao gồm các tài liệu sau đây:

- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
- Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ.

Cụ thể đối với hồ sơ đăng ký quyền sở hữu nhãn hiệu (Điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009) cần có:

- Tài liệu xác định nhãn hiệu cần được bảo hộ gồm có mẫu nhãn hiệu. Yêu cầu đặt ra là phải chỉ rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể nếu có; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt hoặc có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì cũng phải được phiên âm.

- Đơn đăng ký nhãn hiệu cần nêu rõ danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn

hiệu. Danh mục hàng hóa, dịch vụ này phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thỏa ước Ni – xơ về phân loại được tế về hàng hóa và dịch vụ.

- Nếu nhãn hiệu cần đăng ký là nhãn hiệu tập thể hay nhãn hiệu chứng nhận thì cần phải có thêm quy chế sử dụng các loại nhãn hiệu đó đã được quy định cụ thể tại k4 và k5.Đ105 (như: các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể; danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu tập thể; chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải trả cho việc chứng nhận nếu có...)

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 thì cá nhân, tổ chức của Việt Nam đã đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đó tại các nước thành viên Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu mà Việt Nam đã tham gia.

- **Thủ tục xử lý đơn đăng ký sở hữu nhãn hiệu**

Cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp sau khi đã tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu nhãn hiệu sẽ tiến hành các bước cơ bản sau đây để cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho người đăng ký:

- Thứ nhất: bước thẩm định hình thức hợp lệ của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp để công nhận tính hợp lệ của đơn. Thời hạn để thẩm định hình thức là **1** tháng kể từ ngày nộp đơn.

- Thứ hai: công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trên công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng đối với nhãn hiệu kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ. Việc công khai các thông tin về đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp để cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ giải quyết bất kỳ ý kiến phản đối của người thứ 3 nào về việc cấp văn bằng bảo hộ chính thức cho các đối tượng trên.

- Thứ ba: thẩm định nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp khi đã có quyết định công nhận là hợp lệ để đánh giá các tiêu chí bảo hộ và phạm vi bảo hộ của các đối tượng đó. Thời hạn thẩm định về nội dung đối với nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

- **Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và hiệu lực của giấy chứng nhận**

Cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp (Cục sở hữu trí tuệ) sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho những đơn đáp ứng được tất cả các điều kiện theo quy định của pháp luật và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp. Văn bằng bảo hộ sẽ có hiệu lực từ ngày cấp và được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực **10** năm và có thể gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần **10** năm.

d. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu

- **Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu**

Theo quy định của pháp luật, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có các quyền cơ bản như:

- **Độc quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.**

Đối với việc sử dụng nhãn hiệu có thể kể tới như: gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ, nhập khẩu hàng hóa có mang nhãn hiệu được bảo hộ.

- **Quyền tạm thời đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp:** là quyền của người đăng ký bảo hộ các đối tượng đó được phát sinh từ ngày đơn đăng ký bảo hộ được nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được công bố công khai đến ngày được cấp bằng độc quyền đối với các đối tượng đó. *Tuy nhiên pháp luật sở hữu trí tuệ chỉ ghi nhận quyền tạm thời này cho các đối tượng như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí. Còn đối với chủ sở hữu nhãn hiệu thì không có quyền này.*

- **Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.**

Trong thời gian bảo hộ, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có quyền chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho người khác. Quyền cho phép người khác sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức kí kết hợp đồng bằng văn bản phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự, thương mại

- **Định đoạt quyền sở hữu công nghiệp và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến các đối tượng sở hữu công nghiệp**

Chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ được pháp luật bảo hộ quyền lợi của mình nếu họ chứng minh được có hành vi cạnh tranh không lành mạnh xảy ra trên thực tế.

- **Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu**

Bên cạnh việc ghi nhận và bảo hộ các quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu như đã nêu trên, pháp luật cũng quy định các nghĩa vụ mà chủ sở hữu phải thực hiện như sau:

- Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu đó. Nếu chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng mà không sử dụng nhãn hiệu trong thời hạn **5** năm liên tục mà không có lý do chính đáng kể từ ngày được cấp văn bằng bảo hộ thì sẽ bị chấm dứt hiệu lực đối với văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất 3 tháng tính từ ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực.

- Đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận nếu chủ sở hữu vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả đối với việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận

thì cũng bị chấm dứt văn bằng bảo hộ.

e. Hạn chế quyền sở hữu nhãn hiệu

Về nguyên tắc, các quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ tuyệt đối trong thời gian còn hiệu lực bảo hộ. Chủ sở hữu có độc quyền trong việc khai thác, sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, pháp luật lại quy định hạn chế các quyền nêu trên của chủ sở hữu. Đối với nhãn hiệu, hạn chế này được thể hiện qua những quy định sau:

- Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
- Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

2.4.2.2.3. Chỉ dẫn địa lý

a. Khái niệm chỉ dẫn địa lý

Tại khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 đã quy định: *Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.*

Như vậy, chỉ dẫn địa lý giúp cho người tiêu dùng biết được hàng hóa đó đến từ khu vực nào với những nét đặc thù riêng của khu vực đó như thế trong quá trình lựa chọn sản phẩm.

Bên cạnh khái niệm “chỉ dẫn địa lý” còn tồn tại một khái niệm gần giống là khái niệm “**chỉ dẫn nguồn gốc**” – được đề cập tới trong Công ước Paris. Theo đó, “chỉ dẫn nguồn gốc” là dấu hiệu chỉ ra tên địa lý của một quốc gia, một khu vực hay một vùng cụ thể nơi sản phẩm được tạo ra mà không cần dựa trên chất lượng hay đặc thù của sản phẩm. Chỉ dẫn nguồn gốc khác với chỉ dẫn địa lý ở chỗ chỉ dẫn nguồn gốc không có một sự bảo đảm nào về chất lượng đặc biệt của sản phẩm. Nó chỉ đơn giản là giúp người tiêu dùng nhận biết được sản phẩm đó sản xuất từ đâu. Ví dụ: Made in VN hay Made in China.

b. Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý:

Một chỉ dẫn địa lý được bảo hộ là một đối tượng sở hữu công nghiệp nếu đáp ứng được cả điều kiện theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Cụ thể:

Thứ nhất: Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

- Có nghĩa là chỉ dẫn địa lý đó phải gắn với 1 khu vực, địa phương cụ thể hay nói cách khác tên gọi, biểu tượng hình ảnh đó phải có thực và chỉ thuộc về khu vực địa phương đó mà thôi.

Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý có ranh giới được xác định chính xác bằng từ ngữ và bản đồ. Khu vực địa lý có thể là một đơn vị hành chính quốc gia (vd: tỉnh Hải Dương – Bánh đậu xanh Hải Dương, nước mắm Phú Quốc thì Phú Quốc là 1 huyện đảo nằm trong tỉnh Kiên Giang...), khu vực địa lý thuộc một hay nhiều đơn vị hành chính hoặc toàn bộ lãnh thổ quốc gia (.....)

- Chỉ dẫn địa lý phải được dùng với mục đích duy nhất là: để chỉ rõ nguồn gốc của sản phẩm được sản xuất từ khu vực địa phương đó chứ không phải được gắn trên hàng hóa hay bao bì của hàng hóa nhằm mục đích trang trí cho đẹp hay vì bất cứ mục đích nào khác.

Thứ hai: Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Hay nói một cách khác là: sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải thể hiện được mối quan hệ giữa danh tiếng, chất lượng của sản phẩm với điều kiện địa lý của địa phương đó.

Như vậy, một chỉ dẫn địa lý được bảo hộ thì yêu cầu tối thiểu là phải chỉ ra được bằng chứng về đặc tính của hàng hóa có sự liên quan phụ thuộc với điều kiện địa lý tự nhiên, con người hoặc kết hợp cả 2 yếu tố đó của khu vực, địa phương cụ thể.

Danh tiếng, uy tín của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được thể hiện thông qua sự biết đến sản phẩm đó một cách rộng rãi trong giới tiêu dùng sản phẩm liên quan trong quá trình tồn tại và phát triển của sản phẩm đó.

Ví dụ: các sản phẩm nước hoa, hương phẩm của Pháp có gắn hình tượng tháp Eiffel đã được giới tiêu dùng trên cả thế giới ưa chuộng bởi uy tín và danh tiếng của các sản phẩm nước hoa có nguồn gốc xuất xứ từ Pháp

Các điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý bao gồm 2 yếu tố cơ bản là : **yếu tố tự nhiên và yếu tố con người.**

- **Yếu tố tự nhiên:** bao gồm khí hậu, thủy văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác. Vd: nước mắm ở Phú Quốc có nguồn gốc từ đảo Phú Quốc là loại hàng hóa có chất lượng bất biến từ các điều kiện tự nhiên vốn dĩ ở đảo này như các điều kiện về khí hậu và thổ nhưỡng (loại cá cơm đặc biệt dùng làm nguyên liệu sống ở biển khu vực đảo này, kết hợp với các điều kiện về nguồn nước, cường độ ánh sáng mặt trời... của khu vực đó).

- **Yếu tố về con người:** được thể hiện thông qua các yếu tố độc đáo về kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, bao gồm cả quy trình sản xuất truyền thống của người dân địa phương nếu quy trình đó là nhân tố tạo ra và giữ gìn chất lượng, uy tín của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Vd: nước mắm Phú Quốc có được sự khác biệt chính yếu so với các loại nước mắm khác ngoài nhờ những yếu tố tự nhiên

có sẵn thì còn phải kể đến quy trình sản xuất đã được hình thành và phát triển từ hơn 200 năm nay giúp cho nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián đặc trưng – màu cánh gián này có được nhờ cách ướp tươi còn máu trong thân cá và thời gian ủ trong thùng gỗ tới 12 tháng.

Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng một hoặc một số yếu tố như: chỉ tiêu định tính, định lượng hoặc cảm quan về vật lý, hóa học, vi sinh.. và các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương pháp kiểm tra thông thường.

c. Phạm vi bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

Về phạm vi bảo hộ của chỉ dẫn địa lý, pháp luật quy định các đối tượng sau không được bảo hộ chỉ dẫn địa lý (Điều 80 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009):

- Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa ở Việt Nam tại thời điểm yêu cầu đăng ký; *Ví dụ:* Hàng Việt Nam
- Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;
- Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;
- Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó

d. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý.

• Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước. Các cá nhân, tổ chức sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các cá nhân, tổ chức đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý nếu được Nhà nước cho phép và không trở thành chủ sở hữu của chỉ dẫn địa lý đó. **Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó**

Cá nhân, tổ chức nước ngoài là chủ thể có quyền đối với chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật nước xuất xứ có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý đó ở Việt Nam.

• Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý:

Theo quy định tại Điều 100 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, hồ sơ xin đăng ký quyền sở hữu công nghiệp phải bao gồm các tài liệu sau đây:

- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

- Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ.

Cụ thể đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý cần có:

- Tên gọi, dấu hiệu được dùng làm chỉ dẫn địa lý
- Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý
- Bản mô tả tính chất đặc thù phải chỉ rõ cả nguyên liệu thô và các đặc tính lý học, hóa học, vi sinh và cảm quan của sản phẩm cũng như chỉ ra mối quan hệ giữa tính chất, chất lượng đặc thù hoặc danh tiếng của sản phẩm với điều kiện địa lý nơi xuất xứ của sản phẩm
- Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý; (nếu là chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc nước ngoài thì cần phải có tài liệu chứng minh chỉ dẫn đó đang được bảo hộ ở một nước cụ thể).
- Nếu đơn đăng ký được nộp thông qua một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp thì phải có thêm giấy ủy quyền;
- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu được thụ hưởng quyền đó từ người khác;
- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

• Thủ tục xử lý đơn đăng ký sở hữu chỉ dẫn địa lý

Cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp sau khi đã tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu chỉ dẫn địa lý sẽ tiến hành các bước cơ bản sau đây để cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý:

- Thứ nhất: bước thẩm định hình thức hợp lệ của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp để công nhận tính hợp lệ của đơn. Thời hạn để thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.
- Thứ hai: công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trên công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng đối với chỉ dẫn địa lý kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ. Việc công khai các thông tin về đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp để cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ giải quyết bất kỳ ý kiến phản đối của người thứ 3 nào về việc cấp văn bằng bảo hộ chính thức cho các đối tượng trên.
- Thứ ba: thẩm định nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp khi đã có quyết định công nhận là hợp lệ để đánh giá các tiêu chí bảo hộ và phạm vi bảo hộ của các đối tượng đó. Thời hạn thẩm định về nội dung đối với chỉ dẫn địa lý tối đa là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn

• Văn bằng bảo hộ và hiệu lực của văn bằng bảo hộ

Cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp (Cục sở hữu trí tuệ) sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho những đơn đáp ứng được tất cả các điều kiện theo quy định của pháp luật và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Văn bằng bảo hộ sẽ có hiệu lực từ ngày cấp và được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý là văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp duy nhất được bảo hộ vô thời hạn kể từ ngày cấp.

e. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp

Theo quy định của pháp luật, chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý (thực ra là người đã thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý) có các quyền cơ bản như: gắn chỉ dẫn địa lý được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ, nhập khẩu hàng hóa có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.

Về bản chất, chỉ dẫn địa lý được xem như là thuộc tài sản quốc gia nên về nguyên tắc nó không thể chuyển giao cho bất cứ chủ thể nào khác và người được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cũng không có quyền định đoạt đối với chỉ dẫn địa lý đó nhưng chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý vẫn có quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến các đối tượng sở hữu công nghiệp.

2.4.2.2.5. Kiểu dáng công nghiệp

a. Khái niệm kiểu dáng công nghiệp

Khoản 13 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 đã quy định; “*Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố này*”. Sản phẩm ở đây được hiểu là đồ vật, dụng cụ, phương tiện...được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hay thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông.

Việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam đang dần được các doanh nghiệp quan tâm, nhưng không phải kiểu dáng công nghiệp nào cũng được bảo hộ mà nó phải đáp ứng được các tiêu chí theo quy định của pháp luật.

b. Điều kiện bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ khi nó đáp ứng được 3 tiêu chí cơ bản sau đây:

- **Có tính mới so với thế giới ;**
- **Có tính sáng tạo;**
- **Có khả năng áp dụng công nghiệp.**
- ***Có tính mới***

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp phải đạt được 3 tiêu chí:

- Thứ nhất: kiểu dáng công nghiệp được công nhận là có tính mới nếu đến ngày nộp đơn, kiểu dáng đó có sự khác biệt cơ bản rõ rệt với những kiểu dáng đã bị bộc lộ công khai. Hay nói cách khác là kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ

không được đồng nhất hoặc tương tự tới gần giống đến mức gây nhầm lẫn với những kiểu dáng đã tồn tại trước đó.

- Thứ hai: kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt cơ bản với nhau nếu chỉ khác biệt bởi các đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết và ghi nhớ được, các đặc điểm đó không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp với nhau.

- Thứ ba: kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ chưa bị bộc lộ công khai ở bất kỳ đâu, dưới bất kỳ hình thức nào tính đến ngày nộp đơn.

Pháp luật đã có quy định các trường hợp nhằm loại trừ việc làm mất tính mới của kiểu dáng công nghiệp. Đó là khi kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố bị rơi vào các trường hợp sau:

- Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được pháp của người có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp (về quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp – chúng ta sẽ nói tới ở mục sau)

- Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học hay trưng bày tại các cuộc triển lãm quốc gia vừa Việt Nam hoặc tại triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

- ***Tính sáng tạo***

Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp được thể hiện qua 2 yếu tố cơ bản là: kiểu dáng công nghiệp phải là thành quả sáng tạo của tác giả, nó không được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng; kiểu dáng công nghiệp trong đơn yêu cầu phải tạo ra bước tiến rõ rệt về mặt kỹ thuật so với kiểu dáng của các sản phẩm cùng loại trước đó.

- ***Có khả năng áp dụng công nghiệp***

Kiểu dáng công nghiệp là đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu công nghiệp nên tiêu chí có khả năng áp dụng công nghiệp là không thể thiếu đối với đối tượng này.

Kiểu dáng công nghiệp được công nhận là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo ra hàng loạt bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó.

c. Phạm vi bảo hộ

Những đối tượng sau đây không có khả năng bảo hộ dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:

- Hình dáng bên ngoài của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng. Đối với các loại sản phẩm mà khi đưa vào sử dụng thì không còn giữ được hay bị mất đi hình dáng bên ngoài như lúc ban đầu thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu bảo hộ. *Ví dụ:* cục xà phòng.

- Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 thì chỉ những bản vẽ, thiết kế sơ đồ các công trình xây dựng mới được bảo hộ dưới góc độ của quyền tác giả;

- Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có hoặc chỉ mang đặc tính kỹ thuật (ví dụ: hình dáng đĩa CD, VCD); hình dáng bên ngoài của sản phẩm chỉ thuần túy có giá trị thẩm mỹ (hình dáng các bức tượng, điêu khắc)

- Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với chuyên gia có trình độ trung bình thuộc lĩnh vực tương ứng;

- Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật bắt buộc phải có;

- Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng;

- Hình dáng các sản phẩm chỉ có giá trị thẩm mỹ.

d. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp

- **Quyền nộp đơn xin đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp**

Kiểu dáng công nghiệp nằm trong nhóm đối tượng quyền sở hữu công nghiệp có tính sáng tạo là đặc trưng nổi bật. Chính vì vậy, bên cạnh chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp, pháp luật còn ghi nhận tác giả đã sáng tạo ra chúng.

Các tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

- Tác giả đã tạo ra đối tượng trên bằng công sức và chi phí của mình;

- Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

- Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ cơ sở vật chất, kinh phí thì quyền đăng ký sẽ thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện cho Nhà nước thực hiện quyền đăng ký này. Nếu nhà nước chỉ góp 1 phần vốn hoặc có ký kết hợp đồng hợp tác nghiên cứu – phát triển với các tổ chức, cá nhân khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tương ứng với tỉ lệ đóng góp thuộc về Nhà nước

Những chủ thể trên có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho cá nhân, tổ chức khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản để thừa kế, hay thừa kế theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

- **Đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp**

Theo quy định tại Điều 100 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, hồ sơ xin đăng ký quyền sở hữu công nghiệp phải bao gồm các tài liệu sau đây:

- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

- Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ.

Cụ thể đối với đơn đăng ký đối với kiểu dáng công nghiệp cần có:

- Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp và bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. Trong đó bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm phần mô tả kiểu dáng công nghiệp và phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Yêu cầu đặt ra: tài liệu xác định kiểu dáng công nghiệp cần được bảo hộ cần phải bộc lộ đầy đủ các đặc điểm tạo dáng, chỉ rõ điểm mới khác biệt so với các kiểu dáng công nghiệp trước đó và phải phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ.

- Nếu người đăng ký muốn được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo nhiều phương án khác nhau thì phải chỉ rõ đâu là phương án cơ bản và sự khác biệt giữa nó với các phương án còn lại.

- Trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng ký là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ sản phẩm đó.

- Nếu kiểu dáng có chứa nhãn hiệu thì phải có tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu.

- **Thủ tục xử lý đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp**

Cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp sau khi đã tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu kiểu dáng công nghiệp sẽ tiến hành các bước cơ bản sau đây để cấp giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho người đăng ký:

- Thứ nhất: bước thẩm định hình thức hợp lệ của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp để công nhận tính hợp lệ của đơn. Thời hạn để thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

- Thứ hai: công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trên công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng đối với kiểu dáng công nghiệp kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ. Việc công khai các thông tin về đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp để cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ giải quyết bất kỳ ý kiến phản đối của người thứ 3 nào về việc cấp văn bằng bảo hộ chính thức cho các đối tượng trên.

- Thứ ba: thẩm định nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp khi đã có quyết định công nhận là hợp lệ để đánh giá các tiêu chí bảo hộ và phạm vi bảo hộ của các đối tượng đó. Thời hạn thẩm định về nội dung đối với kiểu dáng công nghiệp tối đa là 7 tháng kể từ ngày công bố đơn.

- **Văn bằng bảo hộ và hiệu lực của văn bằng bảo hộ**

Cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp (Cục sở hữu trí tuệ) sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho những đơn đáp ứng được tất cả các điều kiện theo quy

định của pháp luật và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp. Văn bằng bảo hộ sẽ có hiệu lực từ ngày cấp và được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực **5** năm, có thể gia hạn liên tiếp 2 lần, mỗi lần 5 năm.

e. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp

• Quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp

Theo quy định của pháp luật, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có các quyền cơ bản như:

- Độc quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp
- Quyền tạm thời đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp
- Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, định đoạt quyền sở hữu công nghiệp
- Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến các đối tượng sở hữu công nghiệp

Quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp – quyền năng quan trọng nhất của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp. Đối với kiểu dáng công nghiệp: đó là sản xuất sản phẩm có hình dáng bên ngoài được bảo hộ dưới danh nghĩa là kiểu dáng công nghiệp; lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm và nhập khẩu các sản phẩm được bảo hộ theo kiểu dáng công nghiệp đó.

Pháp luật Sở hữu trí tuệ chỉ ghi nhận quyền tạm thời này đối với các đối tượng như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí vì chúng có đặc điểm về tính sáng tạo. Quyền tạm thời này chỉ phát sinh trên các điều kiện như:

+ Có việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng ký đã nộp. Việc sử dụng các đối tượng này được tiến hành sau thời điểm đơn đăng ký bảo hộ được công khai trên Công báo đối tượng sở hữu công nghiệp. Nếu việc sử dụng được tiến hành trước thời điểm này thì *người sử dụng trước* sẽ được hưởng các quyền của người sử dụng trước.

• Nghĩa vụ của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp

Chủ sở hữu phải có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả kiểu dáng công nghiệp theo thỏa thuận

f. Hạn chế quyền sở hữu công nghiệp

Theo quy định, bất kỳ chủ thể nào khác muốn có được các quyền đối với đối tượng sở hữu công nghiệp đều phải có được sự cho phép chủ sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, ngoại lệ đối với đối tượng sở hữu công nghiệp là kiểu dáng công nghiệp là:

Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp không có quyền cấm người khác thực

hiện các hành vi sau:

- Sử dụng kiểu dáng công nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất.
- Các hành hóa mang kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ đã được chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp đó đưa ra thị trường tại bất cứ đâu trong hay ngoài nước thì chủ sở hữu ko có quyền ngăn cấm các hành vi nhập khẩu, lưu thông hàng hóa đó
- Không được ngăn cản quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp của người có quyền sử dụng trước đưa ra thị trường
- Người có quyền sử dụng trước không được mở rộng phạm vi, khối lượng sử dụng nếu ko đc sự cho phép của chủ sở hữu cũng như ko đc chuyển giao quyền đó cho người khác trừ trường hợp chuyển giao quyền đó kèm theo chuyển giao cơ sở sản xuất, kinh doanh nơi sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó.

2.4.2.2.6. Các đối tượng khác

a. Tên thương mại

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong một hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với các chủ thể kinh doanh khác trong cùng một lĩnh vực kinh doanh và khu vực kinh doanh.

Khu vực kinh doanh là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bán hàng, khách hàng hoặc danh tiếng, nó có thể nằm trong phạm vi hay vượt ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia.

Tên thương mại không có tính phân biệt cao nên các doanh nghiệp thường lấy thành phần phân biệt của tên thương mại để làm Nhân hiệu hàng hóa. Ví dụ: Công ty liên doanh TNHH ngọc trai Minh Ngọc đăng ký NHHH: “Minh Ngọc PEARLS »

b. Bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh là các thông tin tạo thành bí quyết mà chủ thể dùng nó để kinh doanh tạo ra những ưu thế về chất lượng của sản phẩm, dịch vụ...Bí mật này được chủ kinh doanh giữ bí mật không cho người khác biết.

Bí mật kinh doanh gồm hai yếu tố: bí mật và quyết định. Thông thường, bí mật kinh doanh không được bảo vệ hoặc cấp bằng sáng chế, hoặc vì chưa hội đủ các yêu cầu để cấp bằng, hoặc vì quá quý báu không thể bị tiết lộ. Ví dụ: tất cả các nhà máy của công ty Coca Cola đều dùng một loại hương liệu được sản xuất tại phòng thí nghiệm ở Atlanta, bang Georgia, Mỹ. Công thức chế tạo hương liệu này được dấu kín hơn 100 năm nay. Trong khi nếu chúng được bảo vệ bằng việc

cấp văn bằng độc quyền sáng chế, thì công thức đó phải được công bố và chỉ có giá trị 20 năm - không được gia hạn. [SEP] Đặc tính thứ nhất của thông tin trong bí mật kinh doanh là tính bí mật, có nghĩa là thông tin hoặc phần quan trọng của chúng phải không được dễ biết hoặc dễ suy đoán. Tất nhiên điều đó cũng không có nghĩa là mỗi phần của thông tin phải là bí mật. Sự bí mật có thể đơn thuần chỉ là sự kết hợp của tất cả những điều đã biết. [SEP] Chính vì tính bí mật mà việc soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng bí mật kinh doanh rất phức tạp. Bên chuyển giao muốn chuyển giao một bí mật, nhưng không thể biết bên nhận đã biết về bí mật đó chưa (mà cũng không thể mô tả bí mật đó rồi hỏi phía bên kia: “anh đã biết bí mật đó chưa”, vì câu trả lời chắc chắn là “rồi” và giá trị của bí quyết cũng không còn nữa); ngược lại bên nhận chuyển giao cũng không muốn “chưa nhìn mặt đã đặt tên”, nghĩa là chưa biết bí quyết ra sao đã phải quyết định giá mua và thậm chí đã phải trả tiền mua. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng chuyển giao bí quyết sẽ được đi sâu hơn trong phần sau. [SEP] Đặc tính thứ hai của thông tin trong bí quyết là tính quyết định, có nghĩa là thông tin đó phải đóng vai trò quan trọng trong quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Như vậy bí quyết cần phải có ích ở chỗ nó nâng cao vị trí hoặc tạo ưu thế cạnh tranh của người nắm bí quyết, ví dụ như đánh vào thị hiếu mới của người tiêu dùng. Đặc tính thứ ba của bí quyết là tính xác định. Đây chỉ là đặc tính bổ trợ và định hình cho hai đặc tính đầu. [SEP] Chúng ta cần phải biết ba đặc tính này vì khác với các sở hữu công nghiệp, bí quyết không được bảo hộ độc quyền. Chỉ trong vài trường hợp bí quyết được coi như bí mật quân sự và kinh tế, có thể được luật hình sự, thương mại hoặc lao động bảo vệ (nguyên tắc bảo mật). Cũng không có một công ước quốc tế nào về bảo hộ bí quyết, vì vậy mà khi soạn thảo hợp đồng, ta cần nắm rõ các quy định về nghĩa vụ dân sự và quy định nghĩa vụ bảo mật của đôi bên cho chắc chắn. Tương tự, chúng ta nên cẩn thận hơn khi định giá một “bí quyết” mà trên thực tế không hội đủ điều kiện (thí dụ chúng chẳng có gì là bí mật hay cũng không có giá trị quyết định nào). Đối với nhà nước, việc xác định bí quyết có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý và phê duyệt hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Chủ sở hữu bí mật kinh doanh được quyền chuyển giao bí mật theo hợp đồng gọi là li-xăng bí mật kinh doanh. Việc chuyển giao quyền sử dụng bí mật kinh doanh phải lập thành văn bản, nhưng không phải đăng ký hay phê duyệt. Trong khi đó một hợp đồng chuyển giao công nghệ cần phải được phê duyệt đăng ký. Có một đối tượng chuyển giao công nghệ, đó là bí quyết, là một dạng đặc biệt của bí mật kinh doanh. Khi việc chuyển giao bao gồm bí quyết, các chủ thể của hợp đồng chuyển giao nên xem xét xem bản chất của việc chuyển giao đó có phải là chuyển giao công nghệ và cần phải phê duyệt hay đăng ký hay không.

2.4.2.3. Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp.

2.4.2.3.1. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

- **Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với sáng chế, giải pháp hữu ích**

Người có hành vi sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trong thời hạn bảo hộ mà không xin phép chủ sở hữu thì bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Những hành vi đó là :

- Sản xuất sản phẩm theo sáng chế, giải pháp hữu ích, theo thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đã được bảo hộ tại Việt Nam ;
- Sử dụng, nhập khẩu, quảng cáo, lưu thông sản phẩm mà sản phẩm đó được sản xuất theo sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đã được bảo hộ tại Việt Nam ;
- Áp dụng các phương pháp mà phương pháp đó được bảo hộ tại Việt Nam là sáng chế, giải pháp hữu ích.

- **Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp**

Người sử dụng kiểu dáng công nghiệp trong thời hạn văn bằng bảo hộ vẫn có hiệu lực mà không được chủ sở hữu cho phép thì bị coi là xâm phạm quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Những hành vi xâm phạm được thể hiện ở các dạng sau :

- Sản xuất sản phẩm theo kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ tại Việt Nam ;
- Nhập khẩu, bán, quảng cáo hoặc sử dụng các sản phẩm chế tạo theo kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ tại Việt Nam nhằm mục đích kinh doanh.

- **Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý**

Là hành vi gắn nhãn hiệu trên sản phẩm của mình mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu như :

- Gắn nhãn hiệu của người khác, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam hoặc nhãn hiệu tương tự lên bao bì, sản phẩm của mình ;
- Nhập khẩu, bán hoặc chào hàng các sản phẩm có gắn nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam trên thị trường Việt Nam.

2.4.2.3.2. Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp

Khi quyền của chủ sở hữu công nghiệp bị xâm phạm, chủ sở hữu có quyền :

- Yêu cầu người đang có hành vi xâm phạm phải chấm dứt ngay hành vi xâm phạm hay cạnh tranh không lành mạnh đó đồng thời người có hành vi xâm phạm phải hủy bỏ những sản phẩm đã sản xuất do sao chép, ăn cắp nhãn hiệu hàng hóa gây thiệt hại cho người tiêu dùng và làm giảm sự tín nhiệm của người tiêu dùng đối với chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp ;

- Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại;
- Chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp khởi kiện lên Tòa án, yêu cầu bảo vệ khi xác định được người có hành vi xâm phạm tới quyền sở hữu công nghiệp.

Chương 3: LUẬT LAO ĐỘNG

3.1. Hợp đồng lao động

3.1.1. Khái niệm, đặc điểm của Hợp đồng lao động

Trong quá trình lao động, việc hình thành quan hệ lao động thông qua các hình thức tuyển dụng lao động là một nhu cầu tất yếu. Hiện nay, pháp luật quy định ba hình thức tuyển dụng lao động, đó là: Hợp đồng lao động, tuyển dụng vào biên chế nhà nước và bầu cử. Mỗi hình thức tuyển dụng được sử dụng ở một phạm vi nhất định phù hợp với tính chất của quá trình sử dụng lao động, trong đó hợp đồng lao động là hình thức tuyển dụng chủ yếu và phổ biến nhất để thiết lập quan hệ lao động trong cơ chế thị trường.

Theo quy định của Bộ luật lao động thì, “Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.” (Điều 13 – BLLĐ năm 2019). Như vậy, có ba nhân tố cơ bản cấu thành hợp đồng lao động, đó là: Sự cung ứng một việc làm, sự trả công và sự lệ thuộc về mặt pháp lý giữa người lao động và người sử dụng lao động.

So với các quan hệ hợp đồng khác, hợp đồng lao động có ba đặc trưng khác biệt:

Một là, hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện với tư cách cá nhân của các bên chủ thể, nói cách khác, việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động luôn có tính đích danh, các chủ thể tự mình giao kết và thực hiện hợp đồng lao động bằng hành vi của chính mình. Người lao động phải tự mình thực hiện công việc theo hợp đồng và phải tự mình chịu trách nhiệm khi có vi phạm, nếu không có sự đồng ý của người sử dụng lao động thì người lao động không được tự ý chuyển công việc của mình cho người khác thực hiện ngay cả khi người đó có khả năng cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp.

Hai là, đối tượng của hợp đồng lao động là việc làm. Sức lao động của người lao động chính là hàng hoá trong quan hệ mua bán và người sử dụng lao động mua được sức lao động của người lao động bằng cách cung ứng cho người lao động một việc làm.

Ba là, hợp đồng lao động bao giờ cũng được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục. Hai bên trong quan hệ hợp đồng không được tự do dừng lại việc thực hiện hợp đồng theo ý chí của riêng mình, chỉ được tạm hoãn trong những trường hợp pháp luật cho phép. Có nghĩa là việc thực hiện hợp đồng phải tuân thủ theo thời gian xác định (giờ làm việc, ngày làm việc, tuần làm việc...) mà người lao động không có quyền lựa chọn hay làm việc theo ý mình.

3.1.2. Đối tượng và phạm vi áp dụng của hợp đồng lao động

- **Về đối tượng**, hợp đồng lao động áp dụng cho mọi đối tượng người lao động làm công ăn lương thuộc mọi khu vực kinh tế, mọi thành phần kinh tế, không phân biệt trình độ. Trừ một số trường hợp không áp dụng hợp đồng lao động là:

- + Cán bộ, công chức;
- + Đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp chuyên trách, người giữ các chức vụ trong cơ quan của quốc hội, chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp, toà án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân được quốc hội hoặc hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc cử ra theo nhiệm kỳ;
- + Người được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng trong doanh nghiệp nhà nước;
- + Thành viên của hội đồng quản trị doanh nghiệp;
- + Những người thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội;
- + Cán bộ chuyên trách công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp;
- + Xã viên hợp tác xã;
- + Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp và viên chức trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân.

- **Về phạm vi áp dụng**, hợp đồng lao động áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động làm công ăn lương trên lãnh thổ Việt nam.

3.1.3. Phân loại hợp đồng lao động

3.1.3.1. Theo hình thức hợp đồng:

Căn cứ vào hình thức hợp đồng, có hai loại HĐLĐ:

- **Hợp đồng lao động bằng văn bản**: Ghi bằng văn bản, theo mẫu, áp dụng cho: HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên; HĐLĐ về coi giữ tài sản gia đình; HĐLĐ làm việc trong các cơ sở dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, vũ trường...; HĐLĐ với người dưới 15 tuổi (phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp); HĐLĐ ký thông qua người đại diện của một nhóm người lao động.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

- **Hợp đồng lao động bằng lời nói**: Các bên thoả thuận hợp đồng chỉ thông qua đàm phán bằng lời nói mà không lập thành văn bản, có thể có hoặc không có

người làm chứng. Loại hợp đồng này được áp dụng cho những công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới 01 tháng. Khi giao kết và thực hiện các bên đương nhiên phải tuân thủ pháp luật. Nếu có tranh chấp phát sinh, cơ quan có thẩm quyền sẽ dựa vào quy định của pháp luật để giải quyết.

3.1.3.2. Theo thời hạn của hợp đồng:

Căn cứ vào thời hạn của hợp đồng, có 02 loại HĐLĐ (Điều 20 – BLLĐ năm 2019)

- **HĐLĐ không xác định thời hạn:** Là loại hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng được thực hiện từ khi bắt đầu đến khi có một sự kiện làm chấm dứt quan hệ giữa hai bên. Hợp đồng này được áp dụng cho những công việc có tính chất thường xuyên, ổn định mà các bên không xác định trước được thời điểm kết thúc.

- **HĐLĐ xác định thời hạn:** Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Chú ý: (Khoản 2 – Điều 20 – BLLĐ năm 2019) Khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động xác định thời hạn trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật lao động 2019.

3.1.3.3. Theo tính kế tiếp của trình tự giao kết hợp đồng:

Căn cứ vào tính kế tiếp của trình tự giao kết hợp đồng, có 02 loại HĐLĐ:

- **Hợp đồng thử việc:** Trong hợp đồng này chỉ tồn tại các điều khoản cơ bản nhất như công việc, thời hạn thử việc, tiền lương... và chỉ có ý nghĩa như một loại điều kiện cho việc tuyển dụng lao động. Do vậy, mức độ ràng buộc chưa cao, các bên có quyền chấm dứt bất kỳ khi nào mà không bị coi là bất hợp pháp.

Thời gian thử việc: Căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

- + Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

- + Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

- + Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

- + Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Tiền lương trong thời gian thử việc: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Kết thúc thời gian thử việc:

- + Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

- + Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

- HĐLĐ chính thức: Là hợp đồng tạo nên quan hệ lao động. Đây là cơ sở pháp lý cho việc xác lập, duy trì quan hệ lao động. Hợp đồng này chặt chẽ hơn so với HĐ thử việc, mức độ ràng buộc giữa các bên cũng cao hơn, khi muốn chấm dứt hợp đồng các bên phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

3.1.4. Nội dung của HĐLĐ

Nội dung hợp đồng lao động là toàn bộ những vấn đề được phản ánh trong hợp đồng lao động dựa trên sự thoả thuận hợp pháp của các chủ thể. Cụ thể hơn đó chính là các điều khoản ghi nhận các cam kết tạo ra quyền và nghĩa vụ của các chủ thể hợp đồng.

Tuỳ theo tính chất và mức độ cần thiết của các điều khoản trong hợp đồng lao động, có thể chia các điều khoản của hợp đồng ra làm hai loại là:

- Điều khoản bắt buộc:** Là những điều khoản được pháp luật quy định cần được phản ánh trong hợp đồng lao động hoặc những điều khoản không được có những thoả thuận tự do. Đó là các điều khoản: Thông tin của các bên trong hợp đồng (Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp; họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân

hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động); Công việc và địa điểm làm việc; Thời hạn của HĐLĐ; Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Nếu thiếu những điều khoản này thì hợp đồng coi như chưa được xác lập.

- **Điều khoản thoả thuận:** Là những điều khoản do các bên tự do xác lập, không trái pháp luật. Nó thông thường bao gồm các điều khoản mới (ví dụ: số lượng) và mức độ thoả thuận của các điều khoản (chất lượng). Việc thiếu các điều khoản này không làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của hợp đồng nhưng sự hiện diện của nó là cần thiết bởi sự tăng hay giảm một số quyền, những trách nhiệm liên quan, những phương thức để hoà giải những bất đồng... thường được ghi nhận và dự liệu để đảm bảo cho quá trình lao động.

3.1.5. Giao kết hợp đồng lao động

3.1.5.1. Nguyên tắc giao kết HĐLĐ

Để đảm bảo cho việc giao kết hợp đồng được thuận lợi, đúng pháp luật, trước hết các bên phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản mà pháp luật quy định, đó là:

- *Tự do- tự nguyện khi giao kết hợp đồng:* Theo nguyên tắc này, mọi sự cưỡng bức, dụ dỗ giao kết hợp đồng đều không được pháp luật thừa nhận. Nếu vi phạm nguyên tắc này, hợp đồng sẽ bị vô hiệu toàn bộ.

- *Bình đẳng:* Nguyên tắc này nói lên tư cách của các bên khi giao kết HĐLĐ. Các bên phải tương đồng về vị trí và phương thức biểu hiện khi thoả thuận giao kết hợp đồng.

- *Không trái pháp luật, đạo đức xã hội và thoả ước lao động tập thể:* Theo nguyên tắc này, pháp luật đòi hỏi các bên trong quá trình xác lập hợp đồng phải tuân thủ pháp luật và thoả ước lao động tập thể. Mặt khác, các bên (nhất là phía người lao động) có thể viện dẫn các quy định của pháp luật cũng như thoả ước lao động tập thể để bảo vệ quyền lợi của mình.

3.1.5.2. Chủ thể giao kết HĐLĐ

- Người lao động:

+ **Đủ độ tuổi quy định:** ít nhất từ đủ 15 tuổi trở lên. Người dưới 15 tuổi cũng có quyền giao kết HĐLĐ nhưng phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp bằng văn bản. Tuy vậy, lao động trẻ em (dưới 18 tuổi) chỉ được giao kết HĐLĐ để làm những công việc nhất định mà pháp luật không cấm sử dụng lao động vị thành niên;

+ Có khả năng lao động.

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;
- + Người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động;
- + Người đại diện theo pháp luật đối với người dưới 15 tuổi và có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi;
- + Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được tiếp tục ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

- Người sử dụng lao động:

- + Là cá nhân, tổ chức được phép sử dụng lao động theo quy định của pháp luật, nếu là cá nhân phải đủ 18 tuổi trở lên;
- + Có các điều kiện đảm bảo cho quá trình sử dụng lao động như quyền kinh doanh, cung ứng dịch vụ, đảm bảo tiền lương cho người lao động.
- + Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động: Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động; tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;
- + Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật;
- + Chủ hộ gia đình;
- + Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động nêu trên không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác giao kết hợp đồng lao động theo mẫu quy định.

3.1.5.3. Trình tự giao kết HĐLĐ

Quá trình giao kết HĐLĐ thường được chia thành ba giai đoạn chủ yếu:

- *Đề nghị giao kết*: Có thể thực hiện một cách trực tiếp hoặc thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm, các phương tiện thông tin đại chúng... Sự đề nghị chỉ có tính chất yêu cầu, không ràng buộc trách nhiệm pháp lý của bên đưa ra yêu cầu.

- *Thương lượng, đàm phán các nội dung:* Ở giai đoạn này, trách nhiệm của các bên đã thể hiện phần nào. Bên sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo cho người lao động tình hình của cơ quan, đơn vị...mình, giới thiệu các vấn đề liên quan đến công việc, lợi ích chung và riêng của người lao động, kể cả triển vọng của đơn vị ấy. Về phía người lao động có bổn phận cung cấp cho bên kia những thông tin cần thiết (kể cả vấn đề đòi tư nếu có liên quan) và thực hiện các hành vi theo hướng dẫn của bên sử dụng lao động để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm tra khả năng lao động của họ (nếu cần).

Nhưng nếu các bên không đạt được thoả thuận với nhau thì cũng không bắt buộc phải giao kết hợp đồng với lý do là đã đàm phán, không phải bồi thường do có thiệt hại vì mất thời gian hay chi phí tốn kém cho đàm phán.

Ngoài ra, để đi đến giao kết một hợp đồng lao động, các bên có thể thoả thuận một thời gian làm thử (thử việc). *Vấn đề thử việc* không phải là bắt buộc đối với tất cả các công việc mà thông thường là do người sử dụng lao động yêu cầu, đó là điều kiện để giao kết hợp đồng chính thức bởi thông qua thử việc người sử dụng lao động có thể kiểm tra tay nghề và trình độ của người lao động trước khi đi đến quyết định giao kết HĐLĐ. Hợp đồng thử việc có thể được giao kết riêng hoặc là một điều khoản thoả thuận về việc làm thử trong HĐLĐ chính thức. Cả hai trường hợp này đều không tạo ra sự lệ thuộc pháp lý nào.

3.1.5.4. Hiệu lực của HĐLĐ

HĐLĐ có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

3.1.6. Thực hiện HĐLĐ

Kể từ thời điểm HĐLĐ có hiệu lực, các bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ, tạo điều kiện cho bên kia thực hiện HĐLĐ.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên hoàn toàn bình đẳng với nhau, không bên nào có quyền ép buộc bên kia phải thi hành cam kết. Nếu người lao động không thực hiện hợp đồng thì người sử dụng lao động có thể áp dụng biện pháp chấm dứt quan hệ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Việc thực hiện hợp đồng cũng phải do người lao động đích danh thực hiện, trừ trường hợp được người sử dụng lao động đồng ý.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện HĐLĐ có một số trường hợp pháp luật cho phép các bên được phép thực hiện những thay đổi liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, đó là các trường hợp sau:

3.1.6.1. Tạm thời chuyển người lao động đi làm công việc khác so với HĐLĐ

- *Căn cứ tạm thời chuyển người lao động:*

Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

- + Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;
- + Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
- + Sự cố điện, nước;
- + Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

- ***Thời hạn tạm thời chuyển:*** Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định của Bộ luật Lao động.

- ***Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi tạm thời chuyển người lao động:***

Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.

Người lao động được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

3.1.6.2. Sửa đổi, bổ sung HĐLĐ

Trong quá trình thực hiện HĐLĐ, các bên có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của HĐLĐ nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật, đó là: Bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung của HĐLĐ thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất là 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Việc sửa đổi cũng phải tuân theo nguyên tắc giao kết hợp đồng.

3.1.6.3. Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ

- Khái niệm tạm hoãn thực hiện HĐLĐ

Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là sự tạm thời không thi hành các quyền và nghĩa vụ lao động trong một khoảng thời gian nhất định mà HĐLĐ không bị huỷ bỏ hay bị mất hiệu lực. Sau thời hạn đó, HĐ có thể tiếp tục được thực hiện.

- Các trường hợp tạm hoãn thực hiện HĐLĐ

HĐLĐ được tạm hoãn thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- + Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;
- + Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Luật tố tụng hình sự;
- + Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.
- + Lao động nữ mang thai có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền là nếu tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi.
- + Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
- + Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- + Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;
- + Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận như người lao động xin đi học, xin nghỉ không lương...

- Nhận lại người lao động khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc. Trường hợp người lao động không thể có mặt tại nơi làm việc theo đúng thời hạn quy định thì người lao động phải thoả thuận với người sử dụng lao động về thời điểm có mặt.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí người lao động làm công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết; trường hợp không bố trí được công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết thì hai bên thoả thuận công việc mới và thực

hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Người bị tạm giữ, tạm giam sau khi hết hạn tạm hoãn HĐLĐ được giải quyết như sau: Nếu việc tạm giữ, tạm giam có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động thì khi hết hạn tạm giữ, tạm giam hoặc khi toà án kết luận là người lao động bị oan thì người sử dụng lao động phải nhận họ trở lại làm công việc cũ, trả đủ tiền lương và các quyền lợi khác trong thời gian người lao động bị tạm giữ, tạm giam. Nếu người lao động có vi phạm nhưng toà án miễn tố hoặc không bị tù giam và không bị cấm làm công việc cũ thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm có thể được sắp xếp công việc cũ hoặc bố trí việc làm mới. Trong trường hợp bị tạm giữ, tạm giam không liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động, khi hết thời hạn này, người sử dụng lao động bố trí công việc mới hoặc sắp xếp công việc cũ cho người lao động.

3.1.7. Chấm dứt hợp đồng lao động

4.1.7.1. Khái niệm chấm dứt HĐLĐ

Chấm dứt HĐLĐ chấm dứt việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thoả thuận, chấm dứt quan hệ lao động.

Việc chấm dứt hợp đồng lao động thường kéo theo hậu quả rất lớn, đặc biệt là chấm dứt bất hợp pháp, dễ xảy ra tranh chấp lao động nên cần xác định rõ các trường hợp chấm dứt HĐLĐ, quyền và nghĩa vụ của các bên khi chấm dứt HĐ.

3.1.7.2. Các căn cứ chấm dứt HĐLĐ

Chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp

Là chấm dứt HĐLĐ trong những trường hợp pháp luật cho phép, bao gồm:

- *Đương nhiên chấm dứt HĐLĐ:*

Trong các trường hợp sau:

- + Hết hạn hợp đồng lao động;
- + Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
- + Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động;
- + Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định;
- + Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án;
- + Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đó chết;

+ Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đồ chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

+ Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định.

+ Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Bộ luật lao động 2019.

+ Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật lao động 2019.

+ Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.

- ***Đơn phương chấm dứt HĐLĐ:***

Đối với người lao động: Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong các trường hợp sau đây:

+ *Đối với HĐLĐ không xác định thời hạn:* Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất là 45 ngày.

+ *Đối với HĐLĐ xác định thời:* Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất là 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng; Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

+ *Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:*

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại Điều 29;

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn;

c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật lao động 2019;

e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động

Đối với người sử dụng lao động: Được đơn phương chấm dứt HĐLĐ hợp pháp trong những trường hợp sau:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động;

đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

g) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, về nguyên tắc người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp chấm dứt vì lý do người lao động nghỉ ốm.

Riêng đối với trường hợp đơn phương chấm dứt do người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên, người sử dụng lao động không cần báo trước.

Bên cạnh đó pháp luật cũng quy định *người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ (ngay cả khi có căn cứ chấm dứt) trong các trường hợp sau:*

+ Người lao động bị ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp vượt quá thời hạn theo quy định hoặc cơ quan, đơn vị chấm dứt hoạt động;

+ Người lao động đang nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động cho phép;

+ Lao động nữ nghỉ việc vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Trong tất cả các trường hợp trên, mỗi bên đều có thể từ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trước khi hết thời hạn báo trước. Khi hết thời hạn báo trước, mỗi bên đều có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Chấm dứt HĐLĐ bất hợp pháp

Là những trường hợp các bên chấm dứt HĐLĐ không có lý do chính đáng, không đúng pháp luật. Sự chấm dứt HĐLĐ bất hợp pháp có thể vi phạm các quy định về căn cứ chấm dứt, về nghĩa vụ báo trước, về thời hạn báo trước hoặc về nghĩa vụ bàn bạc, thỏa thuận với đại diện người lao động hoặc cơ quan lao động có thẩm quyền.

Chế tài đối với bên chấm dứt hợp đồng lao động bất hợp pháp được quy định như sau:

- Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng đã ký, phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 2 tháng tiền lương của người lao động.

Nếu người lao động không muốn trở lại làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định, người lao động còn được trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật (cứ mỗi năm làm việc bằng nửa tháng tiền lương của người lao động).

Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

Nếu người sử dụng lao động không muốn nhận người lao động trở lại làm việc và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền bồi thường và trợ cấp thôi việc, hai bên thỏa thuận về khoản bồi thường thêm cho người lao động để chấm dứt HĐLĐ nhưng ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng.

Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

- Người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương.

Người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ (hợp pháp hay bất hợp pháp) đều phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có) theo quy định của Chính phủ.

Trong trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ, nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước, bên vi phạm phải bồi thường cho bên kia một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3.1.7.3. Các quyền và lợi ích của các bên khi chấm dứt HĐLĐ

- Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

- Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên (như chế độ nghỉ hàng năm, số ngày thực tế làm việc...), trường hợp đặc biệt được kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

- Trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản thì quyền lợi của người lao động được giải quyết theo quy định của Luật phá sản doanh nghiệp.

- Người sử dụng lao động ghi lý do chấm dứt HĐLĐ vào sổ lao động và có trách nhiệm trả lại sổ cho người lao động. Ngoài các quy định trong sổ lao động, người sử dụng lao động không được nhận xét thêm điều gì trở ngại cho người lao động tìm việc làm mới.

- Trợ cấp thôi việc:

+ *Đối tượng*: Người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên mà phải thôi việc trong các trường hợp:

- ☐ HĐLĐ đương nhiên chấm dứt;
- ☐ Người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ hợp pháp;
- ☐ Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ hợp pháp (trừ trường hợp NLĐ bị sa thải);
- ☐ Người sử dụng lao động chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật nhưng người lao động không muốn trở lại làm việc hoặc người sử dụng lao động không muốn nhận người lao động trở lại làm việc (cùng với việc trả lương, phụ cấp nếu có và bồi thường).
- ☐ Nếu người lao động bị sa thải thì không được trợ cấp thôi việc.

Pháp luật cũng quy định các trường hợp người lao động không được trợ cấp thôi việc bao gồm:

- ☐ Người lao động bị sa thải do trộm cắp, tham ô..., hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của doanh nghiệp hoặc do bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm;
- ☐ Người lao động nghỉ hưởng chế độ hưu trí hàng tháng;
- ☐ Người lao động bị nghỉ việc do thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc sắp xếp lại doanh nghiệp
- ☐ Người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật (do không đúng căn cứ luật định hoặc vi phạm về nghĩa vụ báo trước).

+ *Mức trợ cấp*: Cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương.

+ *Phương thức trả*: Trực tiếp, một lần, tại nơi làm việc, đúng thời hạn quy định.

- *Trợ cấp mất việc làm*:

+ *Đối tượng*: Do doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà không thể giải quyết được việc làm mới cho người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên, bị mất việc làm.

+ *Mức trợ cấp*: Cứ 1 năm làm việc bằng 1 tháng lương, nhưng thấp nhất cũng bằng 2 tháng lương.

3.2. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

3.2.1. Kỷ luật lao động và trách nhiệm kỷ luật

3.2.1.1. Kỷ luật lao động

- *Khái niệm và ý nghĩa của kỷ luật lao động*

Môi trường lao động có sự tham gia của nhiều người với sự khác nhau về trình độ, tâm lý cũng như các nhu cầu. Chính quá trình lao động chung của con người đòi hỏi phải có trật tự, nề nếp để hướng các hoạt động của từng người vào việc thực hiện kế hoạch chung và tạo ra kết quả chung đã định, nói cách khác là phải có kỷ luật lao động. Nó là yêu cầu khách quan đối với tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức... Sản xuất ngày càng phát triển, cùng với nó là trình độ phân công, tổ chức lao động trong xã hội ngày càng cao và vì vậy, kỷ luật lao động ngày càng trở nên quan trọng.

Dưới góc độ pháp lý, kỷ luật lao động là một chế định của luật lao động, đó là tổng hợp các quy phạm pháp luật quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; quy định những biện pháp khuyến khích người lao động gương mẫu chấp hành cũng như những hình thức xử lý đối với người không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ những nghĩa vụ, trách nhiệm đó.

Trong phạm vi một doanh nghiệp, kỷ luật lao động là việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động.

Việc tuân thủ kỷ luật lao động có ý nghĩa cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. Kỷ luật lao động là cơ sở để tổ chức lao động khoa học và có hiệu quả trong từng đơn vị và trên toàn xã hội; thông qua việc duy trì kỷ luật lao động, người sử dụng lao động có thể bố trí, sắp xếp lao động một cách hợp lý để ổn định sản xuất, ổn định đời sống người lao động và trật tự xã hội nói chung. Mặt khác, việc tuân thủ kỷ luật lao động cũng góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm... Nó cũng là chuẩn mực để người lao động phấn đấu nâng cao trình độ, thông qua đó ổn định cuộc sống và thu nhập. Đồng thời nó cũng góp phần tạo ra quan hệ lao động ổn định, hài hoà.

- Nội dung của kỷ luật lao động

Trong một đơn vị, người lao động và người sử dụng lao động phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Đối với vấn đề kỷ luật lao động, trách nhiệm cơ bản của người sử dụng lao động là phải tạo ra và duy trì kỷ luật lao động; nghĩa vụ của người lao động là phải tuân thủ kỷ luật lao động.

Cụ thể:

Đối với người lao động, họ phải thực hiện các nghĩa vụ như thực hiện các quy định về thời gian làm việc và trật tự trong đơn vị; tuân thủ các quy định về kỹ thuật, công nghệ, an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc; bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, kinh doanh của đơn vị.

Đối với người sử dụng lao động, họ phải thực hiện đúng các quy định về ban hành nội quy lao động như: Về hình thức, nội quy lao động phải bằng văn

bản; về nội dung không được trái với luật lao động, các quy định pháp luật khác và thoả ước lao động tập thể, trong đó, quan trọng nhất là người sử dụng lao động phải quy định về các hành vi vi phạm và các hình thức kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất tương ứng; về thủ tục, trước khi ban hành nội quy, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của BCH công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động hoặc áp dụng trách nhiệm vật chất đối với các hành vi không quy định trong nội quy; tổ chức hợp lý và có biện pháp kiểm tra quá trình lao động của người lao động; thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và vệ sinh môi trường; thực hiện đúng thoả ước lao động tập thể và hợp đồng đã ký kết với người lao động...

3.2.1.2. Trách nhiệm kỷ luật

- Khái niệm và nguyên tắc áp dụng

Trách nhiệm kỷ luật là trách nhiệm pháp lý do người sử dụng lao động áp dụng với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động bằng cách bắt họ phải chịu một trong các hình thức kỷ luật lao động.

Khi áp dụng trách nhiệm kỷ luật, người sử dụng lao động phải tuân thủ các nguyên tắc pháp lý sau:

- + Mỗi hành vi vi phạm kỷ luật lao động chỉ bị xử lý bằng một hình thức kỷ luật thích hợp. Người lao động có nhiều hành vi vi phạm đồng thời thì áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất;

- + Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm nội quy lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi;

- + Không xử lý kỷ luật đối với người lao động đang trong thời gian nghỉ ốm đau, điều dưỡng, nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ, tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm; lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động: Cấm xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động; dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động; xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.

- Căn cứ áp dụng trách nhiệm kỷ luật

Để áp dụng trách nhiệm kỷ luật, cần có hai căn cứ, đó là:

- + Có hành vi vi phạm kỷ luật lao động: Vi phạm các nghĩa vụ trong quan hệ lao động, vi phạm nội quy lao động như thực hiện sai, không đầy đủ hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao...

+ Có lỗi: Người lao động chỉ bị truy cứu trách nhiệm kỷ luật khi họ có hành vi vi phạm kỷ luật lao động và có lỗi. Người lao động sẽ bị coi là có lỗi nếu họ vi phạm kỷ luật lao động trong khi họ có đầy đủ điều kiện và khả năng thực tế để thực hiện các nghĩa vụ lao động của mình.

- Các hình thức kỷ luật lao động

Các hình thức kỷ luật lao động là những hình thức của trách nhiệm kỷ luật do pháp luật quy định, tùy theo mức độ vi phạm và mức độ lỗi mà người sử dụng lao động áp dụng cho phù hợp. Có ba hình thức kỷ luật được pháp luật quy định là:

+ **Khiển trách:** Áp dụng trong trường hợp người lao động vi phạm lần đầu, mức độ vi phạm nhẹ.

+ **Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc cách chức:** Áp dụng đối với người lao động đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời gian 3 tháng kể từ ngày bị khiển trách hoặc có những hành vi vi phạm đã được quy định trong nội quy lao động.

Người sử dụng lao động căn cứ vào mức độ vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và tình hình thực tế của doanh nghiệp, hoàn cảnh của người lao động để lựa chọn một trong hai hình thức này.

+ **Sa thải:** Áp dụng với người lao động vi phạm một trong các trường hợp mà pháp luật quy định và được cụ thể hoá trong nội quy lao động, đó là:

Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

□ Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật. Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật.

□ Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng (Bao gồm: Thiên tai, hỏa hoạn hoặc bản thân, thân nhân bị ốm đau có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động).

Người sử dụng lao động có quyền ***tạm đình chỉ công việc của người lao động*** khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh, sau khi tham khảo ý kiến của BCH công đoàn cơ sở.

Thời hạn tạm đình chỉ công việc không quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. Trong thời gian đó, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc. Hết thời hạn tạm đình chỉ, người lao động phải được tiếp tục làm việc. Nếu có lỗi mà bị xử lý kỷ luật, người lao động cũng phải trả lại số tiền đã tạm ứng; nếu người lao động không có lỗi thì người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương và phụ cấp nếu có trong thời gian tạm đình chỉ công việc.

- Trình tự và thủ tục xử lý kỷ luật lao động

+ *Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động* tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi phạm, trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.

+ *Phiên họp xử lý kỷ luật lao động*:

Thành phần gồm: Đương sự và đại diện BCH công đoàn cơ sở, người có liên quan. Người lao động vi phạm có tự bào chữa hoặc thuê người bào chữa.

Trường hợp người sử dụng lao động đã báo ba lần liên tiếp bằng văn bản mà người lao động vẫn không đến thì có thể xử lý kỷ luật lao động vắng mặt người lao động.

Trong phiên họp, người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động vi phạm và việc xem xét kỷ luật phải được ghi lại thành biên bản. Các thành viên phải ký vào biên bản. Đương sự và công đoàn có quyền bảo lưu ý kiến nhưng phải nêu rõ lý do.

+ *Ra quyết định kỷ luật*: Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động phải ra quyết định bằng văn bản (trừ hình thức khiển trách bằng miệng) trong thời hạn quy định. Nếu xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải, người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với BCH công đoàn cơ sở.

Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động, kể cả tạm đình chỉ công việc là người sử dụng lao động; người được người sử dụng lao động uỷ quyền chỉ được xử lý kỷ luật theo hình thức khiển trách. Các hình thức kỷ luật khác chỉ được uỷ quyền khi người sử dụng lao động đi vắng và phải uỷ quyền bằng văn bản.

Sau khi ra quyết định, người sử dụng lao động phải gửi quyết định cho đương sự và BCH công đoàn cơ sở. Nếu sa thải thì phải gửi văn bản lên cơ quan

quản lý lao động địa phương cùng biên bản họp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Người lao động có quyền khiếu nại lên người sử dụng lao động hoặc Ủy ban nhân dân các cấp hoặc yêu cầu giải quyết theo thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Khi cơ quan có thẩm quyền kết luận về quyết định xử lý kỷ luật lao động của người sử dụng lao động là sai thì người sử dụng lao động phải xin lỗi công khai, khôi phục danh dự và mọi quyền lợi vật chất cho người lao động.

Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng, hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xoá kỷ luật. Trường hợp bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức cách chức thì sau thời hạn 03 năm, nếu tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì không bị coi là tái phạm.

Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ, có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn.

3.2.2. Trách nhiệm vật chất

3.2.2.1. Khái niệm và phạm vi áp dụng

- **Khái niệm:** Trách nhiệm vật chất của người lao động trong quan hệ lao động là trách nhiệm phải bồi thường những thiệt hại về tài sản của người lao động cho người sử dụng lao động do hành vi vi phạm kỷ luật lao động hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong sản xuất, công tác gây ra.

Như vậy, trong khi thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động, nếu người lao động vi phạm kỷ luật lao động gây thiệt hại đến tài sản của người sử dụng lao động thì không những họ phải chịu trách nhiệm kỷ luật mà pháp luật còn quy định trách nhiệm phải bồi thường những thiệt hại do hành vi vi phạm của họ gây ra.

- **Phạm vi áp dụng:** Trách nhiệm vật chất khác trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong dân sự ở phạm vi áp dụng trách nhiệm này. Cụ thể trách nhiệm vật chất chỉ được áp dụng khi nó nằm trong phạm vi như sau:

Thứ nhất, tài sản bị thiệt hại phải là tài sản mà người sử dụng lao động giao cho người lao động để người lao động thực hiện nhiệm vụ của mình; **thứ hai**, thiệt hại về tài sản phải nằm trong quá trình người lao động thực hiện nghĩa vụ lao động của họ; **thứ ba**, lỗi của người gây thiệt hại là lỗi vô ý.

Vi phạm không thoả mãn một trong ba yếu tố trên thì không áp dụng trách nhiệm vật chất, có thể áp dụng trách nhiệm dân sự.

- Căn cứ áp dụng:

Căn cứ áp dụng trách nhiệm vật chất là những điều kiện cần và đủ để người sử dụng lao động quy trách nhiệm vật chất đối với người lao động gây thiệt hại.

Đó cũng là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong quan hệ bồi thường. Để áp dụng trách nhiệm này cần thoả mãn 4 căn cứ sau:

+ Có hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động

+ Có thiệt hại về tài sản: Là sự giảm bớt số lượng hoặc giá trị của tài sản.

Thiệt hại xảy ra phải là thiệt hại thực tế, trực tiếp.

+ Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm kỷ luật lao động và thiệt hại xảy ra. Xác định mối quan hệ này là quá trình chứng minh rằng hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động là nguyên nhân trực tiếp, khách quan và tất yếu dẫn tới thiệt hại.

+ Có lỗi của người lao động vi phạm: Chỉ áp dụng với lỗi vô ý.

- *Mức bồi thường, cách thực hiện bồi thường và thủ tục xử lý*

+ *Nguyên tắc xác định mức bồi thường*: Xác định mức bồi thường không được vượt quá mức thiệt hại trực tiếp mà người lao động đã gây ra; phải căn cứ vào mức độ lỗi và thiệt hại thực tế; không phải bồi thường thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng; phải căn cứ vào hoàn cảnh, nhân thân, tài sản của người lao động.

+ *Cách thực hiện bồi thường*: Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương nhưng không quá 30% lương tháng của người lao động.

Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, dịch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

Trình tự, thủ tục và thời hiệu xử lý trách nhiệm vật chất giống trình tự, thủ tục và thời hiệu xử lý kỷ luật lao động.

Chương 4

LUẬT HÌNH SỰ VÀ LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

4.1. Luật Hình sự

4.1.1. Khái quát chung về luật hình sự

Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy định pháp luật do Nhà nước ban hành trong đó xác định rõ những hành vi vi phạm nào là tội phạm, đồng thời, quy định hình phạt đối với từng tội phạm cụ thể.

Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là các quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội khi người này thực hiện hành vi mà Nhà nước quy định là tội phạm. Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự là phương pháp quyền uy, đó là Nhà nước có quyền tối cao trong việc định đoạt số phận của người phạm tội, buộc họ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm mà họ đã gây ra. Trách nhiệm hình sự là loại trách nhiệm cá nhân, phải do chính người phạm tội trực tiếp gánh chịu.

Luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Trong hệ thống pháp luật của nước ta chỉ có Bộ luật hình sự do Quốc hội ban hành mới quy định về tội phạm và về hình phạt. Ngoài Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất thì không có cơ quan nào khác có quyền quy định về tội phạm và về hình phạt. Hệ thống các quy định của luật hình sự được chia làm hai phần:

- Phần chung: Bao gồm các quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ của Luật hình sự, về những vấn đề chung về tội phạm và hình phạt.

- Phần các tội phạm: Bao gồm các quy định xác định các dấu hiệu pháp lý của từng tội phạm cụ thể, loại hình phạt và mức hình phạt áp dụng đối với từng tội phạm đó.

Phần chung và Phần các tội phạm của Luật hình sự có mối quan hệ mật thiết hữu cơ với nhau tạo nên sự hoàn chỉnh của Luật hình sự. Để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với mỗi tội phạm được quy định ở Phần các tội phạm cần phải tuân thủ những quy định của Phần chung. Mặt khác, Phần chung muốn phát huy tác dụng khi áp dụng vào thực tiễn của công tác đấu tranh chống tội phạm phải dựa vào các quy định ở Phần các tội phạm.

4.1.2. Tội phạm

4.1.2.1. Khái niệm, đặc trưng của tội phạm

4.1.2.1.1. Khái niệm tội phạm

Điều 8 - Bộ Luật hình sự năm 2015 quy định: "*Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự*".

Như vậy tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt.

4.1.2.1.2. Đặc trưng của tội phạm

Theo Luật hình sự, tội phạm phải phản ánh bằng hành vi của con người. Những gì mới chỉ tồn tại trong tư tưởng của con người mà chưa được thể hiện ra bên ngoài bằng một hành vi cụ thể nhất định thì không thể bị coi là tội phạm. Sự xác nhận tội phạm chỉ có thể là hành vi được coi là một trong những nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự Việt Nam. Đó là nguyên tắc hành vi. Theo nguyên tắc này, Luật hình sự Việt Nam không đặt vấn đề trách nhiệm hình sự đối với tư tưởng của con người cũng như đối với cả những biểu hiện của con người ra thế giới khách quan mà không phải là hành vi.

Hành vi bị coi là tội phạm được phân biệt với những hành vi không phải là tội phạm qua bốn đặc trưng cơ bản, đó là:

a. Tính nguy hiểm cho xã hội

Đây là dấu hiệu cơ bản, quan trọng nhất, quyết định những dấu hiệu khác của tội phạm. Một hành vi sở dĩ được Luật hình sự quy định là tội phạm và phải chịu trách nhiệm hình sự vì nó có tính nguy hiểm cho xã hội. Trong bất cứ trường hợp nào, nếu xác định được rằng, hành vi không mang tính nguy hiểm cho xã hội, hoặc "Tính chất nguy hiểm cho xã hội không đánh kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác" (Khoản 4 - Điều 8 - Bộ luật Hình sự năm 2015).

Tính nguy hiểm cho xã hội, về khách quan là đã gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho các quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ. Đó là những quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng, một khi bị xâm hại có thể gây ra những thiệt hại đáng kể cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm không những là căn cứ để phân biệt hành vi là tội phạm với những hành vi vi phạm pháp luật khác; mà còn là cơ sở để đánh giá mức độ nghiêm trọng nhiều hay ít của hành vi phạm tội, qua đó giúp cho việc cá thể hoá trách nhiệm hình sự được chính xác.

Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm có tính khách quan, không phụ thuộc vào ý chủ quan của nhà làm luật. Do vậy, để khẳng định hành vi nhất định là hành vi nguy hiểm cho xã hội thì phải thông qua việc đánh giá nhiều tình tiết khác nhau của hành vi hoặc có liên quan đến hành vi. Những tình tiết đó, trước hết phải kể đến là: Tính chất của quan hệ xã hội bị xâm hại, tính chất của hành vi khách quan, mức độ thiệt hại gây ra hoặc đe dọa gây ra cho quan hệ xã hội bị xâm hại, tính chất và mức độ lỗi, nhân thân của người phạm tội...

b. Tính có lỗi

Luật hình sự chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đã có lỗi trong việc thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Lỗi là thái độ chủ quan của một người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả của hành vi đó, thể hiện dưới dạng cố ý hoặc cố ý.

Một người được coi là có lỗi khi thực hiện một hành vi gây thiệt hại cho xã hội, nếu hành vi đó là kết quả của việc tự lựa chọn và quyết định của chủ thể trong khi có đủ điều kiện để lựa chọn và quyết định một xử sự khác phù hợp với đòi hỏi của xã hội.

Luật hình sự Việt Nam không chấp nhận việc quy tội khách quan, nghĩa là truy cứu trách nhiệm hình sự một người chỉ dựa vào việc người đó đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, mà không căn cứ vào lỗi của họ. Bởi vì, mục đích của việc áp dụng hình phạt không phải là nhằm trừng trị hành vi, mà là để trừng trị người đã thực hiện tội phạm nhằm cải tạo, giáo dục họ. Mục đích này không thể đạt được nếu áp dụng hình phạt đối với người không có lỗi.

c. Tính trái pháp luật hình sự

Tội phạm bao giờ cũng được quy định trong luật hình sự. Điều 2 - Bộ Luật hình sự quy định: "*Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ Luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự*".

Tính trái pháp luật hình sự mặc dù chỉ là dấu hiệu về hình thức pháp lý còn phản ánh dấu hiệu về nội dung là tính nguy hiểm cho xã hội nhưng nó vẫn có tính độc lập tương đối. Nếu bỏ qua dấu hiệu này thì có thể dẫn đến tình trạng tùy tiện cho việc xác định một hành vi như thế nào là tội phạm. Việc xác định tội danh và quyết định hình phạt sẽ bị chi phối bởi những tình cảm cá nhân, suy nghĩ cục bộ... do vậy sẽ dẫn đến việc xử lý người phạm tội không thống nhất, ngược lại nếu quá coi trọng tính trái pháp luật sẽ dẫn đến tình trạng xác định tội phạm met cách hình thức, máy móc.

d. Tính phải chịu hình phạt

Hình phạt là một biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất, luôn gắn liền với tội phạm và chỉ áp dụng đối với người có hành vi phạm tội. Nói cách khác, tội phạm có tính chịu hình phạt. Tức là, bất cứ một hành vi phạm tội nào cũng đều bị đe dọa có thể phải chịu một biện pháp cưỡng chế Nhà nước nghiêm khắc nhất là hình phạt. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc áp dụng và thi hành trong thực tế hình phạt cụ thể là có tính chất bắt buộc tuyệt đối cho mọi trường hợp phạm tội. Trong thực tế vẫn có trường hợp người phạm tội không phải chịu hình phạt. Đó là những trường hợp có tội nhưng được miễn trách nhiệm hình sự, được miễn hình phạt hoặc được miễn chấp hành hình phạt...

Tính phải chịu hình phạt là một dấu hiệu của tội phạm, nhưng không phải thuộc tính bên trong của tội phạm như dấu hiệu về nội dung là tính nguy hiểm cho xã hội, về hình thức là tính trái pháp. Một hành vi bị coi là phạm tội đã có tính chịu hình phạt vì đó là hành vi nguy hiểm cho xã hội và trái pháp luật hình sự. Vì vậy, tính chịu hình phạt là một dấu hiệu tất yếu được quy định bởi tính nguy hiểm cho xã hội và tính trái pháp luật hình sự. Mặc dù vậy, nếu không coi tính chịu hình phạt là dấu hiệu của tội phạm thì sẽ không thấy được hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất luôn gắn liền với tội phạm và chỉ có thể áp dụng đối với người có hành vi phạm tội. Trong những trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự, được miễn hình phạt hoặc được miễn chấp hành hình phạt, người phạm tội tuy không phải chịu hình phạt nhưng không có nghĩa tội phạm mà họ thực hiện không có tính chịu hình phạt, mà trái lại, khả năng chịu hình phạt vẫn có. Người phạm tội không phải chịu hình phạt vì đã được miễn với những lý do khác nhau. Đó là những lý do đã được quy định trong các Điều 29, 59, và 62 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tội phạm bao giờ cũng phải có đầy đủ bốn dấu hiệu nêu trên. Đó không chỉ là cơ sở cho việc xác định tội danh đúng đắn mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và áp dụng Luật hình sự vào thực tiễn đấu tranh chống tội phạm.

4.1.2.2. Phân loại tội phạm

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi. Bộ luật hình sự năm 2015 phân chia thành bốn nhóm tội phạm khác nhau đó là:

Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm đến 07 năm tù;

Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm đến 15 năm tù;

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Sự phân biệt bốn nhóm tội như vậy là cơ sở thống nhất cho việc xây dựng các khung hình phạt cho các tội phạm cụ thể đồng thời cũng là những căn cứ pháp lý thống nhất giúp cho các nhà hoạt động thực tiễn có thể thực hiện được nguyên tắc cá thể hoá hình phạt khi áp dụng luật hình sự.

4.1.2.3. Các yếu tố cấu thành tội phạm

Cấu thành tội phạm là tổng hợp những dấu hiệu chung có tính đặc trưng cho một loại tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự.

Về mặt cấu trúc, tội phạm có đặc điểm chung là đều được hợp thành bởi những yếu tố nhất định, tồn tại không tách rời nhau nhưng có thể phân chia được trong tư duy và do vậy có thể cho phép nghiên cứu độc lập với nhau. Những yếu tố đó theo khoa học luật hình sự Việt Nam là khách thể, chủ thể, mặt khách quan và mặt chủ quan của tội phạm.

4.1.2.3.1. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại đạt điều kiện về năng lực luật định và đã thực hiện hành vi phạm tội cụ thể.

Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội có khả năng nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình và có khả năng điều khiển được hành vi ấy.

Năng lực trách nhiệm hình sự là điều kiện cần thiết để có thể xác định con người có lỗi khi họ thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Chỉ người có năng lực trách nhiệm hình sự mới có thể là chủ thể của tội phạm.

Về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Bộ luật Hình sự hiện hành xác định như sau: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hai điều kiện: Năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi là những dấu hiệu pháp lý bắt buộc là cá nhân chủ thể của tội phạm.

Ngoài hai dấu hiệu trên, chủ thể của một số tội phạm đòi hỏi phải có thêm một số dấu hiệu đặc biệt khác, vì chỉ khi có những dấu hiệu đó chủ thể mới có thể thực hiện được hành vi phạm tội của những tội này. Ví dụ: Chỉ những người có chức vụ, quyền hạn liên quan đến tài sản mới có thể thực hiện được hành vi tham ô tài sản (Điều 353). Những chủ thể của tội phạm đòi hỏi thêm những dấu hiệu đặc biệt đó được gọi là những chủ thể đặc biệt.

Chủ thể tội phạm là pháp nhân thương mại thì năng lực trách nhiệm hình sự chính là năng lực pháp nhân trong hoạt động thương mại. Đó là những loại hình doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.

4.1.2.3.1. Khách thể của tội phạm

Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại.

Bất kỳ một hành vi phạm tội cũng đều gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho một hoặc một số quan hệ xã hội nhất định được luật hình sự bảo vệ, không có sự xâm hại quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ thì không có tội phạm.

Khách thể của tội phạm được phân thành các loại sau:

- Khách thể chung của tội phạm là tổng hợp các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ khỏi sự xâm hại của tội phạm. Đó là độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, chế độ kinh tế, chính trị, nền văn hoá, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân...

- Khách thể loại của tội phạm là nhóm các quan hệ xã hội cùng tính chất được luật hình sự bảo vệ khỏi sự xâm hại của tội phạm. Khách thể loại là cơ sở để hệ thống hoá các quy phạm trong phần tội phạm thành từng chương: Các tội phạm về chức vụ, các tội xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ...

- Khách thể trực tiếp của tội phạm là quan hệ xã hội cụ thể bị tội phạm cụ thể trực tiếp xâm hại.

4.1.2.3.3. Mặt chủ quan của tội phạm

Mặt chủ quan của tội phạm là những diễn biến tâm lý bên trong của người phạm tội đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội và hậu quả do hành vi đó gây ra.

Hoạt động tâm lý bên trong của người phạm tội bao gồm nhiều nội dung khác nhau. Nhưng nội dung thuộc mặt chủ quan của tội phạm có ý nghĩa về mặt hình sự là những nội dung trả lời các câu hỏi:

- Điều gì thúc đẩy người phạm tội thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội? (động cơ).

- Người phạm tội nhằm đạt được điều gì qua việc thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội? (mục đích).

- Lý trí và ý chí củ người phạm tội đối với những biểu hiện bên ngoài của tội phạm như thế nào? (lỗi).

Bất kỳ tội phạm nào cũng phải là hành vi có lỗi. Lỗi là thái độ tâm lý của một người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra được biểu hiện dưới hình thức cố ý hoặc vô ý.

Người thực hiện hành vi gây thiệt hại cho xã hội bị coi là có lỗi nếu hành vi đó là kết quả của sự tự lựa chọn của họ trong khi có đủ điều kiện khách quan và chủ quan để lựa chọn và thực hiện xử sự khác phù hợp với đòi hỏi của xã hội.

Lỗi cố ý gồm hai hình thức là cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp.

Lỗi cố ý trực tiếp là lỗi của người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra (Điều 10 - Bộ luật Hình sự năm 2015).

Lỗi cố ý gián tiếp là lỗi của người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó, tuy không mong muốn nhưng có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra (Điều 10 - Bộ luật Hình sự năm 2015).

Lỗi vô ý cũng gồm hai hình thức là vô ý vì quá tự tin và vô ý vì quá cẩu thả.

Lỗi vô ý phạm tội vì quá tự tin là lỗi trong trường hợp người phạm tội tuy thấy hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được nên vẫn thực hiện và đã gây ra hậu quả nguy hiểm đó (Điều 11 - Bộ luật Hình sự năm 2015).

Lỗi vô ý phạm tội vì cẩu thả là lỗi trong trường hợp người phạm tội đã gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội nhưng do cẩu thả nên không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả đó, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả này (Điều 11 - Bộ luật Hình sự năm 2015).

Lỗi là một dấu hiệu bắt buộc trong mọi cấu thành tội phạm. Luật hình sự không chấp nhận việc buộc tội khách quan, tức là buộc tội không cần xem xét người thực hiện hành vi có lỗi hay không. Việc thừa nhận nguyên tắc có lỗi trong luật hình sự chính là sự thừa nhận và tôn trọng quyền tự do của con người. Đó cũng là cơ sở bảo đảm khả năng khách quan thực hiện được mục đích của hình phạt "không chỉ nhằm trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội mà còn giáo dục họ ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới; giáo dục người, pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm".

Mục đích và động cơ phạm tội tuy cũng là dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm nhưng không phải luôn luôn có ý nghĩa quyết định tính chất nguy hiểm cho xã hội của tội phạm và do vậy cũng không phải là luôn luôn là dấu hiệu đặc trưng của tội phạm để phân biệt giữa các loại tội phạm với nhau. Mục đích và động cơ chỉ được phản ánh trong một số cấu thành tội phạm cơ bản là dấu hiệu bắt buộc.

4.1.2.3.4. Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm là mặt bên ngoài của tội phạm, bao gồm những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài thế giới khách quan.

Bất kỳ tội phạm nào khi xảy ra cũng đều có những biểu hiện diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài mà con người có thể trực tiếp nhận biết được. Đó là:

- Hành vi khách quan nguy hiểm cho xã hội:
- Hậu quả nguy hiểm cho xã hội cũng như mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả:
- Các điều kiện bên ngoài của việc thực hiện hành vi phạm tội (công cụ, phương tiện, phương pháp, thủ đoạn, thời gian, địa điểm phạm tội...)

Trong mặt khách quan của tội phạm, hành vi khách quan là biểu hiện cơ bản. Những biểu hiện khác của mặt khách quan chỉ có ý nghĩa khi có hành vi khách quan. Không thể nói đến hậu quả của tội phạm cũng như những biểu hiện khách quan khác như công cụ, phương tiện, địa điểm, thời gian...khi không có hành vi khách quan.

Hành vi khách quan được phản ánh trong tất cả các cấu thành tội phạm. Không có hành vi khách quan thì không có tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm có ba đặc điểm sau:

- Hành vi khách quan của tội phạm phải có tính nguy hiểm cho xã hội. Tính nguy hiểm của hành vi thể hiện ở chỗ hành vi đó gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. Tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi khách quan phụ thuộc vào tính chất của quan hệ xã hội mà hành vi xâm hại cũng như tính chất và mức độ gây ra thiệt hại hoặc đe dọa gây ra thiệt hại cho quan hệ xã hội đó.
- Hành vi khách quan của tội phạm là hoạt động có ý thức và ý chí. Khi nói đến hành vi của con người phải hiểu đó là hành vi có ý thức. Không thể có hành vi khách quan của tội phạm mà những biểu hiện bên ngoài của con người không được lý trí của họ kiểm soát hoặc không được ý chí của họ điều khiển.
- Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi trái pháp luật hình sự. Hành vi trái pháp luật nếu nó thoả mãn đầy đủ của hành vi của 1 tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự.

Hành vi khách quan của tội phạm có thể được thực hiện bằng hành vi hành động hoặc hành vi không hành động.

+ Hành vi hành động phạm tội là hình thức của hành vi khách quan làm biến đổi tình trạng bình thường của đối tượng tác động của tội phạm gây thiệt hại cho khách thể của tội phạm thông qua việc chủ thể làm một việc bị pháp luật cấm.

+ Hành vi không hành động phạm tội là hình thức của hành vi khách quan làm biến đổi tình trạng bình thường của đối tượng tác động của tội phạm gây thiệt hại cho khách thể của tội phạm thông qua việc chủ thể không làm một việc mà pháp luật yêu cầu phải làm mặc dù có đủ điều kiện để làm.

Nghiên cứu mặt khách quan của tội phạm có ý nghĩa thực tiễn trong việc định tội, định khung hình phạt, xác định mức độ trách nhiệm hình sự cũng như xác định mặt chủ quan của tội phạm.

4.1.2.4. Các tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi

Trong thực tế chúng ta gặp không ít những trường hợp hành vi của con người về hình thức có các dấu hiệu của tội phạm nhưng trong hành vi đó có một số tình tiết nhất định làm mất tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi nên hành vi ấy không bị coi là tội phạm thậm chí còn có ích cho xã hội. Đó là:

4.1.2.4.1. Sự kiện bất ngờ

Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

4.1.2.4.2. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự

Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

4.1.2.4.3. Phòng vệ chính đáng

Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì muốn bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm vì nó phù hợp với lợi ích của xã hội, hỗ trợ nhà nước trong việc duy trì trật tự xã hội, chống lại những hành vi xâm hại các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ.

Phòng vệ chính đáng là quyền của công dân nhưng không phải là nghĩa vụ pháp lý. Công dân có thể không sử dụng quyền đó vì những lý do khác nhau. Với chế định phòng vệ chính đáng, Nhà nước cho phép công dân được bảo vệ quyền và lợi ích của mình hay lợi ích của xã hội khi có hành vi xâm phạm. Nhưng phòng

vệ chính đáng không có nghĩa là xử lý tùy tiện vì quyền xử lý các hành vi trái pháp luật thuộc về nhà nước. Do vậy phòng vệ chính đáng cũng có giới hạn của nó. Một hành vi chỉ được coi là phòng vệ chính đáng khi nó có các điều kiện thể hiện sự phòng vệ là chính đáng phù hợp với lợi ích của xã hội. Bao gồm các điều kiện sau:

- *Cơ sở phát sinh quyền phòng vệ chính đáng là:*

+ Có hành vi xâm hại đang hiện tại xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền và lợi ích chính đáng của người phòng vệ hoặc của người khác.

+ Hành vi xâm hại này phải nguy hiểm đáng kể cho xã hội, trái pháp luật và luôn luôn là hành vi cố ý (nguy hiểm không đáng kể thì không cần phòng vệ).

+ Hành vi xâm hại đó phải đang xảy ra (hành vi xâm hại đã bắt đầu, đang diễn ra và chưa kết thúc) hoặc tuy chưa xảy ra nhưng đe dọa xảy ra ngay tức khắc (hành vi xâm hại chưa phải là thực tại nhưng căn cứ vào các mặt khách quan, chủ quan, không gian, thời gian xảy ra sự việc cho thấy người phòng vệ có cơ sở để khẳng định rằng sự xâm hại sẽ xảy ra ngay tức khắc tại chỗ với mình).

Do vậy sẽ không phải là phòng vệ chính đáng và phải chịu trách nhiệm hình sự nếu ở trong các trường hợp sau:

-> Hành vi xâm hại tuy có xảy ra nhưng thực sự đã kết thúc thì không đòi hỏi phải có hành vi ngăn chặn nữa, sự phòng vệ lúc này hoàn toàn không đạt được mục đích mà chỉ có thể là sự trả thù. Trường hợp này pháp luật gọi là phòng vệ quá muộn.

-> Khi hành vi xâm hại chưa xảy ra, chưa có biểu hiện sẽ xảy ra ngay tức khắc mà một người đã có hành vi phòng vệ cũng không được coi là phòng vệ chính đáng. Trường hợp này pháp luật gọi là phòng vệ quá sớm.

- *Nội dung của phòng vệ chính đáng:* khi có cơ sở cho phép phòng vệ, người phòng vệ có quyền phòng vệ bằng cách chống lại người đang có hành vi xâm hại bằng cách gây thiệt hại cho chính người có hành vi xâm hại đó tức là phải nhằm vào chính kẻ tấn công - người đang gây ra sự nguy hiểm cho xã hội để làm tê liệt và loại trừ sự xâm hại nguy hiểm ấy. Sự chống trả này có khi nhằm trực tiếp vào kẻ tấn công cũng có thể nhằm vào công cụ, phương tiện mà người đó sử dụng. Nhưng dù bằng hình thức nào đi chăng nữa thì sự chống trả của người phòng vệ đều có thể gây ra những thiệt hại nhất định cho người có hành vi xâm hại.

- *Phạm vi phòng vệ:* sự chống trả của người phòng vệ là sự chống trả lại một cách cần thiết. Điều này có nghĩa là biện pháp chống trả của người phòng vệ (phương pháp, phương tiện, thiệt hại) đặt trong hoàn cảnh cụ thể phải là những biện pháp cần thiết để có thể ngăn chặn được hành vi xâm hại, hạn chế được những thiệt hại có thể bị hành vi xâm hại gây ra. Biện pháp đó đặt trong hoàn cảnh cụ

thể là cần thiết và phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi tấn công.

Phòng vệ chính đáng không phải là biện pháp trả thù mà là biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi nguy hiểm cho xã hội. Mục đích đó trong nhiều trường hợp chỉ đạt được bằng cách phải gây ra cho kẻ tấn công một thiệt hại lớn hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là cho phép người phòng vệ muốn gây ra thiệt hại như thế nào cũng được. Vì vậy pháp luật cũng quy định trường hợp vượt quá giới hạn của phòng vệ chính đáng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng được coi là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Vượt quá giới hạn của phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. Đây là trường hợp người phòng vệ đã dùng những phương tiện, phương pháp gây ra thiệt hại quá đáng cho người xâm hại mà tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại cũng như hoàn cảnh cụ thể chưa đòi hỏi phải dùng phương tiện, phương pháp đó.

4.1.2.4.2. Tình thế cấp thiết

Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh gây thiệt hại cho quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Như vậy tình thế cấp thiết là tình thế của người đứng trước sự đe dọa đến lợi ích được pháp luật bảo vệ, vì muốn bảo vệ lợi ích này họ không còn cách nào khác là phải gây ra một thiệt hại cho một lợi ích khác cũng được pháp luật bảo vệ.

Trong luật hình sự, người được coi là hành động trong tình thế cấp thiết khi người đó đã biết hy sinh một cách hợp lý lợi ích nhỏ để bảo vệ lợi ích khác lớn hơn, cần thiết hơn. Chính vì tính hợp lý này mà hành động trong tình thế cấp thiết không bị coi là tội phạm.

Điều kiện hợp pháp của tình thế cấp thiết:

- Về tính chất của nguồn nguy hiểm:

+ Sự nguy hiểm này là thực tế đang gây ra hoặc đe dọa gây ra những thiệt hại nhất định cho quyền và lợi ích chính đáng của bản thân người hành động, cho lợi ích của Nhà nước, tập thể, quyền lợi chính đáng của người khác.

+ Nguồn nguy hiểm này có thể do con người, súc vật hay các sức mạnh tự nhiên hoặc do những nguyên nhân khác gây ra.

+ Nếu sự nguy hiểm chưa xảy ra hoặc xảy ra ở mức độ không đáng kể thì không phải là tình thế cấp thiết. Nếu sự nguy hiểm đã qua hoặc thiệt hại đã xảy ra thì tình thế cấp thiết cũng không còn nữa.

- Về phương thức khắc phục: Trong hoàn cảnh lúc này chủ thể đứng trước hai lợi ích, cả hai lợi ích này đều cần được bảo vệ. Chủ thể hành động bằng cách hy sinh lợi ích này để bảo vệ lợi ích khác. Tuy nhiên hy sinh một lợi ích chỉ được thực hiện trong điều kiện đó là biện pháp cuối cùng và duy nhất. Có nghĩa là khi còn những biện pháp khác để loại trừ khả năng gây thiệt hại cho xã hội đòi hỏi chủ thể phải thực hiện biện pháp đó.

- Phạm vi hành động. Chủ thể hy sinh lợi ích tức là gây thiệt hại cho một lợi ích, lợi ích này đòi hỏi phải nhỏ hơn lợi ích cần bảo vệ. Trong thực tế việc so sánh, đánh giá 2 lợi ích đặc biệt trong trường hợp hai lợi ích không cùng tính chất là một việc khó khăn phức tạp đòi hỏi tính khách quan, tính logic và tính hệ thống trong việc đánh giá.

Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người gây ra thiệt hại phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên sự vượt quá giới hạn của tình thế cấp thiết xuất phát từ động cơ và mục đích tích cực vì vậy luật hình sự coi đây là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

4.1.2.4.3. Các trường hợp khác

Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội: Hành vi của người để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm tội mà không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực cần thiết gây thiệt hại cho người bị bắt giữ thì không phải là tội phạm. Trường hợp gây thiệt hại do sử dụng vũ lực rõ ràng vượt quá mức cần thiết, thì người gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm hình sự.

Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Hành vi gây ra thiệt hại trong khi thực hiện việc nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới mặc dù đã tuân thủ đúng quy trình, quy phạm, áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa thì không phải là tội phạm. Người nào không áp dụng đúng quy trình, quy phạm, không áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa mà gây thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên. Người thực hiện hành vi gây thiệt hại trong khi thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên trong lực lượng vũ trang nhân dân để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nếu đã thực hiện đầy đủ quy trình báo cáo người ra mệnh lệnh nhưng người ra mệnh lệnh vẫn yêu cầu chấp hành mệnh lệnh đó, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp này người ra mệnh lệnh phải chịu trách nhiệm hình sự.

4.1.3. Hình phạt

4.1.3.1. Khái niệm, mục đích của hình phạt

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật hình sự, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc

pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó.

Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội mà còn giáo dục họ ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới; giáo dục người, pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

4.1.3.2. Đặc điểm của hình phạt

- *Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất.*

Trong tất cả các biện pháp cưỡng chế Nhà nước thì hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất, được áp dụng phổ biến và có lịch sử lâu đời. Nhà nước sử dụng hình phạt như một công cụ hữu hiệu trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Người bị kết án có thể bị tước bỏ hoặc hạn chế quyền tự do, quyền về tài sản, về chính trị thậm chí cả quyền sống. Bên cạnh đó hình phạt cũng để lại những hậu quả pháp lý là án tích cho người bị kết án trong thời hạn nhất định theo quy định của pháp luật.

- *Hình phạt do luật hình sự quy định và do Toà án quyết định.*

Hình phạt trong Bộ luật hình sự được quy định cả phần chung và phần riêng. Phần chung quy định những vấn đề có tính nguyên tắc liên quan đến hình phạt như mục đích, hệ thống, căn cứ quyết định hình phạt... Phần các tội phạm quy định các loại hình phạt và mức hình phạt cho từng loại tội phạm cụ thể. Trong mọi trường hợp không áp dụng hình phạt đối với những hành vi không được Bộ luật hình sự quy định là tội phạm, tất nhiên là không được áp dụng một loại hình phạt nào đó nếu nó không được quy định trong hệ thống hình phạt.

Toà án nhân dân là cơ quan có quyền nhân danh nhà nước tuyên bố một người là có tội và áp dụng hình phạt đối với họ, ngoài ra không có một cơ quan nào khác.

- *Hình phạt chỉ có thể áp dụng đối với người có hành vi phạm tội*

Xuất phát từ nguyên tắc chịu trách nhiệm cá nhân và cá thể hoá hình phạt, hình phạt chỉ áp dụng đối với người đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm, không thể áp dụng đối với thành viên trong gia đình cũng như những người thân khác của người phạm tội, thậm chí cả trong trường hợp người phạm tội cố tình trốn tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Luật hình sự Việt nam không cho phép việc chấp hành hình phạt thay cho người phạm tội cho dù là tự nguyện.

Hình phạt tịch thu tài sản chỉ áp dụng đối với tài sản thuộc sở hữu của người thực hiện hành vi phạm tội mà không được phép tịch thu tài sản thuộc sở hữu của các thành viên khác trong gia đình hoặc người thân của người phạm tội

- **Hình phạt mang nội dung giai cấp.**

Hình phạt được quy định bởi bản chất giai cấp của Nhà nước, nhà nước sử dụng hình phạt như công cụ sắc bén để bảo vệ lợi ích của mình và xã hội.

4.1.3.3. Hệ thống hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam

- **Hình phạt đối với cá nhân phạm tội**

a. *Cảnh cáo*: Là sự khiển trách công khai của Nhà nước do Toà án áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

b. *Phạt tiền*: là hình phạt tước của người phạm tội khoản tiền nhất định sung công quỹ nhà nước.

c. *Cải tạo không giam giữ*: Là hình phạt chính có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng có nơi làm việc ổn định hoặc nơi thường trú rõ ràng khi xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội.

d. *Trục xuất*: là hình phạt buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

e. *Tù có thời hạn*: là việc buộc người bị kết án phải chấp hành án tại trại giam trong một thời gian nhất định để học tập, lao động và cải tạo.

f. *Tù chung thân*: Là hình phạt tù không có thời hạn được áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình.

g. *Tử hình*: Là hình phạt đặc biệt có nội dung cưỡng chế nghiêm khắc nhất, tước bỏ quyền sống của người bị kết án, chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

h. *Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định*: là hình phạt bổ sung được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định sau khi chấp hành xong hình phạt tù hoặc sau khi bản án có hiệu lực pháp luật thì có thể họ có điều kiện phạm tội mới.

i. *Cấm cư trú*: Là hình phạt bổ sung buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú hoặc thường trú ở một số địa phương nhất định kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

j. *Quản chế*: Là hình phạt bổ sung buộc người bị kết án phải cư trú, làm ăn, sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương.

x. *Tước một số quyền công dân*: là hình phạt bổ sung áp dụng đối với công dân Việt Nam bị kết án tù về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác được Bộ luật hình sự quy định.

y. *Tịch thu tài sản*: Là hình phạt bổ sung nhằm tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án về tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng sung quỹ nhà nước.

- ***Hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội***

Đối với pháp nhân thương mại phạm tội thì hình phạt chính bao gồm: Phạt tiền; Đình chỉ hoạt động có thời hạn; Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Hình phạt bổ sung bao gồm: Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; Cấm huy động vốn; Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính.

4.2. Luật Phòng chống tham nhũng

4.2.1. Khái niệm và đặc trưng của tham nhũng

Trên thế giới có nhiều định nghĩa khác nhau về tham nhũng. Theo nghĩa rộng, tham nhũng được hiểu là hành vi của bất kỳ người nào có chức vụ, quyền hạn hoặc được giao nhiệm vụ, quyền hạn và lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc nhiệm vụ được giao để vụ lợi. Theo nghĩa hẹp, tham nhũng là sự lợi dụng quyền lực nhà nước để trục lợi riêng.

Ở Việt Nam, khái niệm tham nhũng được quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. Theo đó, "*tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi*".

Đặc trưng của tham nhũng

Theo các quy định của pháp luật hiện hành, tham nhũng có những đặc trưng cơ bản như sau:

- *Chủ thể tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn.*

Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp; người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

- *Chủ thể tham nhũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao.*

Chủ thể tham nhũng phải sử dụng "chức vụ, quyền hạn của mình như một phương tiện để thực hiện hành vi sai trái nhằm mang lại lợi ích cho mình, cho gia đình mình hoặc cho người khác. Một người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật vì động cơ vụ lợi nhưng hành vi đó không lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì không coi là tham nhũng (ví dụ như hành vi trộm cắp).

- *Mục đích của hành vi tham nhũng là vụ lợi*

Mục đích của hành vi tham nhũng phải là mục đích vụ lợi. Vụ lợi là lợi ích

vật chất (tiền, nhà, đất, các vật có giá trị...) hoặc lợi ích tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn mong muốn đạt được từ việc thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình. Lợi ích đó có thể cho mình, cho gia đình mình hoặc người thân của mình

4.2.2. Biểu hiện và tác hại của tham nhũng

Bộ luật hình sự, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã phân loại tham nhũng theo hành vi. Theo đó, những hành vi sau đây thuộc nhóm hành vi tham nhũng:

1. Tham ô tài sản.
2. Nhận hối lộ.
3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.
7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.
8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.
9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi.
10. Những nhiễu vì vụ lợi.
11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợiⁱ.

Trong 12 hành vi tham nhũng nêu trên, có 7 hành vi đã được quy định trong

Bộ luật Hình sự năm 2015, bao gồm:

- Tham ô tài sản
- Nhận hối lộ.
- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.
- Giả mạo trong công tác.

Tham nhũng gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- **Tác hại về chính trị**

Tham nhũng là trở lực đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tác hại nguy hiểm của tệ tham nhũng, lãng phí ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về kinh tế, xã hội hoặc một nhiệm vụ quản lý nhất định của Nhà nước. Tổng quát hơn, sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Nhân dân chính là động lực, chủ thể, mục đích của cách mạng.

- **Tác hại về kinh tế**

Tham nhũng gây thiệt hại rất lớn về tài sản của Nhà nước, của tập thể và của công dân.

Trong thời gian qua, nạn tham nhũng diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước, tiền, thời gian, công sức của nhân dân. Hậu quả của hành vi tham nhũng không chỉ là việc tài sản, lợi ích của Nhà nước, của tập thể hoặc của cá nhân bị biến thành tài sản riêng của người thực hiện hành vi tham nhũng, mà nguy hiểm hơn, hành vi tham nhũng còn gây thiệt hại, gây thất thoát, lãng phí một lượng lớn tài sản của Nhà nước, của tập thể, của công dân.

- **Tác hại về xã hội**

Tham nhũng xâm phạm, thậm chí làm thay đổi, đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, tha hóa đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước.

Tham nhũng không chỉ phát sinh ở trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai... mà còn có xu hướng lan sang các lĩnh vực từ trước tới nay ít có khả năng xảy ra tham nhũng như văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao. Thậm chí, cả những lĩnh vực lẽ ra không thể có

tham nhũng, cả dưới góc độ đạo đức và pháp luật, như lĩnh vực phúc lợi xã hội hay bảo vệ pháp luật. Hành vi tham nhũng xảy ra không ít trong các chương trình trợ cấp cho thương binh, liệt sỹ, các gia đình chính sách; tham nhũng cả tiền, hàng hóa cứu trợ cho đồng bào gặp thiên tai, tham nhũng trong cả xét duyệt công dân di tích lịch sử, văn hóa, thi đua khen thưởng. Tham nhũng xảy ra ở ngay các cơ quan bảo vệ pháp luật, những cơ quan tượng trưng cho công lý và công bằng xã hội.

4.2.3. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Phòng ngừa tham nhũng là một trụ cột của Luật phòng, chống tham nhũng. Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định khá đầy đủ các biện pháp phòng ngừa đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng hiện nay.

- *Công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị*
 - Công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản;
 - Công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 - Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước;
 - Công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
 - Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ;
 - Công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp nhà nước;
 - Công khai, minh bạch trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;
 - Kiểm toán việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước;
 - Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất;
 - Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng nhà ở;
 - Công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục;
 - Công khai, minh bạch trong lĩnh vực y tế;
 - Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoa học – công nghệ;
 - Công khai, minh bạch trong lĩnh vực thể dục thể thao;
 - Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước;
 - Công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân;
 - Công khai, minh bạch trong lĩnh vực tư pháp;
 - Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức – cán bộ.
- *Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.*

Xây dựng ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
- Kiểm tra và xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

- *Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức*

- Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm:

+ Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc.

+ Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

+ Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật Nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết.

+ Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của chính phủ.

+ Những người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

+ Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán – tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

+ Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp.

- *Mình bạch tài sản thu nhập*

Những người sau đây phải kê khai tài sản :

- Cán bộ từ cấp phó trưởng phòng của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên và tương đương trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Một số cán bộ công chức tại xã, phường, thị trấn, người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân;

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

4.2.4. Một số tội phạm tham nhũng cụ thể

Các tội phạm về tham nhũng là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện một cách cố ý xâm phạm đến tài sản, uy tín của cơ quan, tổ chức; xâm phạm đến tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định 7 tội phạm về tham nhũng, đó là: tội tham ô tài sản; tội nhận hối lộ; tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ; tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và tội giả mạo trong công tác. Dưới đây là một số tội phạm tham nhũng cụ thể:

4.2.4.1. Tội tham ô tài sản

a. Định nghĩa

Tham ô là một trong những hành vi tham nhũng, nhưng có thể nói cùng với hành vi nhận hối lộ, nó là hành vi chủ yếu của tham nhũng, đặc trưng điển hình của tệ tham nhũng.

Tội tham ô tài sản được quy định tại Bộ luật hình sự, theo đó: *Tham ô tài sản là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý*

b. Cấu thành tội tham ô tài sản

*** Chủ thể của tội tham ô tài sản**

Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội tham ô tài sản cũng phải đảm bảo các yếu tố (điều kiện) cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự quy định trong Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đối với tội tham ô tài sản, chỉ những người sau đây mới có thể là chủ thể của tội phạm này:

Trước hết, người phạm tội tham ô phải là người có chức vụ, quyền hạn và có trách nhiệm đối với tài sản mà họ chiếm đoạt.

Người có chức vụ, quyền hạn thường là những cán bộ, công chức hoặc là người thông qua quan hệ hợp đồng lao động hoặc do một hình thức khác, tuy không phải là cán bộ, công chức, họ chỉ được các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hợp đồng làm một công việc nhất định thường xuyên hay theo thời vụ hoặc trong một thời gian nhất định có liên quan đến việc quản lý tài sản và họ có trách nhiệm quản lý đối với tài sản.

Người có chức vụ, quyền hạn, phải là người có trách nhiệm quản lý tài sản, nếu họ không có trách nhiệm quản lý tài sản thì cũng không thể là chủ thể của tội tham ô tài sản được. Đây là điều kiện cần và đủ để một người có thể trở thành chủ thể của tội tham ô tài sản và cũng là dấu hiệu để phân biệt với một số tội phạm khác có tính chất chiếm đoạt.

Người có trách nhiệm đối với tài sản là người được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý tài sản như: Thủ quỹ, thủ kho, kế toán, người được giao vận chuyển tài

sản của cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị mình... Ngoài ra, còn những người tuy không được giao trực tiếp quản lý tài sản nhưng lại có trách nhiệm trong việc quyết định việc thu chi, xuất nhập, mua bán, trao đổi tài sản như: Giám đốc công ty, Chủ nhiệm hợp tác xã, người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức là chủ tài khoản hoặc là người có quyền quyết định về tài sản của cơ quan, tổ chức mình.

Do những đặc điểm riêng về chủ thể của tội tham ô tài sản, nên khoa học luật hình sự cho rằng, chủ thể của tội tham ô tài sản là chủ thể đặc biệt, tức là chỉ có những người có chức vụ, quyền hạn mới tham ô được. Tuy nhiên, khẳng định này chỉ đúng đối với trường hợp vụ án tham ô không có đồng phạm, còn trong vụ án có đồng phạm thì có thể có cả những người không có chức vụ, quyền hạn nhưng người thực hành trong vụ án có đồng phạm, thì nhất thiết phải là người có chức vụ, quyền hạn.

** Khách thể của tội tham ô tài sản*

Khách thể của tội tham ô vẫn là quan hệ sở hữu về tài sản của Nhà nước của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, vì nó trực tiếp xâm phạm đến quan hệ sở hữu. Tuy nhà làm luật không quy định sở hữu xã hội chủ nghĩa nhưng thực chất tội phạm này chỉ xâm phạm quan hệ sở hữu. Ý kiến khác lại cho rằng, tội tham ô là tội do những người có chức vụ, quyền hạn thực hiện là tội phạm thuộc nhóm tội tham nhũng nên khách thể của tội phạm phải là những hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, còn quan hệ sở hữu chỉ là đối tượng tác động của tội phạm (thông qua quan hệ sở hữu mà xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức).

Tuy nhiên, khách thể của tội phạm này không còn là dấu hiệu để phân biệt tội tham ô tài sản với các tội phạm khác có tính chất chiếm đoạt nên việc xác định khách thể của tội tham ô tài sản chỉ có ý nghĩa về lý luận mà không có ý nghĩa trong thực tiễn xét xử nên chúng tôi chỉ nêu những quan điểm khác nhau để tham khảo và tiếp tục nghiên cứu.

** Mặt khách quan của tội tham ô tài sản*

- Về hành vi khách quan:

Trước hết, người phạm tội tham ô tài sản phải là người có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình có để chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản là do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện và hành vi chiếm đoạt tài sản đó có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của họ, nếu họ không có chức vụ, quyền hạn đó thì họ khó có thể thực hiện việc chiếm đoạt tài sản; chức vụ, quyền hạn là điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện việc chiếm đoạt tài sản một cách dễ dàng.

Chiếm đoạt tài sản do mình có trách nhiệm quản lý. Về trách nhiệm quản lý tài sản đã được phân tích ở các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm. Chiếm đoạt tài sản là một hành vi chuyển dịch bất hợp pháp tài sản từ chủ sở hữu thành tài sản của mình hoặc của người khác mà mình quan tâm.

Hành vi chuyển dịch bất hợp pháp tài sản có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, có trường hợp người phạm tội tự chuyển dịch tài sản như: Thủ quỹ tự lấy tiền trong két, thủ kho tự lấy tài sản trong kho đem bán...

Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của người phạm tội tham ô hoàn toàn tương tự như thủ đoạn của người phạm tội trộm cắp tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản... như: lén lút, công khai, gian dối, bội tín... Cũng chính vì đặc điểm này mà tội tham ô tài sản được coi là trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người có chức vụ, quyền hạn có trách nhiệm quản lý tài sản.

- Về hậu quả:

Đối với tội tham ô tài sản, thiệt hại trước hết là thiệt hại về tài sản, ngoài ra còn có những thiệt hại khác phi vật chất.

Hậu quả của tội tham ô tài sản, xét về phương diện các yếu tố cấu thành tội phạm thì không phải là dấu hiệu bắt buộc, tức là, dù hậu quả chưa xảy ra nhưng hành vi vẫn cấu thành tội phạm.

** Mục đích của tội tham ô tài sản*

Tội tham ô cũng là tội phạm có tính chất chiếm đoạt nên cũng như đối với tội có tính chất chiếm đoạt khác, người phạm tội thực hiện hành vi của mình là cố ý (cố ý trực tiếp), tức là, người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra; không có trường hợp tham ô tài sản nào được thực hiện do cố ý gián tiếp, vì người phạm tội bao giờ cũng mong muốn chiếm đoạt được tài sản.

Mục đích chiếm đoạt tài sản của người phạm tội bao giờ cũng có trước khi thực hiện hành vi chiếm đoạt sản. Vì vậy, có thể nói mục đích chiếm đoạt tài sản là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội tham ô tài sản. Nếu mục đích của người phạm tội chưa đạt được (chưa chiếm đoạt được tài sản), thì thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Tuy nhiên, ngoài mục đích chiếm đoạt, người phạm tội còn có thể có những mục đích khác cùng với mục đích chiếm đoạt hoặc chấp nhận mục đích chiếm đoạt của người đồng phạm khác thì người phạm tội cũng chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tham ô tài sản, nếu mục đích đó không cấu thành một tội phạm độc lập.

4.2.5.2. Tội nhận hối lộ

a. Định nghĩa

Tội nhận hối lộ được quy định tại Bộ luật hình sự, theo đó: *Nhận hối lộ là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.*

b. Cấu thành tội nhận hối lộ

** Chủ thể của tội nhận hối lộ*

Ngoài các điều kiện chung về chủ thể của tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự ra thì người phạm tội nhận hối lộ phải là người có chức vụ, quyền hạn. Tuy nhiên khác với chủ thể của tội tham ô tài sản là chủ thể của tội nhận hối lộ là những người có chức vụ, quyền hạn không phải là người có trách nhiệm quản lý tài sản. Phạm vi chức vụ, quyền hạn của người phạm tội nhận hối lộ rộng hơn. Tuy nhiên, người phạm tội nhận hối lộ lại không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản do mình có trách nhiệm quản lý mà là lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác.

Người có chức vụ, quyền hạn, phải là người có trách nhiệm trong việc giải quyết những yêu cầu của người đưa hối lộ. Những yêu cầu đó có thể là yêu cầu về lợi ích vật chất hoặc phi vật chất của người đưa hối lộ. Tuy nhiên, người có chức vụ, quyền hạn khi giải quyết những yêu cầu của người đưa hối lộ phải là việc thực hiện công vụ. Nếu có chức vụ, quyền hạn khi giải quyết yêu cầu cho người khác để nhận tiền hoặc lợi ích vật chất của họ, nhưng không phải là thực hiện công vụ thì không phải là nhận hối lộ.

Người có trách nhiệm đối với việc giải quyết yêu cầu của người đưa hối lộ là người được giao nhiệm vụ và do nhiệm vụ đó mà họ quyền đối với việc giải quyết yêu cầu của người khác. Việc xác định trách nhiệm của một người đối với việc giải quyết yêu cầu của người đưa hối lộ là rất quan trọng, vì trong thực tế không ít trường hợp người đưa hối lộ cứ tưởng rằng người mà mình đưa hối lộ là người có trách nhiệm giải quyết được yêu cầu của mình.

Chủ thể của tội nhận hối lộ là chủ thể đặc biệt, tức là chỉ có những người có chức vụ, quyền hạn mới nhận hối lộ được. Tuy nhiên, khẳng định này chỉ đúng đối với trường hợp vụ án nhận hối lộ không có đồng phạm, còn trong vụ án có đồng phạm thì có thể có cả những người không có chức vụ, quyền hạn nhưng họ chỉ có thể là người tổ chức, người xúi dục, người giúp sức, còn người thực hành trong vụ án có đồng phạm, thì nhất thiết phải là người có chức vụ, quyền hạn. Dù là người có chức vụ, quyền hạn hay người đồng phạm khác trong vụ án thì họ cũng chỉ trở thành chủ thể của tội phạm này trong những trường hợp sau:

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 2. khoản 3 và khoản 4 Điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, vì các trường hợp nhận hối lộ quy định tại các khoản trên là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, đối với những người này họ chỉ có thể là đồng phạm trong vụ án nhận hối lộ với vai trò giúp sức, vì những người này chưa thể trở thành cán bộ, công chức. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử cũng có trường hợp người dưới 16 tuổi lại là người chủ mưu, khởi xướng, giúp sức trong vụ án nhận hối lộ có đồng phạm như: Được người có chức vụ, quyền hạn giao cho đi nhận tiền của người đưa hối lộ, được giao đưa thư, đưa tài liệu...

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định của Bộ luật hình sự mà chỉ những người đủ 16 tuổi trở lên mới chịu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ theo khoản 1 của Điều 354 Bộ luật hình sự, vì theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Đối với tội nhận hối lộ quy định tại khoản 1 của điều luật là tội phạm nghiêm trọng.

** Khách thể của tội nhận hối lộ*

Có thể xác định được ngay khách thể của tội nhận hối lộ là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, cao hơn là chính thể bị sụp đổ. Vì vậy, hối lộ cùng với tham ô được Đảng và Nhà nước ta coi là quốc nạn, phải đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi.

** Mặt chủ quan của tội nhận hối lộ*

Người phạm tội nhận hối lộ thực hiện hành vi của mình là cố ý (cố ý trực tiếp), tức là, người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra; không có trường hợp nhận hối lộ nào được thực hiện do cố ý gián tiếp, vì người phạm tội bao giờ cũng mong muốn nhận được của hối lộ.

Mặc dù điều luật quy định đã nhận hoặc sẽ nhận, nhưng không vì thế mà cho rằng ý định nhận hối lộ của người phạm tội có sau khi thực hiện hành vi phạm tội, cho dù người phạm tội sẽ nhận của hối lộ sau khi làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì người nhận hối lộ vẫn có ý định nhận của hối lộ trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Mục đích của người phạm tội là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu người phạm tội không có ý định nhận của hối lộ thì dù họ có làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ thì cũng không phải nhận hối lộ.

** Mặt khách quan của tội nhận hối lộ*

- Hành vi khách quan:

Trước hết, cũng tương tự như tội tham ô tài sản, người phạm tội nhận hối lộ phải là người có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình. Nếu ở tội tham ô tài sản, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn là để chiếm đoạt tài sản do mình có trách nhiệm quản lý, thì ở tội nhận hối lộ người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn mà mình có để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ. Có thể nói thủ đoạn của hai tội phạm này như nhau chỉ khác nhau ở mục đích thực hiện hành vi.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ là do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện và hành vi nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của họ, nếu họ không có chức vụ, quyền hạn đó thì họ khó có thể thực hiện việc nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của

người đưa hối lộ; chức vụ, quyền hạn là điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện việc nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ.

Tuy nhiên, người phạm tội có việc lợi dụng chức vụ để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ thì mới bị coi là nhận hối lộ. Nếu hành vi để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện không liên quan gì đến chức vụ, quyền hạn của họ thì dù họ có chức vụ, quyền hạn thì cũng không bị coi là nhận hối lộ.

Trực tiếp hoặc qua trung gian để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ

Trực tiếp nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ là trường hợp người nhận hối lộ trực tiếp nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ không thông qua người khác như: A đưa hối lộ cho B bằng cách trực tiếp cầm tiền giao cho B hoặc chuyển tiền vào tài khoản của B tại ngân hàng.

Qua trung gian để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ là trường hợp người nhận hối lộ không trực tiếp nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ hoặc người đưa hối lộ không trực tiếp đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người nhận hối lộ. Qua trung gian không nhất thiết là chỉ qua người thứ ba mà có thể qua nhiều người, nhiều khâu nhưng cuối cùng thì tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ cũng đến với người nhận hối lộ.

Đã nhận nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác Là trường hợp người nhận hối lộ đã nhận được tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác mà người đưa hối lộ trực tiếp hoặc qua trung gian giao cho, tức là người nhận hối lộ đã chiếm hữu số tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác như: đã cầm tiền, đã cầm tài sản, tiền đã được chuyển vào tài khoản của mình (Ngân hàng đã báo có)...

Sẽ nhận nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác là trường hợp người đưa hối lộ hứa sẽ giao tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người nhận hối lộ nhưng chưa giao. Người nhận hối lộ và người đưa hối lộ mới thoả thuận với nhau về của hối lộ, nhưng chưa có việc giao nhận của hối lộ.

Dù người nhận hối lộ đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ thì cũng không vì thế mà cho rằng, trường hợp đã nhận là tội phạm hoàn thành còn trường hợp sẽ nhận là tội phạm chưa hoàn thành, vì giá trị của hối lộ không phải là hậu quả của tội phạm mà nó chỉ là phương tiện để thực hiện tội phạm, một dấu hiệu khách quan của tội nhận hối lộ, vì tội nhận hối lộ không phải là tội phạm có tính chất chiếm đoạt, nên hành vi nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác không phải là hành vi chiếm đoạt.

Hành vi trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác *dưới bất kỳ hình thức nào* là việc nhận của hối lộ không bị phụ thuộc vào thủ đoạn mà người đưa và nhận hối lộ thực hiện. Hình thức ở đây là hình thức nhận

hối lộ chứ không phải là hình thức giao nhận tiền, nên khi xác định hình thức nhận hối lộ trong một số trường hợp núp dưới danh nghĩa tưởng như hợp pháp thì cần xác định hình thức đó chính là thủ đoạn đưa và nhận hối lộ, còn hình thức cụ thể đó chỉ là thủ đoạn giao quyết để che giấu tội phạm. Tuy nhiên, nếu hình thức đó không phải là thủ đoạn đưa và nhận hối lộ thì đó lại là một quan hệ thuộc các lĩnh vực dân sự, kinh tế, hành chính hoặc chỉ là quan hệ thuộc lĩnh vực đạo đức. Ví dụ: Thông qua một hợp đồng mua bán, nhưng hợp đồng mua bán đó về hình thức và nội dung đều đúng với quy định của pháp luật; người mua chuyển tiền, người bán giao hàng với giá cả thỏa thuận thì không thể coi đó là thủ đoạn đưa và nhận hối lộ được.

Như vậy hình thức nhận hối lộ không phải là dấu hiệu bắt buộc đối với cấu thành tội nhận hối lộ, nhưng căn cứ vào hình thức ta xác định được thủ đoạn của hành vi nhận hối lộ do người phạm tội thực hiện. Trong nhiều trường hợp chính thông qua hình thức nhận hối lộ giúp ta xác định được đó là thủ đoạn nhận hối lộ hay chỉ là quan hệ xã hội khác..

Để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ

Đây là dấu hiệu rất quan trọng thuộc mặt khách quan của tội phạm này và thực tiễn xét xử khi xác định dấu hiệu này của tội nhận hối lộ trong nhiều vụ án các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng còn có nhiều ý kiến khác nhau dẫn đến việc xác định hành vi phạm tội cũng rất khác nhau. Quan niệm chung của xã hội khi đánh giá một hành vi đưa và nhận hối lộ là phải có tiền thì mới được việc dù việc đó giải quyết đúng hay sai người có yêu cầu giải quyết không quan tâm. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng cũng thường nêu ra lý do người nhận hối lộ không làm trái công vụ để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt và coi đây là một tình tiết giảm nhẹ đặc biệt.

Để làm một việc vì lợi ích của người đưa hối lộ là hành vi của người nhận hối lộ đã sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình để giải quyết cho người đưa hối lộ một việc nào đó, mà việc đó có lợi cho chính người đưa hối lộ như: Thẩm phán nhận hối lộ của bị cáo để cho bị cáo được hưởng án treo; Điều tra viên nhận hối lộ của bị can đang bị tạm giam để đề xuất thay đổi biện pháp tạm giam thành biệt pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; Kiểm sát viên nhận hối lộ của bị can để ra quyết định đình chỉ điều tra; Thủ trưởng nhận hối lộ của cán bộ cấp dưới để tăng lương, bổ nhiệm, đề bạt họ; Cán bộ của Bộ thương mại nhận hối lộ của doanh nghiệp để cấp “quota” xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp đó; Cán bộ của sở nhà đất hoặc của Ủy ban nhân dân nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.v.v... Có thể nói, trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có thể xảy ra việc đưa và nhận hối lộ. Tuy nhiên, để phân biệt dấu hiệu này với các dấu hiệu khác, thì chỉ cần xem người phạm tội làm một việc và việc đó đem lại lợi cho

người đưa hối lộ hay người khác mà người đưa hối lộ quan tâm. Nếu người nhận hối lộ làm một việc vì lợi ích của chính người đưa hối lộ thì thuộc trường hợp phạm tội này, nếu người nhận hối lộ làm một việc lại vì lợi ích của người khác không phải của người đưa hối lộ thuộc trường hợp “để làm một việc theo yêu cầu của người đưa hối lộ”.

Để làm một việc theo yêu cầu của người đưa hối lộ là trường hợp người nhận hối lộ đã sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình để giải quyết cho người đưa hối lộ một việc nào đó, mà việc đó đem lại lợi ích cho người khác mà người đưa hối lộ quan tâm như: Bố mẹ đưa hối lộ để xin học cho con; con đưa hối lộ chạy tội cho bố mẹ; vợ hoặc chồng đưa hối lộ để chạy tội cho chồng hoặc vợ; anh chị em đưa hối lộ để chạy tội cho nhau... Có khi người đưa hối lộ chỉ yêu cầu người nhận hối lộ thi hành nhanh một quyết định của cơ quan, tổ chức có lợi cho người mà người đưa hối lộ quan tâm.

Không làm một việc vì lợi ích của người đưa hối lộ là trường hợp vì đã nhận hối lộ nên người phạm tội không thực hiện một việc mà lẽ ra họ phải thực hiện và do không thực hiện nhiệm vụ đó nên đã đem lại lợi ích cho người đưa hối lộ. Ví dụ: Không thi hành lệnh bắt tạm giam, để người phạm tội bỏ trốn; không ra lệnh thi hành án phạt tù để người bị kết án bỏ trốn hoặc hết thời hiệu thi hành án; không bắt người đang phá trại giam để bỏ trốn; không thi hành lệnh cưỡng chế giải phóng mặt bằng; không lập biên bản vi phạm trong trường hợp bắt được hàng lậu, hàng cấm; không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội hoặc không kết án người có tội... Khoa học luật hình sự coi trường hợp phạm tội này là không hành động, tức là không làm một việc mà pháp luật bắt người có chức vụ, quyền hạn phải làm.

Không làm một việc theo yêu cầu của người đưa hối lộ là trường hợp cũng tương tự như trường hợp không làm một việc vì lợi ích của người đưa hối lộ, chỉ khác ở chỗ: lợi ích mà người nhận hối lộ đem lại không phải cho người đưa hối lộ mà là cho người khác mà người đưa hối lộ quan tâm, có thể là những người thân của người đưa hối lộ nhưng cũng có thể chỉ là bạn bè của người đưa hối lộ.

Tóm lại, bị coi là hành vi nhận hối lộ nếu người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trực tiếp hoặc quan trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào.

- Hậu quả:

Cũng như hậu quả của các tội phạm khác, hậu quả của tội nhận hối lộ là những thiệt hại vật chất hoặc phi vật chất cho xã hội.

Hậu quả của hành vi nhận hối lộ không phải là dấu hiệu bắt buộc, tức là, dù hậu quả chưa xảy ra thì hành vi của người phạm tội vẫn cấu thành tội phạm.

Đối với tội nhận hối lộ, nhà làm luật quy định giá trị của hối lộ làm ranh giới phân biệt tội phạm với hành vi vi phạm, nên có quan điểm cho rằng, giá trị của hối lộ là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm và nếu chưa nhận hối lộ

hoặc đã nhận hối lộ nhưng giá trị của hối lộ dưới mức quy định của điều luật thì chưa cấu thành tội phạm; coi giá trị của hối lộ là hậu quả của tội phạm. Đây là sự nhầm lẫn giữa hậu quả của tội phạm với giá trị của hối lộ là dấu hiệu khách quan của tội phạm.

4.2.4.3. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

a. Định nghĩa

Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 355-Bộ luật Hình sự 2015, theo đó: *Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn và đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn đó để chiếm đoạt tài sản của người khác.*

b. Cấu thành tội phạm

** Chủ thể của tội phạm*

Đối với tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm cũng là các dấu hiệu rất quan trọng để xác định hành vi phạm tội; là dấu hiệu phân biệt sự khác nhau giữa tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với các tội phạm khác có tính chất chiếm đoạt.

Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản cũng phải đảm bảo các yếu tố (điều kiện) cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự quy định trong Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đối với tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, chỉ những người sau đây mới có thể là chủ thể của tội phạm này:

Trước hết, người phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản phải là người có chức vụ, quyền hạn.

Nếu so sánh với tội tham ô tài sản, thì người phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác không phải là người có liên quan đến việc quản lý tài sản; còn nếu so sánh với tội nhận hối lộ, thì người phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản cũng tương tự như người phạm tội nhận hối lộ ở chỗ: Phạm vi chức vụ, quyền hạn của người phạm tội rộng hơn, chỉ khác nhau ở chỗ: Người phạm tội nhận hối lộ lại không có hành vi chiếm đoạt tài sản mà là lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ.

** Khách thể của tội phạm*

Khách thể của tội phạm này là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền; cao hơn là chính thể bị sụp đổ. Vì vậy, tham ô hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác là đối tượng phải đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi.

** Mặt chủ quan của tội phạm*

Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác, cũng là tội phạm có tính chất chiếm đoạt nên cũng như đối với tội có tính chất chiếm đoạt khác, người phạm tội thực hiện hành vi của mình là cố ý (cố ý trực tiếp), tức là, người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra; không có trường hợp lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác nào được thực hiện do cố ý gián tiếp, vì người phạm tội bao giờ cũng mong muốn chiếm đoạt được tài sản.

Mục đích chiếm đoạt tài sản của người phạm tội bao giờ cũng có trước khi thực hiện hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn. Vì vậy, có thể nói mục đích chiếm đoạt tài sản là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm này. Nếu mục đích của người phạm tội chưa đạt được (chưa chiếm đoạt được tài sản), thì thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Tuy nhiên, ngoài mục đích chiếm đoạt, người phạm tội còn có thể có những mục đích khác cùng với mục đích chiếm đoạt hoặc chấp nhận mục đích chiếm đoạt của người đồng phạm khác thì người phạm tội cũng chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác, nếu mục đích đó không cấu thành một tội phạm độc lập.

** Mặt khách quan của tội phạm*

Đối với tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác, các dấu hiệu thuộc mặt khách quan cũng là những dấu hiệu rất quan trọng để xác định hành vi phạm tội cũng như để phân biệt tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác với các tội phạm khác có tính chất chiếm đoạt hoặc do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện.

Hành vi khách quan

Trước hết, người phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác, phải là người có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình.

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn là hành vi vượt quá quyền hạn của mình, làm trái công vụ để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Theo điều văn của điều luật thì người có chức vụ, quyền hạn chỉ là chủ thể của tội phạm này khi họ *lạm dụng* chức vụ, quyền hạn mà họ có. Vậy nếu họ không lạm dụng mà chỉ *lợi dụng* chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của người khác thì có phạm tội này không? Nếu *lợi dụng* chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản do mình có trách nhiệm quản lý là hành vi tham ô, nhưng nếu *lợi dụng* chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản do người khác quản lý thì có phạm tội không, nếu có thì đó là tội gì?

Lợi dụng và *lạm dụng* là hai thuật ngữ khác nhau, mặc dù trước đây được giải thích là một. Tuy nhiên, ranh giới giữa hành vi *lợi dụng* với hành vi *lạm dụng* không phải bao giờ cũng phân biệt được một cách rạch ròi.

Vì vậy, khi xác định một người có lạm dụng chức vụ, quyền hạn hay không, trước hết phải căn cứ vào chức vụ họ đang giữ và theo pháp luật thì họ có những

quyền gì? Nếu trong khi thi hành công vụ họ đã thực hiện vượt quá giới hạn cho phép là lạm dụng chức vụ, quyền hạn. Đây là dấu hiệu cơ bản để phân biệt giữa hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong nhiều tội phạm có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn và lạm dụng chức vụ, quyền hạn.

Người có chức vụ, quyền hạn, lạm dụng chức vụ, quyền hạn phải chiếm đoạt tài sản của người khác thì mới cấu thành tội phạm này. Nếu không có hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác, mà chỉ gây thiệt hại đến lợi ích của người khác thì tùy trường hợp mà người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ theo Điều 357 Bộ luật hình sự; tội nhận hối lộ theo điểm b khoản 2 Điều 354 Bộ luật hình sự hoặc tội tha trái pháp luật người đang bị tạm giam, giữ theo Điều 378 Bộ luật hình sự ...

Cũng như hành vi chiếm đoạt trong các tội có tính chất chiếm đoạt khác, hành vi chiếm đoạt trong tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác là hành vi chuyển dịch trái phép tài sản thuộc sở hữu hoặc quyền quản lý hợp pháp thành của mình hoặc của người khác mà mình quan tâm. Hành vi chiếm đoạt tài sản vừa là hệ quả vừa là mục đích của hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn của người phạm tội.

Hậu quả

Cũng như hậu quả của các tội phạm về chức vụ khác, hậu quả của tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác là những thiệt hại vật chất hoặc phi vật chất cho xã hội.

Đối với tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác, thiệt hại trước hết là thiệt hại về tài sản, ngoài ra còn có những thiệt hại khác phi vật chất.

Hậu quả của tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác, xét về phương diện các yếu tố cấu thành tội phạm thì không phải là dấu hiệu bắt buộc, tức là, dù hậu quả chưa xảy ra nhưng hành vi vẫn cấu thành tội phạm.

Chương 5:

LUẬT TỔ TỤNG DÂN SỰ VÀ LUẬT TỔ TỤNG HÌNH SỰ

5.1. Tổ tụng dân sự

5.1.1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh của Luật Tổ tụng dân sự

Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân và chủ thể khác bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận quyền dân sự; buộc chấm dứt hành vi vi phạm; buộc xin lỗi, cải chính công khai; buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự; buộc bồi thường thiệt hại. Bên cạnh đó, các phương thức để giải quyết các tranh chấp, vi phạm về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động rất phong phú và đa dạng như: giải quyết bằng trung gian, hoà giải hay trọng tài hoặc giải quyết bằng con đường Toà án. Mỗi phương thức giải quyết đều có những ưu điểm riêng. Tuy vậy, các bên tranh chấp thường lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp bằng con đường Toà án.

Theo quy định tại Điều 1 Luật tổ chức Toà án nhân dân thì các Toà án là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nhiệm vụ xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế, hành chính và giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật để bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự, nhân phẩm của công dân. Do vậy, mỗi khi quyền và lợi ích hợp pháp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của các cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác bị xâm phạm hoặc có tranh chấp thì các chủ thể này theo thủ tục do pháp luật quy định có quyền yêu cầu Toà án bảo vệ.

Khi các chủ thể yêu cầu Toà án giải quyết các tranh chấp, yêu cầu phát sinh từ quan hệ pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động được Toà án thụ lý giải quyết làm phát sinh vụ việc dân sự. Những vụ việc dân sự mà trong đó Toà án giải quyết các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa các bên được gọi là vụ án dân sự, còn đối với những vụ việc dân sự trong đó Toà án không giải quyết các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa các bên mà giải quyết các yêu cầu được gọi là việc dân sự.

Quá trình giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự đã làm phát sinh nhiều mối quan hệ giữa các chủ thể bao gồm Toà án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, đương sự, người đại diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch và những chủ thể khác liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự, thi hành án dân sự. Hoạt động của các chủ thể trên tiến hành theo một trình tự, thủ tục thống nhất do pháp luật quy định được gọi là *thủ tục tổ tụng dân sự* và tổng hợp các quy

phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự gọi là Luật tố tụng dân sự. Vì vậy, có thể chỉ ra khái niệm Luật tố tụng dân sự như sau:

Luật tố tụng dân sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa toà án, viện kiểm sát với các đương sự và những người tham gia tố tụng khác trong quá trình toà án giải quyết vụ án dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, pháp nhân, nhà nước và các chủ thể khác.

Từ khái niệm nêu trên, ta có thể thấy rằng đối tượng điều chỉnh của Luật tố tụng dân sự Việt Nam là các quan hệ giữa Toà án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, đương sự, người đại diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch, người định giá tài sản và người liên quan phát sinh trong tố tụng dân sự. Trong các quan hệ được Luật tố tụng dân sự Việt Nam điều chỉnh thì quan hệ giữa Toà án với đương sự là mối quan hệ trung tâm của hoạt động tố tụng.

5.1.2. Các nguyên tắc đặc trưng của Luật Tố tụng dân sự

Nguyên tắc của Luật tố tụng dân sự Việt Nam là những nguyên lý, tư tưởng pháp lý được ghi nhận trong các văn bản pháp luật tố tụng dân sự nhằm chỉ đạo và định hướng cho việc xây dựng và thực hiện pháp luật tố tụng dân sự.

Tất cả các hành vi được tiến hành trong quá trình tố tụng, như khởi kiện, hòa giải, chuẩn bị xét xử hay xét xử... đều phải được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự. Bất cứ một hành vi nào, do bất kỳ ai thực hiện trong bất cứ giai đoạn tố tụng nào vi phạm một trong số các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự thì đều là không hợp pháp.

Việc tuân thủ triệt để các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự trước hết tạo điều kiện cho cơ quan xét xử tiến hành tố tụng một cách thuận lợi và nhanh chóng. Đồng thời, nó còn bảo đảm cho đương sự có điều kiện để thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình, trên cơ sở đó mà các lợi ích hợp pháp của bản thân đương sự được tôn trọng. Bên cạnh đó, nó cũng có tác dụng ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật và những biểu hiện tiêu cực trong quá trình giải quyết vụ án dân sự.

Luật tố tụng dân sự quy định rất nhiều các nguyên tắc, trong đó, có thể phân chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất bao gồm các nguyên tắc tố tụng chung, được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 và cụ thể hóa tại các Luật tố tụng cụ thể như tố tụng dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng hành chính, bao gồm: Nguyên tắc xét xử có hội thẩm nhân dân, Nguyên tắc hai cấp xét xử, Nguyên tắc thẩm phán xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, Nguyên tắc tranh tụng (mới)...Nhóm thứ hai bao gồm các nguyên tắc đặc thù của tố tụng dân sự, chỉ Luật tố tụng dân sự mới quy định, thể hiện bản chất của Luật tố tụng dân sự bao gồm: Nguyên tắc quyền tự

quyết định và tự định đoạt của đương sự, Nguyên tắc cung cấp chứng cứ và chứng minh, Nguyên tắc hòa giải trong tố tụng dân sự...

5.1.2.1. Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự

Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự là quyền pháp luật quy định, theo đó cho phép đương sự tự do thể hiện ý chí và thực hiện theo ý chí đó trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự.

Nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự có cội nguồn từ nguyên tắc trong giao lưu dân sự. Trong đó, các quan hệ dân sự được phát sinh, thay đổi, chấm dứt trên cơ sở tự nguyện, tự thỏa thuận, tự chịu trách nhiệm và bình đẳng giữa các chủ thể. Quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự là sự phản ánh của quyền tự định đoạt của các chủ thể trong mối quan hệ dân sự. Quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự chính là quy phạm luật hình thức, được phái sinh bởi các nguyên tắc trong giao lưu dân sự do pháp luật nội dung quy định.

Điều 5 BLTTDS 2015 quy định:

1. Đương sự có quyền quyết định việc khởi kiện, yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự và chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đó.

2. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền chấm dứt, thay đổi yêu cầu của mình hoặc thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội”.

Nội dung của nguyên tắc tự định đoạt của đương sự được thể hiện qua các quá trình tố tụng: trước khi khởi kiện; sau khi khởi kiện và Tòa án thụ lý vụ việc; khi giải quyết vụ việc và sau khi đã có bản án, quyết định của Tòa án.

Trước khi khởi tòa án thụ lý vụ việc: Hiến pháp cũng như BLTTDS quy định các cá nhân, cơ quan, tổ chức khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền để được pháp luật bảo vệ. Tuy pháp luật quy định quyền khởi kiện, quyền yêu cầu nhưng việc thực hiện hay không lại do chính các chủ thể này quyết định. Nội dung việc khởi kiện, yêu cầu cũng do các bên tự quyết định, Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự và chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đó.

Sau khi khởi kiện, Tòa án thụ lý, giải quyết vụ việc: Sau khi cá nhân, cơ quan tổ chức thực hiện quyền khởi kiện của mình, Tòa án sẽ đảm bảo các bên đưa ra yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập cũng như bảo đảm cho việc đương sự phải được hòa giải để giải quyết tranh chấp. Tại giai đoạn này, đương sự có quyền định đoạt việc tham gia hay không tham gia hòa giải, nếu tham gia có đồng ý hay không

đồng ý với những ý kiến, yêu cầu của bên còn lại. Bên cạnh đó, đương sự cũng có quyền sửa đổi, bổ sung, rút lại đơn khởi kiện. Việc rút lại đơn khởi kiện của nguyên đơn và có sự đồng ý của Tòa được coi là căn cứ để đình chỉ giải quyết vụ việc. Các bên đương sự cũng có quyền tự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự và Tòa án phải tôn trọng sự thỏa thuận đó.

Sau khi có bản án, quyết định của Tòa án: Sau khi có bản án, quyết định của Tòa án, các đương sự có quyền tự định đoạt việc có kháng cáo bản án hay không, có đơn đề nghị kháng nghị hay không, phạm vi của kháng cáo là như thế nào. Khi bản án có hiệu lực pháp luật, đương sự cũng có quyền tự định đoạt việc có đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm hay không (trừ các trường hợp không được kháng nghị) hoặc chấp nhận thi hành án. Việc yêu cầu thi hành án hay không thi hành án cũng là do đương sự tự định đoạt. Cơ quan thi hành án chỉ thi hành án khi có đơn yêu cầu (trừ một số trường hợp thi hành án không cần có đơn yêu cầu).

5.1.2.2. Cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự

Ngay từ thế kỷ thứ III trước công nguyên, trong luật La Mã cổ đại đã hình thành nguyên tắc: "Trách nhiệm chứng minh thuộc về người khẳng định, chứ không thuộc về người phủ định. Ngay cả đối với TTHS, việc cơ quan điều tra, VKS, Tòa án muốn khởi tố, truy tố, kết luận một người có tội cũng cần phải dựa trên những chứng cứ xác thực (Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án). Nghĩa vụ chứng minh thuộc về cơ quan điều tra, viện kiểm sát, Tòa án – tức những người yêu cầu, buộc tội.

Điều 6 BLTTDS 2015 quy định:

1. Đương sự có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cứ cho Tòa án và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có quyền và nghĩa vụ thu thập, cung cấp chứng cứ, chứng minh như đương sự.

2. Tòa án có trách nhiệm hỗ trợ đương sự trong việc thu thập chứng cứ và chỉ tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ trong những trường hợp do Bộ luật này quy định

Theo nguyên tắc này, các đương sự có quyền và nghĩa vụ cung cấp chứng cứ cho toà án và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có quyền và nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chứng minh như đương sự.

Trong quá trình giải quyết vụ án, toà án có trách nhiệm hướng dẫn các đương sự cung cấp chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình để bảo vệ quyền lợi của họ. Toà án chỉ tiến hành xác minh thu thập chứng cứ trong những trường

hợp do luật tố tụng dân sự quy định. Cụ thể là khi có yêu cầu của đương sự và đương sự không thể thu thập chứng cứ cần có sự giúp đỡ từ Tòa án.

5.1.2.3. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự

Cũng giống như nguyên tắc tự định đoạt của đương sự, nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự cũng phát sinh từ nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong quan hệ dân sự. Khi tham gia vào quan hệ dân sự, kể cả nhà nước (nếu vai trò là một trong các bên tham gia QHDS) thì cũng có quyền và nghĩa vụ như các chủ thể là cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình... Vì vậy, khi tham gia vào quan hệ tố tụng dân sự, các chủ thể này cũng bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

Theo nguyên tắc này, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, trước toà án, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp. Mọi cơ quan, tổ chức đều bình đẳng không phụ thuộc vào hình thức tổ chức, hình thức sở hữu và những vấn đề khác.

Các đương sự đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự, toà án có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Nguyên tắc này nhằm đảm bảo việc xét xử của toà án được công bằng, đúng pháp luật, bảo vệ đúng đắn các quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân.

5.1.2.4. Hoà giải trong tố tụng dân sự

Nguyên tắc hòa giải trong tố tụng dân sự xuất phát từ việc tôn trọng sự tự định đoạt của các đương sự, có mối quan hệ sâu sắc với nguyên tắc quyết định và tự định đoạt của đương sự. Bên cạnh đó, việc Tòa án hòa giải sẽ bảo đảm cho các đương sự hiểu được bản chất vấn đề, thể hiện được ý chí, cân bằng được quyền và lợi ích của mình cũng như đảm bảo việc giải quyết vụ án được diễn ra nhanh chóng. Nếu vụ án không được hòa giải sẽ dẫn đến hậu quả việc giải quyết kéo dài, gây tổn thất về thời gian, tiền bạc cho các bên và nhà nước. (Việc giải quyết vụ việc dân sự thông qua các giai đoạn, mỗi giai đoạn lại được thực hiện trong thời gian luật định. Thường cơ quan tiến hành tố tụng do khối lượng công việc lớn nên vận dụng tối đa thời hạn mà luật quy định. Ví dụ thời gian đưa vụ án ra xét xử, thời gian mở phiên Tòa. Bên cạnh đó, nếu các bên không hợp tác, ví dụ như vắng mặt khi xét xử khiến phiên Tòa bị hoãn cũng sẽ dẫn đến việc thời gian giải quyết diễn ra rất chậm, chưa kể việc kháng cáo, kháng nghị).

Điều 10 BLTTDS 2015 quy định

Toà án có trách nhiệm tiến hành hoà giải và tạo điều kiện thuận lợi để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của Bộ luật này.

Theo quy định, toà án có trách nhiệm tiến hành hoà giải và tạo điều kiện thuận lợi để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ việc dân sự. Hoà giải là một thủ tục tố tụng bắt buộc đối với việc giải quyết hầu hết các vụ án dân sự và có thể được tiến hành trong toàn bộ quá trình tố tụng.

Việc hòa giải được thực hiện trên cơ sở tôn trọng sự tự nguyện thoả thuận của các đương sự, không được dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, bắt buộc các đương sự phải thoả thuận không phù hợp với ý chí của mình. Nội dung thoả thuận giữa các đương sự không được trái pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội. Chỉ khi nào không hoà giải được toà án mới đưa vụ án ra xét xử, trừ một số trường hợp vụ án dân sự không được hoà giải hoặc không tiến hành hoà giải được.

5.1.3. Thẩm quyền của toà án nhân dân

5.1.3.1. Thẩm quyền của toà án nhân dân theo vụ việc

Về nguyên tắc chung, Tòa án nhân dân có nhiệm vụ xét xử tất cả các tranh chấp, yêu cầu phát sinh từ các quan hệ pháp luật dân sự (quan hệ dân sự theo nghĩa rộng: bao gồm dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động). Điều 4 BLTTDS 2015 quy định: Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng. Vụ việc dân sự chưa có điều luật để áp dụng là vụ việc dân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự nhưng tại thời điểm vụ việc dân sự đó phát sinh và cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu Tòa án giải quyết chưa có điều luật để áp dụng. Việc giải quyết vụ việc dân sự quy định tại khoản này được thực hiện theo các nguyên tắc do Bộ luật dân sự và BLTTDS quy định.

Tuy nhiên, BLTTDS 2015 vẫn quy định các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án tại các Điều 26 đến Điều 34. Cụ thể bao gồm:

- Các tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bao gồm: Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân; Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản; Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự; Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của BLTTDS 2015; Tranh chấp về thừa kế tài sản; Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính....v...v

- Các yêu cầu dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bao gồm: Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó; Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một

người mất tích; Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết; Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;v...v

- Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bao gồm: Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn; Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn; Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ; Tranh chấp về cấp dưỡng; Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.

- Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật; Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; Yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn; Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi; Yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình; Yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án; Yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình;V...V.

- Các tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bao gồm: Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; ...v...v.

- Các yêu cầu về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bao gồm: Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại; Yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo

quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam, trừ trường hợp bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án...v..v

- Các tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bao gồm: Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động mà hòa giải thành nhưng các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, hòa giải không thành hoặc không hòa giải trong thời hạn do pháp luật quy định, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải; Tranh chấp lao động tập thể về quyền giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết mà tập thể lao động hoặc người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định đó hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết; Tranh chấp về học nghề, tập nghề; Tranh chấp về cho thuê lại lao động,....

- Các yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bao gồm: Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu; Yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công; Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam...

5.1.3.2. Thẩm quyền của toà án nhân dân theo cấp xét xử.

5.1.3.2.1. Thẩm quyền của Toà án cấp huyện

Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp và các yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và tranh chấp lao động cá nhân theo quy định của pháp luật mà không có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải uỷ thác tư pháp cho cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, cho toà án nước ngoài. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam có thẩm quyền giải quyết các vụ việc nêu trên.

5.1.3.2.2. Thẩm quyền của Toà án cấp tỉnh

Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc không thuộc thẩm quyền của toà án nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật và những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án nhân dân cấp huyện mà toà án nhân dân

cấp tỉnh lấy lên để giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện.

5.1.3.3. Thẩm quyền của toà án nhân dân theo lãnh thổ

- Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định của pháp luật;

Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.

- Thẩm quyền giải quyết việc dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

Tòa án nơi người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

Tòa án nơi người bị yêu cầu thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú, bị yêu cầu tuyên bố mất tích hoặc là đã chết có nơi cư trú cuối cùng có thẩm quyền giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó, yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc là đã chết;

Tòa án nơi người yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cư trú, làm việc có thẩm quyền hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Tòa án đã ra quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc là đã chết có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc là đã chết;

Tòa án nơi người phải thi hành bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của Tòa án nước ngoài cư trú, làm việc,

nếu người phải thi hành án là cá nhân hoặc nơi người phải thi hành án có trụ sở, nếu người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức hoặc nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của Tòa án nước ngoài;

Các trường hợp khác được quy định tại Khoản 2 Điều 39 BLTTDS 2015.

5.1.3.4. Một số trường hợp nguyên đơn được lựa chọn toà án

Nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong các trường hợp sau đây:

- Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết;

- Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh tổ chức thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết;

- Nếu bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ sở ở Việt Nam hoặc vụ án về tranh chấp việc cấp dưỡng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết;

- Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết;

- Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác đối với người lao động thì nguyên đơn là người lao động có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết;

- Nếu tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng lao động của người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi người sử dụng lao động là chủ chính cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi người cai thầu, người có vai trò trung gian cư trú, làm việc giải quyết;

- Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi hợp đồng được thực hiện giải quyết;

- Nếu các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở ở nhiều nơi khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi một trong các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết;

- Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có ở nhiều địa phương khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi có một trong các bất động sản giải quyết.

Người yêu cầu có quyền lựa chọn Tòa án giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 40 BLTTDS năm 2015.

5.1.4. Các giai đoạn cơ bản của tố tụng dân sự

5.1.4.1. Khởi kiện và thụ lý vụ án

Khởi kiện vụ án dân sự là hành vi của cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc của các chủ thể khác theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình hay của người khác. Không có hành vi khởi kiện thì cũng không có quá trình giải quyết vụ án dân sự. Hành vi khởi kiện vụ án dân sự là một trong những điều kiện không thể thiếu được để làm phát sinh vụ án dân sự. Trên cơ sở hành vi khởi kiện của các chủ thể có thẩm quyền và Tòa án thụ lý thì vụ án dân sự mới phát sinh. Tuy nhiên, việc khởi kiện của các chủ thể có thẩm quyền phải được thực hiện theo các điều kiện do pháp luật quy định.

Điều kiện khởi kiện được quy định như sau:

- Chủ thể khởi kiện phải có tư cách về mặt pháp lý: Cá nhân khi khởi kiện phải có năng lực hành vi tố tụng dân sự đồng thời phải có quyền lợi bị xâm phạm; pháp nhân khởi kiện do người đại diện hợp pháp của pháp nhân thực hiện; Đối với cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì chỉ được khởi kiện đối với các trường hợp theo quy định của pháp luật như theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, Luật lao động... Đồng thời việc khởi kiện phải do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện như: cơ quan dân số, gia đình và trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ, Công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở.

Ngoài ra, các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách phải có đầy đủ các điều kiện sau:

+ Cơ quan, tổ chức đó có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, quản lý xã hội về một lĩnh vực nhất định;

+ Lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước cần yêu cầu Tòa án bảo vệ phải thuộc lĩnh vực do cơ quan, tổ chức đó phụ trách

- Chủ thể khởi kiện chỉ được khởi kiện đối với những việc thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án;

- Chủ thể khởi kiện chỉ được khởi kiện những việc trước đó toà án chưa giải quyết bằng một bản án hay quyết định đã có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

- a) Nộp trực tiếp tại Tòa án;
- b) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
- c) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Khi nộp đơn khởi kiện, người khởi kiện phải nộp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ. Bên cạnh đó, đương sự phải gửi tài liệu, chứng cứ cho đương sự khác. Mục đích của việc gửi tài liệu, chứng cứ cho đương sự khác là để phục vụ tốt hơn cho phiên họp xem xét chứng cứ và việc tranh tụng trong tố tụng.

5.1.4.2. Hoà giải, kiểm tra chứng cứ và chuẩn bị xét xử

Bằng việc thụ lý vụ án, toà án chính thức xác nhận trách nhiệm giải quyết vụ án. Để thực hiện trách nhiệm này, toà án phải tiến hành hàng loạt những công việc nhằm chuẩn bị cơ sở cho các quyết định của toà án. Thời hạn thực hiện việc chuẩn bị xét xử được quy định là bốn tháng đối với những tranh chấp về dân sự và hôn nhân gia đình; hai tháng đối với những tranh chấp về kinh doanh thương mại và lao động, kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với những vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì Chánh án toà án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá hai tháng đối với những tranh chấp về dân sự và hôn nhân gia đình; một tháng đối với những tranh chấp về kinh doanh thương mại và lao động.

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, tùy từng trường hợp, toà án ra một trong các quyết định sau đây:

- Công nhận sự thoả thuận của các đương sự;
- Tạm đình chỉ giải quyết vụ án;
- Đình chỉ giải quyết vụ án;
- Đưa vụ án ra xét xử.

Sau khi đã hoàn thiện hồ sơ vụ án, nếu không có căn cứ để tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án thì trước khi đưa vụ án ra xét xử tại phiên toà, toà án mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải giữa các đương sự, trừ những vụ án không được hoà giải (bao gồm yêu cầu bồi thường thiệt hại đến tài sản của Nhà nước; những vụ án dân sự phát sinh từ giao dịch trái pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội) hoặc không tiến hành hoà giải

được (do bị đơn đã được toà án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt; đương sự không thể tham gia hoà giải được vì có lý do chính đáng; đương sự là vợ hoặc chồng trong vụ án ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự, Một trong các đương sự đề nghị không tiến hành hòa giải.). Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng thể hiện tính đặc trưng và riêng biệt của tố tụng dân sự.

Việc hoà giải được tiến hành theo các nguyên tắc sau:

- Tôn trọng sự tự nguyện thoả thuận của các đương sự; không được dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực bắt buộc các đương sự phải thoả thuận không phù hợp với ý chí của mình;
- Nội dung của sự thoả thuận giữa các đương sự không được trái pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội.

Việc hòa giải phải được lập thành biên bản. Trường hợp các bên hòa giải được với nhau thì hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải hoặc một Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công phải ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, nếu phát hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc giải quyết vụ án dân sự có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên thì Tòa án có thể kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Bên cạnh việc hòa giải, BLTTDS năm 2015 còn bổ sung việc kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ tại phiên hòa giải vừa để bảo đảm thực hiện yêu cầu của nguyên tắc “tranh tụng” (mọi tài liệu chứng cứ phải được công khai), vừa bảo đảm nguyên tắc “Hòa giải trong tố tụng dân sự”. Tuy nhiên, nhằm tránh phát sinh thêm những thủ tục không cần thiết, BLTTDS kết hợp 2 nội dung kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào cùng một phiên họp. Trình tự phiên họp này có 2 phần: phần thứ nhất là kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ; phần thứ hai là tiến hành hòa giải.

Riêng về việc chuẩn bị hòa giải đối với vụ án hôn nhân và gia đình liên quan đến người chưa thành niên, trước khi mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải giữa các đương sự thì Thẩm phán, Thẩm tra viên được Chánh án Tòa án phân công phải thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định nguyên nhân của việc phát sinh tranh chấp. Khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán có

thể tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em về hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân phát sinh tranh chấp và nguyện vọng của vợ, chồng, con có liên quan đến vụ án.

Đối với vụ án tranh chấp về nuôi con khi ly hôn hoặc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, Thẩm phán phải lấy ý kiến của con chưa thành niên từ đủ bảy tuổi trở lên, trường hợp cần thiết có thể mời đại diện cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em chứng kiến, tham gia ý kiến. Việc lấy ý kiến của con chưa thành niên và các thủ tục tố tụng khác đối với người chưa thành niên phải bảo đảm thân thiện, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức độ trưởng thành, khả năng nhận thức của người chưa thành niên, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, giữ bí mật cá nhân của người chưa thành niên.

Nếu không hòa giải thành, không có căn cứ để ra quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án hoặc quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự thì toà án phải quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử kết thúc giai đoạn chuẩn bị xét xử và bắt đầu cho một giai đoạn tố tụng mới – giai đoạn xét xử tại phiên tòa.

5.1.4.3. Xét xử sơ thẩm

Việc mở phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự là một bảo đảm về tố tụng để đương sự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Việc mở phiên tòa phải bảo đảm sự có mặt của đương sự, người tiến hành tố tụng. Nếu có sự vắng mặt của một trong các chủ thể nêu trên thì phải hoãn phiên tòa.

Thủ tục phiên tòa sơ thẩm gồm có: Thủ tục bắt đầu phiên tòa, tranh tụng tại phiên tòa, nghị án, tuyên án.

Trong quá trình bắt đầu phiên tòa, nếu có yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch thì Hội đồng xét xử phải xem xét, quyết định.

Bản án sơ thẩm không có hiệu lực pháp luật ngay mà có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật

5.1.4.4. Xét xử phúc thẩm

Phúc thẩm dân sự là việc tòa án cấp trên trực tiếp xét lại vụ án dân sự mà bản án, quyết định sơ thẩm của tòa án cấp dưới chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Toà án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại phần của bản án, quyết định sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị.

Thủ tục tiến hành phiên tòa phúc thẩm tương tự với thủ tục tại phiên tòa sơ thẩm.

Toà án cấp phúc thẩm có quyền:

1. Giữ nguyên bản án sơ thẩm;
2. Sửa bản án sơ thẩm;
3. Hủy bản án sơ thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm;
4. Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án;
5. Đình chỉ xét xử phúc thẩm;
6. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án khi có văn bản của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản trả lời Tòa án kết quả xử lý.

Bên cạnh đó, tại phiên toà phúc thẩm, nếu các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án và thoả thuận của họ là tự nguyện, không trái pháp luật hoặc đạo đức xã hội thì hội đồng xét xử phúc thẩm ra bản án phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thoả thuận của các đương sự. Quyết định phúc thẩm là chung thẩm, có hiệu lực thi hành.

5.1.4.5. Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của toà án đã có hiệu lực pháp luật vì những nguyên nhân khác nhau có thể không đúng đắn. Vì vậy, pháp luật quy định hai thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật là thủ tục giám đốc thẩm và thủ tục tái thẩm.

- Thủ tục giám đốc thẩm: Là xét lại bản án, quyết định của toà án có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.

- Thủ tục tái thẩm: Là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà toà án, các đương sự không biết được khi toà án ra bản án, quyết định đó.

Hội đồng giám đốc thẩm có các quyền sau đây:

1. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
2. Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa;
3. Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm hoặc xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm;

4. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án;
5. Sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Hội đồng tái thẩm có các quyền sau đây:

1. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
2. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục do Bộ luật này quy định.
3. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án.

5.1.5. Quyền và nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng dân sự

Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đương sự trong việc dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm người yêu cầu giải quyết việc dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện, người được cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm. Cơ quan, tổ chức do Bộ luật này quy định khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách cũng là nguyên đơn.

Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trường hợp việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự là người yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý làm căn cứ phát sinh quyền, nghĩa vụ về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc

của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; yêu cầu Tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc dân sự là người tuy không yêu cầu giải quyết việc dân sự nhưng việc giải quyết việc dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc đương sự trong việc dân sự đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trường hợp giải quyết việc dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc dân sự

5.1.5.1. Quyền của đương sự trong tố tụng dân sự

- Giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu theo quy định của Bộ luật này.

- Cung cấp tài liệu, chứng cứ; chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình.

- Đề nghị Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ việc mà tự mình không thể thực hiện được; đề nghị Tòa án yêu cầu đương sự khác xuất trình tài liệu, chứng cứ mà họ đang giữ; đề nghị Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó; đề nghị Tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, quyết định việc định giá tài sản.

- Được biết, ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do đương sự khác xuất trình hoặc do Tòa án thu thập, trừ tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này.

- Đề nghị Tòa án quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.

- Tự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án; tham gia hòa giải do Tòa án tiến hành.

- Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

- Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

- Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật này.

- Tham gia phiên tòa, phiên họp theo quy định.

- Đề nghị Tòa án đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.

- Đề nghị Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ việc theo quy định của Bộ luật này.

- Đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án hoặc đề xuất với Tòa án những vấn đề cần hỏi người khác; được đối chất với nhau hoặc với người làm chứng.

- Tranh luận tại phiên tòa, đưa ra lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng.

- Được cấp trích lục bản án, bản án, quyết định của Tòa án.

- Kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Bộ luật này.

- Đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

5.1.5.2. Nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng dân sự

- Tôn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa.

- Nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nơi cư trú, trụ sở của mình; trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc nếu có thay đổi địa chỉ nơi cư trú, trụ sở thì phải thông báo kịp thời cho đương sự khác và Tòa án.

- Có nghĩa vụ gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của họ bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ, trừ tài liệu, chứng cứ mà đương sự khác đã có, tài liệu, chứng cứ liên quan đến bí mật kinh doanh.. Trường hợp vì lý do chính đáng không thể sao chụp, gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ thì họ có quyền yêu cầu Tòa án hỗ trợ.

- Phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành quyết định của Tòa án trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc.

- Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

- Sử dụng quyền của đương sự một cách thiện chí, không được lạm dụng để gây cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án, đương sự khác; trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thì phải chịu hậu quả do Bộ luật này quy định.

5.1.6. Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự

5.1.6.1. Chứng minh

Chứng minh trong tố tụng dân sự là hoạt động của các chủ thể tố tụng theo quy định của pháp luật trong việc làm rõ các tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự.

Để bảo đảm hoạt động chứng minh đúng đắn và toàn diện nhằm bảo đảm hiệu quả cho việc giải quyết vụ việc dân sự, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, pháp luật tố tụng dân sự hiện hành quy định những chủ thể tố tụng là chủ thể tham gia vào hoạt động chứng minh; các quyền và nghĩa vụ chứng minh của các chủ thể đó; những tình tiết, sự kiện trong vụ việc dân sự phải chứng minh và những tình tiết, sự kiện không cần chứng minh; trình tự, thủ tục chứng minh v.v...

Chứng minh là hoạt động làm rõ được các sự kiện, tình tiết của vụ việc dân sự, đồng thời làm rõ cơ sở pháp lý của việc giải quyết vụ việc, làm cơ sở bảo đảm cho việc giải quyết các vụ việc dân sự được đúng đắn. Chứng minh trong tố tụng dân sự có các ý nghĩa sau đây:

Thứ nhất, bằng việc chứng minh khi tham gia tố tụng giúp cho các đương sự chỉ rõ được các tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự, đồng thời làm rõ được cơ sở pháp lý của các quyền, lợi ích hợp pháp của họ, từ đó thuyết phục Toà án bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp. Trong quá trình tố tụng, nếu đương sự không chứng minh được sự tồn tại quyền, lợi ích hợp pháp của họ thì quyền và lợi ích hợp pháp của họ có thể sẽ không được Toà án bảo vệ.

Thứ hai, Toà án thông qua việc chứng minh có thể xác định một cách khách quan, đầy đủ các tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự. Trên cơ sở làm rõ được các tình tiết khách quan của vụ việc dân sự giúp Toà án chỉ ra được các căn cứ pháp lý cho việc giải quyết vụ việc dân sự, đó là cơ sở cho việc Toà án ra các bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự bảo đảm tính hợp pháp và tính có căn cứ.

Pháp luật quy định nghĩa vụ chứng minh như sau:

- Đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp.
- Đương sự phản đối yêu cầu của người khác đối với mình phải thể hiện bằng văn bản và phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho sự phản đối đó.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước hoặc yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho việc khởi kiện, yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.
- Đương sự có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ để chứng minh mà không đưa ra được chứng cứ hoặc không đưa ra đủ chứng cứ thì Tòa án giải quyết vụ việc dân sự theo những chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ việc.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh như sau:

- Những tình tiết, sự kiện rõ ràng mà mọi người đều biết và được Tòa án thừa nhận;

- Những tình tiết, sự kiện đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật;

- Những tình tiết, sự kiện đã được ghi trong văn bản và được công chứng, chứng thực hợp pháp; trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ tính khách quan của những tình tiết, sự kiện này hoặc tính khách quan của văn bản công chứng, chứng thực thì Thẩm phán có thể yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ chức công chứng, chứng thực xuất trình bản gốc, bản chính.

- Một bên đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản, kết luận của cơ quan chuyên môn mà bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đó không phải chứng minh.

- Đương sự có người đại diện tham gia tố tụng thì sự thừa nhận của người đại diện được coi là sự thừa nhận của đương sự nếu không vượt quá phạm vi đại diện

5.1.6.2. Chứng cứ

5.1.6.2.1. Khái niệm chứng cứ.

Trong tố tụng dân sự, những tin tức, dấu vết về các tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự được thể hiện dưới những hình thức nhất định do toà án sử dụng làm cơ sở để giải quyết vụ việc dân sự được gọi là chứng cứ. Do vậy, nếu hiểu theo nghĩa chung, chứng cứ là cái có thật mà căn cứ vào đó để toà án giải quyết vụ việc dân sự. Tuy vậy, hoạt động tố tụng cung cấp, giao nộp, xem xét, đánh giá và sử dụng chứng cứ thường bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố khác nhau. Để bảo đảm việc giải quyết các vụ việc dân sự được đúng đắn thì các hoạt động tố tụng này phải được pháp luật quy định đầy đủ và chặt chẽ. Từ đó, có thể định nghĩa chứng cứ như sau:

Chứng cứ là cái có thật, theo một trình tự do luật định toà án dùng làm căn cứ để giải quyết vụ việc dân sự.

5.1.6.2.2. Đặc điểm của chứng cứ.

Chứng cứ có những đặc điểm sau:

- Tính khách quan: Chứng cứ trước hết phải là những gì có thật, khách quan không phụ thuộc vào ý thức chủ quan của con người. Chứng cứ sinh ra, thay đổi hình thức hoặc nội dung và có thể mất đi là hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của con người. Toà án, Viện Kiểm sát và những người tham gia tố tụng có thể thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ, nhưng không tạo ra chứng cứ .

- Tính liên quan của chứng cứ: Chứng cứ là những sự kiện thực tế khách quan và có liên quan trực tiếp đến vụ án mà Tòa án cần giải quyết. Những sự kiện không có ý nghĩa đối với vụ án thì không được thu thập và đánh giá như những chứng cứ.

- Tính hợp pháp của chứng cứ : Các sự kiện hợp pháp chỉ được coi là chứng cứ khi nó được thu thập, bảo quản, củng cố, nghiên cứu và đánh giá theo một trình tự do luật định.

5.1.6.2.3. Nguồn của chứng cứ.

Nguồn chứng cứ bao gồm người, vật, tài liệu mang các thông tin về vụ việc dân sự. Như vậy, nguồn chứng cứ có hai loại chủ yếu là người, vật và tài liệu. Việc phân biệt các nguồn chứng cứ có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định giá trị chứng minh của mỗi loại chứng cứ. Thông thường, các chứng cứ được rút ra từ các vật, tài liệu việc nghiên cứu, đánh giá và sử dụng không mấy phức tạp vì chúng ít bị chi phối bởi ngoại cảnh. Đối với những chứng cứ được rút ra từ con người như đương sự, người làm chứng việc nghiên cứu, đánh giá và sử dụng chúng rất phức tạp. Nét chung nhất của con người với nghĩa là nguồn chứng cứ bị chi phối rất lớn bởi yếu tố lợi ích, tâm lý, khả năng nhận thức, nhớ và phản ánh lại những gì họ thấy, sự quan tâm của họ đối với sự kiện v.v.. Tất cả những yếu tố này đều phải tính đến khi nghiên cứu, đánh giá và sử dụng các chứng cứ được rút ra từ đương sự, người làm chứng.

Chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau đây:

1. Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử.
2. Vật chứng.
3. Lời khai của đương sự.
4. Lời khai của người làm chứng.
5. Kết luận giám định.
6. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ.
7. Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.
8. Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập.
9. Văn bản công chứng, chứng thực.
10. Các nguồn khác mà pháp luật có quy định

5.1.6.2.4. Xác định chứng cứ

- Tài liệu đọc được nội dung được coi là chứng cứ nếu là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp, xác nhận.

- Tài liệu nghe được, nhìn được được coi là chứng cứ nếu được xuất trình kèm theo văn bản trình bày của người có tài liệu đó về xuất xứ của tài liệu nếu họ tự thu âm, thu hình hoặc văn bản có xác nhận của người đã cung cấp cho người xuất trình về xuất xứ của tài liệu đó hoặc văn bản về sự việc liên quan tới việc thu âm, thu hình đó.

- Thông điệp dữ liệu điện tử được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Vật chứng là chứng cứ phải là hiện vật gốc liên quan đến vụ việc.

- Lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng được coi là chứng cứ nếu được ghi bằng văn bản, băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình, thiết bị khác chứa âm thanh, hình ảnh theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc khai bằng lời tại phiên tòa.

- Kết luận giám định được coi là chứng cứ nếu việc giám định đó được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.

- Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ được coi là chứng cứ nếu việc thẩm định được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.

- Kết quả định giá tài sản, kết quả thẩm định giá tài sản được coi là chứng cứ nếu việc định giá, thẩm định giá được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.

- Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập tại chỗ được coi là chứng cứ nếu việc lập văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.

- Văn bản công chứng, chứng thực được coi là chứng cứ nếu việc công chứng, chứng thực được thực hiện theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.

5.2. Luật Tố tụng hình sự

Tố tụng hình sự là trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự được cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện, nhằm phát hiện, xử lý tội phạm một cách kịp thời chính xác, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Việc thực hiện toàn bộ quá trình giải quyết vụ án hình sự phải tuân theo những nguyên tắc nhất định.

Luật tố tụng hình sự là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khởi tố, điều tra, xét xử và thi hành án hình sự.

5.2.1. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng hình sự

Nguyên tắc của Luật tố tụng hình sự là những nguyên lý, tư tưởng pháp lý được ghi nhận trong các văn bản pháp luật tố tụng hình sự nhằm chỉ đạo và định hướng cho việc xây dựng và thực hiện pháp luật tố tụng hình sự.

Việc tuân thủ triệt để các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự trước hết tạo điều kiện cho cơ quan xét xử tiến hành tố tụng một cách thuận lợi và nhanh chóng, xử lý chính xác đúng người đúng tội; ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật và những biểu hiện tiêu cực trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.

Tương tự với Luật tố tụng dân sự, Luật TTHS quy định rất nhiều các nguyên tắc, trong đó, có thể phân chia thành hai nhóm.

Nhóm thứ nhất bao gồm các nguyên tắc tố tụng chung, áp dụng cho cả tố tụng dân sự, TTHS, TTHC, bao gồm: Nguyên tắc xét xử có hội thẩm nhân dân, Nguyên tắc hai cấp xét xử, Nguyên tắc thẩm phán xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, Nguyên tắc tranh tụng....

Nhóm thứ hai bao gồm các nguyên tắc đặc thù của TTHS, chỉ Luật TTHS mới quy định, thể hiện bản chất của Luật TTHS bao gồm: Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án, Nguyên tắc suy đoán vô tội, Nguyên tắc Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

5.2.1.1. Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án

Suy cho cùng, đều hướng đến một mục đích chung nhất đó chính là làm rõ có tội phạm hay không và người bị buộc tội có thật sự phạm tội hay không. Muốn vậy, việc xác định sự thật của vụ án đóng vai trò quan trọng nhất để đạt được mục đích đó. Nói cách khác, áp dụng nguyên tắc xác định sự thật còn đảm bảo cho việc xử lý vụ án được công minh, không để lọt tội phạm đồng thời không bắt nhầm, làm oan người vô tội. Việc xác định sự thật phải dựa trên những tình tiết, những căn cứ xác thực.

Điều 15 BLTTHS năm 2015 quy định:

Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng các biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người bị buộc tội.

Các cơ quan tiến hành tố tụng được Nhà nước thành lập và giao quyền áp dụng các biện pháp do Bộ luật tố tụng hình sự quy định; có chuyên môn nghiệp vụ

, do đó các cơ quan tiến hành tố tụng có điều kiện để xác định sự thật khách quan của vụ án.

Để buộc một người phải chịu trách nhiệm hình sự, Nhà nước thông qua các cơ quan chuyên trách của mình phải có trách nhiệm đưa ra chứng cứ chứng minh họ đã thực hiện hành vi phạm tội xâm hại đến lợi ích chung. Do vậy, trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng.

Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án. Các biện pháp hợp pháp đó là các biện pháp do BLTTHS quy định, bao gồm các biện pháp ngăn chặn, các biện pháp điều tra thu thập chứng cứ và các biện pháp khác do pháp luật quy định. Việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn này sẽ làm ảnh hưởng tới các quyền cơ bản của công dân do vậy, khi sử dụng các biện pháp đó, các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án phải nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật về việc áp dụng các biện pháp đó, không được sử dụng các biện pháp bất hợp pháp để tiến hành làm rõ vụ án.

Nội dung của việc xác định sự thật chính là trả lời các câu hỏi như: có hành vi phạm tội xảy ra hay không. Việc trả lời câu hỏi dựa vào việc xác minh một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ thời gian, địa điểm và các tình tiết khác của hành vi phạm tội; ai là người thực hiện hành vi phạm tội; có lỗi hay không có lỗi, do cố ý hay do vô ý; có năng lực trách nhiệm hình sự hay không; mục đích hoặc động cơ phạm tội; những tình tiết tăng nặng, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo và những đặc điểm về nhân thân của bị can, bị cáo; tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra...

5.2.1.2. Nguyên tắc suy đoán vô tội

Xuất phát từ quyền con người được quốc tế thừa nhận. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 của Liên hợp quốc quy định: *“Bất kỳ người bị buộc tội nào đều có quyền suy đoán là không phạm tội cho đến khi lỗi của người đó được xác định theo một trình tự do pháp luật quy định bằng phiên tòa xét xử công khai của Tòa án với sự bảo đảm đầy đủ khả năng bào chữa của người đó”*. Pháp luật tố tụng hình sự của nhiều nước trên thế giới đã thừa nhận nguyên tắc trên và coi nguyên tắc suy đoán vô tội là một trong những nguyên tắc của tố tụng hình sự của quốc gia mình.

Nguyên tắc suy đoán vô tội cũng được ghi nhận trong Hiến pháp 2013. Cụ thể, Khoản 1 Điều 31 Hiến Pháp 2013 có quy định *“Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”*.

Việc quy định nguyên tắc là để đảm bảo tính chứng minh trong TTHS. Sự việc một người bị cho rằng có tội cần được xem xét dưới góc độ đa chiều, đa

chiều, cần trọng. Việc quy định nguyên tắc giúp bảo vệ được quyền của người bị buộc tội. Việc định kiến người bị buộc tội là người có tội kéo theo đó là việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế tố tụng tràn lan, thiếu căn cứ, chà đạp lên quyền con người mà nhiều trường hợp khi vụ án được xem xét lại thì họ hoàn toàn vô tội..

Điều 13 BLTTHS 2015 quy định nguyên tắc suy đoán vô tội như sau:

Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo không có tội.

Nguyên tắc suy đoán vô tội đòi hỏi bất cứ tội phạm nào cũng phải được chứng minh theo trình tự, thủ tục do pháp luật TTHS quy định. Quá trình chứng minh tội phạm được thực hiện từ khi có tố giác, tin báo về tội phạm và thông qua các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành các hoạt động điều tra, kết thúc điều tra đề nghị truy tố, truy tố bằng bản cáo trạng và tiến hành xét xử, điều tra công khai tại phiên tòa.

Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo không có tội. Việc làm sáng tỏ chỉ trong 1 khoảng thời gian nhất định.

Hiến Pháp 2013 cũng chỉ rõ “*người bị buộc tội phải được Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, công bằng, công khai*” Quá thời hạn quy định mà không chứng minh được thì người bị buộc tội được kết luận không có tội.

Ví dụ quá trình điều tra diễn ra thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra. Quá thời hạn này thì Cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra. Các biện pháp ngăn chặn như tạm giam, tạm giữ cũng phải được thực hiện một cách cần trọng, có căn cứ và bị giới hạn trong khoảng thời gian nhất định. BLTTHS cũng quy định rõ chế độ tạm giữ, tạm giam khác với chế độ đối với người đang chấp hành hình phạt tù, thể hiện sự tôn trọng đối với người bị buộc tội khi chưa khẳng định họ có tội.

Bản án hình sự sơ thẩm chỉ có hiệu lực khi nó không có kháng cáo kháng nghị trong thời hạn luật định. Điều đó cho thấy, dù đã có bản án kết tội nhưng nếu bản án ấy bị kháng cáo, kháng nghị thì bị cáo vẫn được coi là không có tội. Trong quá trình xét xử phúc thẩm, Tòa án và cơ quan tiến hành tố tụng vẫn phải tuân thủ

nguyên tắc suy đoán vô tội. Bản án hình sự phúc thẩm phải căn cứ cả vào những chứng cứ mới và những chứng cứ cũ. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng xét xử tuyên án. Một người chỉ có thể bị coi là có tội khi có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

5.2.1.3. Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo

Nguyên tắc này thể hiện:

- Bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho mình (có thể nhờ Luật sư, bào chữa viên nhân dân hoặc người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo)

- Trong một số trường hợp luật định nếu bị can, bị cáo và người đại diện hợp pháp của họ không nhờ người bào chữa thì cơ quan tiến hành tố tụng chỉ định người bào chữa cho bị can, bị cáo (người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc tinh thần...)

- Đảm bảo pháp lý cho quyền bào chữa của bị can, bị cáo được thực hiện, cơ quan tiến hành tố tụng có nhiệm vụ bảo đảm cho họ được thực hiện quyền bào chữa

5.2.2. Các giai đoạn cơ bản của Tố tụng hình sự

5.2.2.1. Khởi tố vụ án hình sự

a. Khái niệm Khởi tố vụ án hình sự:

Khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn mở đầu của tố tụng hình sự trong đó cơ quan có thẩm quyền xác định có hay không có dấu hiệu của tội phạm để quyết định khởi tố vụ án.

b. Căn cứ khởi tố vụ án

Là những nguồn tin mà dựa vào đó cơ quan khởi tố xác định dấu hiệu tội phạm. Để khởi tố vụ án hình sự cần dựa vào các căn cứ sau đây:

- Tổ giác của cá nhân;
- Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
- Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng;
- Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước;
- Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm;
- Người phạm tội tự thú.

c. Thẩm quyền khởi tố vụ án

* Cơ quan điều tra khởi tố vụ án bao gồm:

- Cơ quan điều tra của lực lượng cảnh sát nhân dân và lực lượng an ninh nhân dân;

- Cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân khởi tố vụ án hình sự đối với những vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự (trừ những vụ án do

Viện kiểm sát quân sự hoặc cơ quan điều tra của Viện kiểm sát quân sự khởi tố và những tội phạm mà người thực hiện là cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân.

- Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự trong những trường hợp pháp luật quy định.

* Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự trong những trường hợp sau:

a) Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

b) Viện kiểm sát trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

c) Viện kiểm sát trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc theo yêu cầu khởi tố của Hội đồng xét xử..

* Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm.

* Đơn vị bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra mà phát hiện hành vi phạm tội đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

d. Trình tự khởi tố vụ án hình sự:

- Tiếp nhận tố giác và tin báo về tội phạm.

- Kiểm tra, xác minh các tin tức về tội phạm.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định:

- Quyết định khởi tố vụ án hình sự;

- Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;

- Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nhưng tối đa không quá 4 tháng

e. Căn cứ không khởi tố vụ án hình sự:

Không được khởi tố vụ án hình sự khi có một trong những căn cứ sau đây:

- Không có sự việc phạm tội;

- Hành vi không cấu thành tội phạm;

- Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự;
- Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật;
- Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Tội phạm đã được đại xá;
- Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác.

5.2.2.2. Điều tra vụ án hình sự

a. Khái niệm:

Điều tra vụ án hình sự là những hoạt động gồm nhiều mặt của các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành điều tra nhằm phát hiện tội phạm và những người thực hiện hành vi phạm tội, thu thập chứng cứ, tìm hiểu nguyên nhân và điều kiện phạm tội làm cơ sở cho việc xét xử của Tòa án.

b. Cơ quan điều tra

- Cơ quan điều tra của lực lượng cảnh sát nhân dân.
- Cơ quan điều tra của lực lượng an ninh nhân dân.
- Cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân.
- Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân
- Cơ quan điều tra thuộc bộ đội biên phòng, cơ quan hải quan và cơ quan kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển, Kiểm ngư

c. Các hoạt động điều tra

Hoạt động điều tra bao gồm các hoạt động sau:

- Khởi tố bị can;
- Hỏi cung bị can;
- Lấy lời khai của người làm chứng;
- Lấy lời khai của người bị hại;
- Đối chất;
- Nhận dạng;
- Khám xét;
- Tạm giữ đồ vật, tài liệu khi khám xét.
- Kê biên tài sản;
- Khám nghiệm hiện trường;
- Khám nghiệm tử thi, xem xét dấu vết trên thân thể;
- Thực nghiệm điều tra;

- Giám định.

d. Kết thúc điều tra

Khi kết thúc điều tra, Cơ quan điều tra phải làm bản kết luận điều tra. Việc điều tra kết thúc khi Cơ quan điều tra ra bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc ra bản kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra.

5.2.2.3. Truy tố vụ án hình sự

Truy tố là một giai đoạn tố tụng hình sự, trong đó Viện kiểm sát tiến hành các hoạt động cần thiết nhằm truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng hoặc ra những quyết định tố tụng khác để giải quyết đúng đắn vụ án.

Trong thời hạn 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, 30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện kiểm sát phải ra một trong các quyết định:

- a) Truy tố bị can trước Tòa án;
- b) Trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung;
- c) Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can.

Trường hợp cần thiết, Viện trưởng Viện kiểm sát có thể gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố nhưng không quá 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra một trong các quyết định nêu trên, Viện kiểm sát phải thông báo cho bị can, người bào chữa hoặc người đại diện của bị can, bị hại biết việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung; giao cho bị can hoặc người đại diện của bị can và gửi cho Cơ quan điều tra, người bào chữa bản cáo trạng, quyết định đình chỉ vụ án hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can; thông báo cho bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung khi nghiên cứu hồ sơ vụ án phát hiện thấy:

+ Còn thiếu chứng cứ để chứng minh một trong những vấn đề quy định tại Điều 85 (Có hành vi phạm tội xảy ra hay không, thời gian, địa điểm và những tình tiết khác của hành vi phạm tội; Ai là người thực hiện hành vi phạm tội; có lỗi hay không có lỗi, do cố ý hay vô ý; có năng lực trách nhiệm hình sự hay không; mục đích, động cơ phạm tội; Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo và đặc điểm về nhân thân của bị can, bị cáo; Tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra; Nguyên nhân và điều kiện phạm tội;

Những tình tiết khác liên quan đến việc loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt) của Bộ luật này mà Viện kiểm sát không thể tự mình bổ sung được;

- + Có căn cứ khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác;
- + Có người đồng phạm hoặc người phạm tội khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố bị can;
- + Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Trường hợp Viện kiểm sát xem xét thấy có đủ căn cứ để truy tố thì lập bản cáo trạng. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra bản cáo trạng, Viện kiểm sát phải chuyển hồ sơ vụ án và bản cáo trạng đến Tòa án. Trường hợp vụ án phức tạp thì thời hạn chuyển hồ sơ vụ án và bản cáo trạng đến Tòa án có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày. Trường hợp vụ án không thuộc thẩm quyền truy tố của mình, Viện kiểm sát ra ngay quyết định chuyển vụ án cho Viện kiểm sát có thẩm quyền.

Trong một số các trường hợp luật định, khi hồ sơ đã được chuyển sang Tòa án mà Tòa án thấy cần phải làm rõ, bổ sung các tình tiết chứng cứ thì Tòa án ra quyết định trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra bổ sung thì Viện kiểm sát phải xem xét căn cứ của việc yêu cầu điều tra bổ sung để bổ sung hoặc có văn bản nêu rõ lý do, giữ nguyên quyết định truy tố và chuyển lại hồ sơ cho Tòa án.

Ngoài ra, nếu có các căn cứ để tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án thì Viện Kiểm sát ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án hình sự.

5.2.2.4. Xét xử vụ án hình sự

a. Xét xử sơ thẩm vụ án

Giai đoạn xét xử sơ thẩm bắt đầu kể từ ngày Tòa án nhận được hồ sơ do Viện kiểm sát chuyển sang. Sau khi nhận hồ sơ vụ án, thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa phải nghiên cứu hồ sơ, giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tham gia tố tụng, tiến hành các công việc khác cần thiết cho việc mở phiên tòa. Trong thời hạn 30 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 45 ngày đối với tội phạm nghiêm trọng, 02 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, 03 tháng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra một trong các quyết định:

- a) Đưa vụ án ra xét xử;
- b) Trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung;
- c) Tạm đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ vụ án.

Đối với vụ án phức tạp, Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 15 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội

phạm đặc biệt nghiêm trọng. Việc gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử phải thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp.

Thẩm quyền xét xử:

- Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về những tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm sau đây (Các tội xâm phạm an ninh quốc gia; Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh; Các tội quy định tại các điều 123, 125, 126, 227, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 337, 368, 369, 370, 371, 399 và 400 của Bộ luật hình sự của Bộ luật hình sự).

- Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án quân sự cấp quân khu xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về những tội phạm không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp dưới mà mình lấy lên để xét xử.

Phiên tòa sơ thẩm được tiến hành qua các bước: Khai mạc phiên tòa, tranh tụng, nghị án và tuyên án. Nếu bị cáo có tội thì Tòa án ra bản án kết tội, quyết định mức hình phạt hoặc miễn hình phạt; nếu bị cáo không có tội thì bản án tuyên bố bị cáo không có tội và trả tự do ngay cho bị cáo tại phiên tòa.

Bản án đã được Hội đồng xét xử thông qua được chủ tọa đọc tại phòng xử án. Chủ tọa phiên tòa cần giải thích thêm về việc chấp hành bản án và quyền kháng cáo, kháng nghị. Thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án, thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp là 15 ngày, của Viện kiểm sát nhân dân cấp trên là 30 ngày kể từ ngày tuyên án.

b. Xét xử phúc thẩm

Phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét lại những bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị. Vì vậy đây là một giai đoạn độc lập trong tố tụng hình sự, giai đoạn này có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp, tính có căn cứ của bản án sơ thẩm sửa những sai lầm và vi phạm của Tòa án trong xét xử sơ thẩm.

Thủ tục của phiên tòa phúc thẩm cũng tiến hành như phiên tòa sơ thẩm. Trước khi xét hỏi, một thành viên của Hội đồng xét xử phải trình bày nội dung tóm tắt của vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm và nội dung của kháng cáo, kháng nghị. Tòa án cấp phúc thẩm có quyền quyết định:

- Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm;
- Sửa bản án sơ thẩm;
- Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại hoặc xét xử lại;
- Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án;

- Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm.

5.2.2.5 Thi hành bản án, quyết định của Tòa án

Đây là giai đoạn cuối cùng của tố tụng hình sự nhằm đảm bảo cho các biện pháp hình phạt được Tòa án tuyên trong bản án được thực hiện kịp thời và triệt để. Những cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định của Tòa án là công an, chính quyền xã, hoặc cơ quan nơi người bị kết án làm việc phải báo cáo cho chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án về việc bản án, quyết định được thi hành.

5.2.2.6. Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

a. Thủ tục Giám đốc thẩm

- Giám đốc thẩm là xét lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc xử lý vụ án.

- Căn cứ để kháng nghị là:

- + Kết luận trong bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án;

- + Có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong khi điều tra, truy tố hoặc xét xử;

- + Có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng Bộ luật hình sự.

- Hội đồng giám đốc thẩm có thể ra quyết định:

- + Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị.

- + Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm bị hủy, sửa không đúng pháp luật.

- + Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại.

- + Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án.

- + Sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

- + Đình chỉ xét xử giám đốc thẩm.

- Quyết định của hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

b. Thủ tục Tái thẩm:

Thủ tục tái thẩm được áp dụng đối với bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể

làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án hoặc quyết định mà Tòa án không biết được khi ra bản án hoặc quyết định đó.

- Những căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

- + Có căn cứ chứng minh lời khai của người làm chứng, kết luận giám định, kết luận định giá tài sản, lời dịch của người phiên dịch, bản dịch thuật có những điểm quan trọng không đúng sự thật;

- + Có tình tiết mà Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm do không biết được mà kết luận không đúng làm cho bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật không đúng sự thật khách quan của vụ án;

- + Vật chứng, biên bản về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, biên bản hoạt động tố tụng khác hoặc những chứng cứ, tài liệu, đồ vật khác trong vụ án bị giả mạo hoặc không đúng sự thật;

- + Những tình tiết khác làm cho bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật không đúng sự thật khách quan của vụ án.

- Hội đồng tái thẩm có quyền ra quyết định:

- + Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị.

- + Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại.

- + Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án.

- + Đình chỉ việc xét xử tái thẩm.

- Quyết định của hội đồng tái thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.